

제9장 각종의 가처분과 그 집행

제1절 부동산에 대한 가처분

1. 처분금지가처분

가. 피보전권리

(1) 부동산처분금지가처분은 부동산에 대한 채무자의 소유권이전, 저당권·전세권·임차권의 설정 그 밖에 일체의 처분행위를 금지하는 가처분이다. 가처분등기 이후 채무자로부터 부동산을 양수한 사람은 가처분채권자에게 대항할 수 없게 되어 피보전권리의 실현을 위한 소송과 집행절차에서 당사자를 항정시킬 수 있다. 이러한 당사자항정이 가처분의 주된 목적이다. 또한 가처분채권자는 본안승소 확정판결을 받으면 가처분등기 이후 다른 등기를 한 사람보다 우선하여 판결에 따른 등기를 할 수 있다. 이를 가처분의 순위보전적 효력이라고 부른다.

(2) 부동산처분금지가처분의 대표적인 피보전권리는 소유권에 기한 이전등기청구권, 말소등기청구권과 같은 부동산에 대한 이행청구권이다.

자기 소유 토지 위의 채무자 소유 건물에 대한 철거청구권, 즉 방해배제청구권의 보전을 위해서도 처분금지가처분을 할 수 있다. 타인의 토지 위에 무단으로 건축된 건물의 철거의무를 지는 사람은 그 건물의 소유자 또는 그 건물이 미등기 건물인 때에는 이를 매수하여 법률상·사실상 처분할 수 있는 지위에 있는 사람인데, 점유이전금지가처분이 목적물의 처분까지 금지 또는 제한하는 것은 아니어서 건물철거청구권의 보전을 위해서는 건물과 토지에 대한 점유이전금지가처분만으로는 부족하고 건물에 대한 처분금지가처분이 필요하다(대판 1987. 11. 24. 87다카257, 258 참조).

토지거래계약 허가구역 내 토지에 관하여 체결된 매매계약에 따른 토지거래허가신청절

차청구권도 피보전권리가 된다(대판 1998. 12. 22. 98다44376). 하지만 관할관청의 허가를 받을 것을 전제로 한 매매계약은 미완성의 법률행위로서 허가받기 전의 상태에서는 아무런 효력이 없으므로, 그 매매계약에 기한 소유권이전등기청구권 또는 토지거래허가를 조건으로 한 소유권이전등기청구권을 처분금지가처분의 피보전권리로 삼을 수는 없다(대결 2010. 8. 26. 2010마818).

저당권설정계약에 따른 등기청구권, 임차권에 기한 등기청구권이나 인도청구권 등을 피보전권리로 하여 처분금지가처분을 신청할 수 있다. 저당권설정계약을 한 사람이나 임차인 등은 목적부동산에 대한 처분권을 취득할 수 없으므로 그에 기한 가처분이 가능한지에 관하여 의문이 있을 수 있다. 그러나 저당권설정계약 등에 따라 등기를 마칠 때까지는 소유자에 대하여 목적부동산의 처분금지를 구할 보전의 이익이 있고, 가처분의 효력에 관하여 후술하는 바와 같이 상대적 효력설을 따르는 이상 피보전권리의 범위 내에서만 그 효력이 인정되므로 그 가처분채권자를 필요 이상으로 보호하는 것은 아니다. 임차인이 부동산 임차권을 피보전권리로 한 처분금지가처분등기를 마친 후 그 부동산이 강제경매된 경우, 임차인이 임차권설정등기이행청구의 본안에서 승소확정판결을 받았다면, 임차권설정등기를 마쳤는지 여부에 관계없이 임차인은 임대인의 지위를 포괄승계한 경매절차에서의 매수인에 대하여 임차보증금반환을 청구할 수 있다(대판 1988. 4. 25. 87다카458).

부동산의 공유지분권자가 공유물 분할의 소를 본안으로 제기하기에 앞서 그 승소판결이 확정됨으로써 취득할 특정부분에 대한 소유권을 피보전권리로 하여 부동산 전부에 대한 처분금지가처분도 할 수 있고(대결 2002. 9. 27. 2000마6135), 다른 공유자의 공유지분
345 에 대한 처분금지가처분도 할 수 있다(대결 2013. 6. 14. 2013마396).

나. 가처분 목적물

(1) 등기된 부동산

부동산처분금지가처분은 등기된 부동산에 한하여 허용되므로 미등기 부동산과 같이 채무자의 권리가 등기되지 아니한 경우에는 그 등기를 병행하거나 선행할 수 있는 때에 한하여 처분금지가처분이 허용된다. 부동산처분금지가처분의 공시방법은 가처분등기의 기입이고, 공시방법이 수반되지 않는 가처분은 무익하기 때문이다.

부동산에 대한 소유권이전등기청구권의 양도가 부동산등기 특별조치법 2조 2항, 8조 1호에 저촉된다 하더라도 당연히 그 사법상 효력이 부정되는 것은 아니다(대판 1998. 9. 25. 98다22543). 그러나 매매로 인한 소유권이전등기청구권은 특별한 사정이 없는 이상

그 권리의 성질상 양도가 제한되고 반드시 채무자의 동의나 승낙을 받아야 양도의 효력이 생기므로(대판 2001. 10. 9. 2000다51216, 대판 2018. 7. 12. 2015다36167), 매매로 인한 소유권이전등기청구권의 양수인이 매도인을 상대로 직접 부동산처분금지가처분을 구하는 경우에는 매도인이 그 양도에 대하여 동의나 승낙을 하였는지를 심리하여야 한다.

부동산에 관하여 등기된 권리(근저당권, 전세권 등)에 관하여도 소유권에 준하여 처분금지가처분이 허용된다. 다만 임의경매절차를 막기 위한 저당권실행금지가처분은 허용되지 않는다(대결 2004. 8. 17. 2004카기93 참조).

(2) 미등기 부동산

미등기 부동산이라도 보존등기가 가능한 경우에는 가처분이 가능하다. 이 경우 가처분 발령법원에서 가처분등기의 촉탁을 하면 등기관이 직권으로 소유권보존등기를 마친 후에 가처분등기를 하는 방법으로 집행하므로 심리 단계에서 보존등기가 가능한지 아닌지를 심사하여야 한다.

신축건물로서 완공은 되었으나 사용승인이 이루어지지 않은 건물, 완공되지 않았더라도 건물로서의 실질과 외관을 갖추고 그의 지번·구조·면적 등이 건축허가 또는 건축신고의 내용과 사회통념상 동일하다고 인정되는 건물에 대하여는 부동산등기법 66조에 의하여 가처분이 가능하다(대결 2009. 5. 19. 2009마406, 대결 2011. 6. 2. 2011마224. 자세한 것은 미등기 부동산에 대한 강제집행과 부동산가압류 참조). 신축 중인 건물로서 아직 독립한 건물로 인정할 수 있는 단계에 이르지 않은 경우에는 부동산등기법 66조의 미등기 부동산으로 취급할 수 없는 것은 물론이고, 독립하여 거래의 객체가 될 수 없어 유체동산 집행의 대상으로도 되지 않으므로(대결 1995. 11. 27. 95마820 참조), 보전처분의 대상으로 삼을 수 없다.

(3) 상속등기를 하지 않은 부동산

상속등기를 하지 않은 부동산에 대한 가처분은 가처분채권자가 가처분결정을 부동산등기법 28조의 대위원인을 증명하는 서면으로 하여 대위상속등기신청을 하고, 이어서 가처분기입등기를 하는 방법에 따라 집행한다. 다만 가처분채권자가 피상속인과의 매매 등 원인행위에 의한 권리의 이전·설정등기청구권을 보전하기 위해 상속인들을 상대로 처분금지가처분신청을 하여 집행법원이 이를 인용하고, 피상속인 소유 명의의 부동산에 관하여 상속관계를 표시하여(등기의무자를 ‘망 ○○○의 상속인 ○○○’ 등으로 표시함) 가처분기입등기를 촉탁한 경우에는 상속등기를 거침이 없이 가처분기입등기를 할 수 있다(대판

1995. 2. 28. 94다23999, 등기예규 881호).

(4) 토지의 일부

1필지의 토지 중 특정 부분에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위해 그 전부에 대하여 처분금지가처분을 할 수 있는가. 토지의 분할등기가 이루어지지 않는 한 등기부상 1필지 토지의 특정된 일부분에 대한 처분금지가처분등기는 할 수 없으므로, 바로 분할등기가 될 수 있다는 등 특별한 사정이 없으면 그 1필지 토지 전부에 대한 처분금지가처분결정을 근거로 한 등기촉탁으로 그 1필지 토지 전부에 대한 처분금지가처분등기를 할 수밖에 없다(대판 1975. 5. 27. 75다190, 등기예규 881호). 다만 이 경우의 담보액은 1필지의 일부분이 아닌 처분제한이 되는 가처분 목적물 전체의 가액을 기준으로 정한다. 또한 채권자의 권리범위를 넘어서는 가처분결정으로 인하여 채무자의 손해발생 가능성이 커지는 점을 고려하여 담보액을 상향 조정할 수도 있을 것이다.

1필지 토지의 특정된 일부분에 대한 처분금지가처분신청이 가능한 경우라면 부동산목록을 다음과 같이 표시하면 되는데, 그 도면은 가처분집행을 위한 분할등기(대위등기)의 기초가 되므로 정확한 측량도면일 필요가 있다. 1필지 토지의 특정된 일부분에 대한 처분금지가처분결정이 발령되면, 채권자는 그 가처분결정을 대위원인으로 하여 대위분할등기신청을 하고 분할등기를 한 다음 곧이어 가처분의 기입등기를 할 수 있다(대판 1987. 10. 13. 87다카1093 참조).

○○시 ○○동 ○○번지 대 ○○㎡ 중 별지 도면 표시 ①, ②, ③, ④, ①의 각 점을 순차로 연결한 선내의
 ㉠부분 ○○㎡

다. 신청과 심리

(1) 신청

처분금지가처분의 신청절차는 부동산가압류에 준하여 생각하면 된다.

처분금지가처분에서의 담보액은 통상 목적물 가액의 1/10로 정하는 것이 실무이므로 채권자는 신청 시 목적물의 가액을 산출할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

(2) 심리

(가) 신청원인과 소명자료를 검토하여 피보전권리가 본안소송을 통하여 행사할 수 있는 권리이며 그 주장이 받아들여질 수 있을 정도의 소명이 있는지를 심리한다.

(나) 사해행위취소로 인한 원상회복청구권을 피보전권리로 하는 경우, 먼저 사해행위의 피보전채권이 존재하는지 심리하여야 한다. 특히 피보전채권이 사해행위 이후에 발생한 것이라면 채권성립의 기초가 되는 법률관계가 발생되어 있었는지, 가까운 장래에 그 법률관계에 기하여 채권이 성립하리라는 고도의 개연성이 있었는지에 대한 소명을 요구하여야 한다. 사해의사에 관한 소명을 위하여 채무자가 무자력이라는 점에 관한 구체적인 소명자료를 첨부하도록 하고, 채무자와 수익자 사이의 인적 관계(친척, 친지 등)에 관한 자료도 첨부하도록 하는 것이 바람직하다. 사해행위취소에 관한 민법 406조 2항의 제척기간은 직권조사사항이므로 당연히 심리범위에 속한다. 대상 부동산에 설정되어 있던 선순위저당권의 피담보채권액이 부동산의 가액을 초과하는 때에는 그 부동산의 양도는 사해행위라고 할 수 없으므로, 부동산에 수 개의 선순위저당권이 설정되어 있는 경우 피담보채권 합계액이 부동산 시가를 초과하는지 여부도 살펴보아야 한다. 한편 사해행위 후 변제 등에 의하여 저당권설정등기가 말소된 경우, 그 부동산의 가액에서 저당권의 피담보채권액을 공제한 잔액의 한도에서 사해행위를 취소하고 그 가액의 배상을 명할 수 있을 뿐이므로, 이러한 경우에는 부동산 처분금지가처분은 허용되지 아니하고 부동산가압류만이 허용된다. 따라서 등기사항증명서를 통해 사해행위 후 선순위저당권이 말소되었는지 여부를 확인해 보아야 한다. 또한 대상 부동산에 관한 경매절차에서 매수인이 매각대금을 다 낸 때에는 사해행위취소에 따른 원상회복으로서 배당금(공탁된 경우에는 공탁금)채권에 대한 지급금지가처분만 가능하고 부동산 자체의 처분금지가처분은 허용될 수 없으므로, 가처분신청 대상 부동산에 경매개시결정의 등기가 되어 있다면 그 경매진행상황을 확인해 볼 필요가 있다.

(다) 부동산 명의신탁약정은 종중이나 배우자에 관한 예외적인 경우를 제외하고는 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 4조에 따라 무효이므로, 이와 같이 무효인 명의신탁약정의 해지를 원인으로 하여서는 채무자를 상대로 소유권이전등기청구를 할 수 없다. 채권자가 부동산을 매수하면서 채무자와의 명의신탁약정에 따라 곧바로 채무자 앞으로 소유권이전등기를 마쳤다고 주장하는 경우에는, 채권자와 채무자 사이의 명의신탁약정이 계약명의신탁인지 아니면 3자간 등기명의신탁인지, 계약명의신탁이라면 매도인이 선의인지를 살피는 등으로 피보전권리의 존재 여부를 심사하여야 한다. 만약 3자간 등기명의신탁이라면 매수인은 채권자이므로, 채권자는 매도인에 대하여 매매계약에 기한 소유권이전등기청구권을 가지고 따라서 매도인을 대위하여 채무자를 상대로 무효인 명의신탁약정에 기한 소유권이전등기의 말소를 구할 수 있다. 계약명의신탁이고 매도인이 악의라면 채무자 명의의 소유권이전등기는 원인무효의 등기이지만, 매수인은 채무자이지 채권자가 아니므로

348

제3편
제9장
제1절

349

채권자와 매도인 사이에 별도의 양도약정이 없는 이상, 채권자는 매도인에 대하여 아무런 권리를 가지지 못하고 따라서 매도인을 대위하여 채무자를 상대로 가처분을 구할 수 없다(대판 2003. 9. 5. 2001다32120 참조). 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 시행(1995. 7. 1.) 전에 계약명의신탁약정이 있었고 매도인이 선의라면 채무자는 채권자에게 부동산 자체를 부당이득으로 반환하여야 하므로 이를 피보전권리로 한 가처분이 가능하나, 이러한 부당이득반환청구권에 기한 등기청구권은 채권자의 부동산 계속 점유 여부와 관계없이 10년의 기간이 경과함에 따라 시효로 소멸한다는 점을 유의하여야 한다(대판 2009. 7. 9. 2009다23313). 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 시행 이후에 계약명의신탁약정이 있었다면 채권자에게 반환하여야 할 부당이득의 대상은 부동산 자체가 아니라 부동산의 매수자금이므로 부동산가압류만 가능하고 처분금지가처분은 불가능하다(대판 2005. 1. 28. 2002다66922).

(라) 신탁부동산에 관하여 수분양자가 위탁자인 시행사를 대위하여 수탁자인 신탁회사를 상대로 신탁종료를 원인으로 한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위해 처분금지가처분신청을 하는 경우가 있는데, 통상 분양대금은 분양계약서에 기재된 신탁회사 명의의 특정계좌에 입금되어야 하는 경우가 많으므로 분양대금이 분양계약에 따라 적법하게 지급되었는지를 살펴보아야 한다. 부동산담보신탁의 경우 우선수익자는 신탁부동산의 환가를 통하여 채권의 만족을 얻을 권리가 있어, 함부로 신탁부동산의 처분금지가처분을 하면 우선수익자의 이익을 해치고 신탁의 목적에 반할 우려가 있다. 그러므로 신탁계약이 이미 종료되었거나 곧 종료될 구체적 개연성이 있다는 점에 관한 소명이 있는지도 심사하여야 한다. 350 이때 신탁계약의 내용을 파악하기 위해 해당 건물에 대한 신탁원부를 제출하게 할 필요가 있다. 한편 건물의 신축 및 분양사업에 필요한 자금을 융통하기 위하여 체결한 담보신탁계약은, 채무자가 신탁계약체결 당시 채무초과상태에 있었다고 하더라도 사해의사가 인정되지 않을 여지가 있으므로, 위와 같은 신탁계약이 사해행위라고 주장하는 경우 그 피보전권리의 인정에 좀 더 신중을 기하여야 한다(대결 2012. 10. 11. 2010마2066, 대판 2003. 12. 12. 2001다57884).

(마) 피상속인이 사망하지 아니하였음에도, 피상속인이 의식불명상태이거나 사실상 법률행위를 할 수 없는 상태이고 다른 상속인들이 임의로 상속재산을 처분할 염려가 있다는 이유로 처분금지가처분을 신청하는 경우가 있으나, 이를 허용하면 피상속인의 자유로운 처분을 상속인이 금지하는 결과가 되므로 성년후견·한정후견개시의 심판을 통한 성년후견인, 한정후견인의 선임 등 다른 해결방법에 따를 것이고, 이러한 가처분은 허용되지 않는다.

(바) 유류분반환청구권에 기한 처분금지가처분의 경우, 상속인의 수, 채권자와 다른 상속인들이 피상속인으로부터 증여, 유증, 상속받은 재산의 내역을 구체적으로 밝혀 채권자의 유류분이 침해되었다는 점을 구체적으로 소명하도록 한다. 채권자가 침해되었다고 주장하는 유류분의 지분이 신청취지의 가처분 대상과 부합하는지 살펴보고, 다른 경우에는 신청취지를 유류분 지분에 맞추어 감축하도록 보정을 명하여야 한다.

(사) 도시 및 주거환경정비법 64조, 주택법 22조, 62조 등에 따른 매도청구권 행사를 이유로 한 가처분에서는 해당 법률에서 정하고 있는 매도청구권 행사요건이 갖추어졌는지를 구체적으로 소명하도록 한다.

(아) 매매계약의 계약금만 지급된 상태에서 매수인이 처분금지가처분신청을 하는 경우가 있는데, 이러한 경우 매도인은 매매계약에 위반하여 제3자 앞으로 매매 목적부동산에 관한 소유권이전등기를 마쳐주더라도 계약금의 배액을 상환하고 매매계약을 해제할 수 있으므로, 보전의 필요성이 없다고 볼 여지가 많다. 따라서 중도금 지급 등 매매계약의 이행에 착수했다는 사정에 대한 소명을 요구하거나 계약금만 지급된 상태에서도 가처분을 할 보전의 필요성이 있다는 점에 관한 추가 소명을 요구하는 것이 바람직하다. 한편 계약금만 지급된 경우에도 보전의 필요성에 대한 소명을 엄격하게 요구하지 않고, 채권자로 하여금 현금 담보를 제공하게 한 다음 가처분을 발령하는 실무례도 있다.

라. 재판과 그 집행

(1) 재판

처분금지가처분의 공시방법은 가처분재판에 관한 사항을 등기부에 기입하는 것이므로 가처분채무자의 실제 주소와 등기부상 주소가 다른 경우에는 등기할 수 있도록 결정에 등기부상 주소를 함께 기재하는 것이 실무이다. 다만 결정에 가처분채무자의 주민등록번호를 기재하는 경우에는 동일인 인정에 문제가 없으므로 등기부상 주소를 기재하지 않아도 무방할 것이다(등기예규 1607호 참조). 가처분의 목적물 역시 등기부상의 표시와 일치되도록 하여야 한다.

통상적인 주문례는 다음과 같다.

채무자는 별지 목록 기재 부동산에 대하여 매매, 증여, 전세권·저당권·임차권의 설정 그 밖에 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.

주문 아래에는 ‘매매를 원인으로 한 소유권이전등기청구권, 채권자대위권에 기한 원인

무효의 소유권이전등기 말소등기청구권, 20〇〇.〇.〇.자 근저당권설정계약에 기한 근저당권설정등기청구권, 대지소유권에 기한 건물철거청구권' 등과 같이 등기원인과 함께 피보전권리의 내용을 기재하는 것이 실무이다. 다만 등기예규 881호에는 부동산의 처분금지 가처분등기를 하는 경우 '소유권이전등기청구권'과 같이 등기청구권의 원인은 제외하고 피보전권리를 기록한다고 규정되어 있다. 실무상으로도 법원사무관등이 가처분등기를 촉탁할 때 그 촉탁서에 피보전권리의 명칭만을 기재하고, '매매, 저당권설정계약' 등과 같은
352 피보전권리의 발생 원인은 기재하지 않고 있다(재민 2003-4 7조).

(2) 집행

부동산가압류와 마찬가지로 가처분법원이 집행법원이 되어 등기부에 처분 등을 금지한 사실을 기입하는 방법으로 집행한다. 가처분등기의 촉탁은 집행법원의 법원사무관등이 한다(민집 305조 3항, 293조). 그 양식은 [전산양식 A4781, 4781-1] 참조. 이때에는 가처분신청 시에 집행신청이 함께 있는 것으로 보아 따로 집행신청을 기다리지 않는다.

등기촉탁 시의 등록면허세액은 부동산의 가액의 1,000분의 2이며(지방세 27조 4항, 28조 1항 1호 라목), 그 세액의 100분의 20이 지방교육세액이 된다(지방세 151조 1항 2호).

마. 집행의 효력

(1) 등기와의 관계

처분금지가처분은 그 등기가 마쳐짐으로써 가처분채무자와 제3자에 대하여 구속력을 가진다. 이는 가처분결정 자체의 효력이 아니라 그 집행으로 인하여 생기는 효력이다. 따라서 채권자가 채무자를 상대로 처분금지가처분결정을 받았다고 하더라도 가처분등기가 마쳐지기 전에 채무자가 그 가처분의 내용에 위반되는 처분행위를 하여 제3자 명의로 소유권이전등기 등이 마쳐졌다면 그 등기는 완전히 유효하고 위 가처분결정은 집행불능이 된다(대판 1997. 7. 11. 97다15012 참조). 반면, 가처분 이전에 채무자의 처분행위가 있었으나 그 등기만을 가처분등기 이후에 마친 경우에는 가처분채권자에게 대항할 수 없다고 보는 것이 일반적이다. 결국 부동산에 관하여 처분금지가처분의 등기를 마친 후 가처분채권자가 본안소송에서 승소판결을 받아 확정되면 그 피보전권리의 범위 내에서 그 가처분에 저촉되는 처분행위의 효력을 부정할 수 있고, 이때 그 처분행위가 가처분에 저촉되는
353 것인지는 그 처분행위에 따른 등기와 가처분등기의 선후에 의하여 정해진다(대판 2003. 2. 28. 2000다65802, 65819).

가처분등기보다 먼저 등기된 가등기로 본등기가 마쳐진 경우에는 그 본등기가 설사 가처분등기 후에 마쳐졌다 하더라도 가처분채권자에게 대항할 수 있다.

(2) 처분금지가처분등기 후의 처분행위의 효력 및 그 범위

(가) 처분행위의 효력

처분금지가처분등기 후 채무자가 목적부동산에 관하여 가처분의 내용에 위반되는 처분행위를 하면 채권자는 그 처분행위의 효력을 부정할 수 있다. 그러나 처분금지가처분이 등기되었으나 그 가처분 당시의 가처분채무자 명의의 등기가 원인무효인 관계로 확정판결로 말소되어 전 소유자의 명의로 복귀되는 경우는 금지되는 처분행위에 해당한다고 볼 수 없다(대판 1996. 8. 20. 94다58988).

가처분채권자가 가처분 위반행위의 효력을 부정할 수 있는 시기는 본안소송에서 승소확정판결을 받거나 이와 동일시할 수 있는 사정이 발생한 때(예를 들면 화해, 조정, 청구의 인낙 등에 의하여 가처분채권자의 권리의 존재가 확정된 때)이며, 단순히 가처분채권자인 지위만으로는 가처분채무자로부터 목적부동산의 소유권이전등기를 이전받은 제3자에 대하여 말소등기를 청구하는 등 위법한 처분행위의 효력을 부인할 수 없다(대판 1992. 2. 14. 91다12349, 대판 1996. 3. 22. 95다53768).

따라서 가처분채권자의 권리가 본안에서 확정될 때까지는 가처분등기 후의 처분행위라도 등기가 허용됨은 물론이고(대판 1999. 7. 9. 98다13754 참조), 그 제3취득자는 비록 목적부동산에 관하여 처분금지가처분등기가 되어 있더라도 그 부동산이 임대된 경우에는 임차인에게 차임의 지급을 청구할 수 있으며, 가처분채무자에게 취득한 목적부동산의 인도를 구할 수 있고, 가처분채무자를 상대방으로 하는 타인의 강제집행에 대하여 제3자이익의 소를 제기할 수 있으며, 제3취득자의 채권자도 제3취득자를 채무자로 하여 목적부동산에 대하여 강제집행이나 보전처분을 할 수 있다.

한편 가처분등기 이후에 제3자가 가처분채무자를 상대로 소를 제기하여 화해권고결정 354을 받는 방법으로 소유권이전등기를 마치는 것도 가처분 위반의 처분행위로서 효력이 부정될 수 있다(대판 2012. 5. 10. 2010다2558). 또한 가처분채권자가 가처분채무자의 공유지분에 관하여 처분금지가처분등기를 마친 후에 가처분채무자가 나머지 공유자와 사이에 공유물을 경매에 붙여 매각대금을 분배하는 내용의 화해권고결정을 받아 이를 확정시켰다면, 다른 특별한 사정이 없는 한 이는 처분금지가처분에서 금하는 처분행위에 해당한다(대판 2017. 5. 31. 2017다216981).

(나) 주관적 범위

처분금지가처분에 위반한 처분행위는 가처분채권자에 대한 관계에서는 물론이고 그 밖의 모든 사람에 대한 관계에서도 항상 절대적으로 무효라는 견해(절대적 효력설)도 있으나, 판례와 통설은 위 가처분 위반의 처분행위는 가처분채무자와 그 상대방 및 제3자 사이에서는 완전히 유효하고 단지 가처분채권자에게만 대항할 수 없음에 그친다는 견해(상대적 효력설)를 취하고 있다(대판 1968. 9. 30. 68다1117, 대판 2000. 10. 6. 2000다32147 등 다수).

(다) 객관적 범위

가처분에 의한 처분금지의 효력은 가처분채권자의 권리를 침해하는 한도에서만 생기는 것이므로 가처분채권자는 피보전권리의 한도에서 가처분 위반의 효력을 부정할 수 있다. 예를 들면 저당권 또는 임차권설정등기청구권을 피보전권리로 한 처분금지가처분의 경우, 그 가처분집행 이후에 제3취득자 앞으로 소유권이전등기가 마쳐진 다음 가처분채권자가 본안소송에서 승소확정판결을 받는다고 하더라도 그 소유권이전의 효력이 전면적으로 부정되지는 않고, 단지 제3취득자는 위 저당권, 임차권의 존재를 인정한 채로 소유권을 취득하게 된다. 또한 건물철거, 토지인도청구권보전을 위한 건물에 대한 처분금지가처분등기 후에 건물의 소유권이전등기를 한 제3취득자는 소유권을 취득하지만, 건물철거와 토지인도청구권의 실현을 감수하여야 한다.

임차권자의 임차권설정등기청구권을 피보전권리로 한 처분금지가처분등기가 마쳐진 후
 355 근저당권이 설정되자 임차권자가 가처분채권자로서 그 근저당권설정등기의 말소를 구한
 사안에서, 판례는 임차권은 목적물의 사용, 수익을 내용으로 하는 권리로서 근저당권의
 존속이 임차권의 실현에 장애가 되지 않고, 가처분등기 후 설정된 근저당권이 실행되더라
 도 임차권자는 선행된 가처분등기와 임차권설정등기청구를 인용한 본안판결에 기하여 제
 3자에게 대항할 수 있으므로, 임차권자는 가처분 후 마쳐진 근저당권설정등기의 말소를
 구할 수 없다고 하였다(대결 1984. 4. 16. 84마7).

(3) 피보전권리와 의 관계

(가) 피보전권리 없이 발령된 처분금지가처분

다툼의 대상인 부동산에 관하여 실체상 아무런 권리가 없는 사람의 신청에 따라 처분금지가처분결정이 내려졌다면, 그를 근거로 한 가처분등기가 마쳐졌다 하더라도 그 가처분채권자는 가처분의 효력을 채무자나 제3자에게 주장할 수 없으므로, 그 가처분등기 후에

소유권이전등기를 마친 사람은 가처분채권자에 대하여도 유효하게 소유권을 취득하였음을 주장할 수 있다(대판 1972. 10. 31. 72다1271, 대판 1999. 10. 8. 98다38760 등). 따라서 어느 부동산 전부에 관하여 가처분이 되어 있다 하더라도 가처분 당시 그 부동산의 일부에 대해서만 피보전권리가 인정된다면 그 피보전권리 없는 부분의 가처분은 무효이므로, 그 선행 가처분 후에 그 부동산의 일부에 관하여 새로운 가처분을 받은 자라도 자신의 피보전권리가 선행 가처분채권자의 피보전권리에 저촉되지 않는 한 자신의 가처분으로 선행 가처분채권자에게 대항할 수 있고, 설사 선행 가처분채권자가 후행 가처분 후에 그 부동산에 관한 권리 전부를 취득하였더라도 선행 가처분 중 무효였던 부분이 유효한 것으로 될 수는 없다(대판 1994. 3. 11. 93다52044).

피보전권리가 없음에도 불구하고 그 권리보전이란 구실 아래 처분금지가처분결정을 받아 이를 집행한 경우에는 그 가처분에 따른 본안소송에서 그 가처분채권자와 채무자 사이에 소송상의 화해가 이루어져 그 화해조서에 기하여 가처분채권자 명의의 소유권이전등기가 경료되었다 하더라도 이를 피보전권리의 실현에 의한 등기라고 할 수는 없으므로, 그 가처분을 가지고 후에 이루어진 처분금지가처분의 권리자에게 대항할 수 없다(대판 1994. 4. 29. 93다60434).

다만 처분금지가처분신청에 의하여 가처분결정을 한 가처분 법원의 촉탁으로 가처분 목적 건물에 관하여 원시취득자 앞으로 소유권보존등기가 마쳐졌다면, 그 가처분이 피보전권리 없이 발하여진 것이라 하더라도 그 소유권보존등기는 실체관계에 부합하는 유효한 등기이다(대판 1995. 10. 13. 94다44996). 356

또한 소유권이전등기청구권보전을 위한 가등기가 사해행위로 이루어진 것이라는 이유로 그 가등기상 권리의 처분을 금지하는 가처분을 받은 채권자가 제기한 본안소송인 사해행위취소소송에서, 민법 406조 2항의 제척기간이 도과되었다고 의심할 만한 사정이 있다고 볼 여지가 있었지만, 법원이 직권으로 추가적인 증거조사를 하여 그 기간 준수 여부를 확인함이 없이 원고인 가처분채권자에 대하여 승소판결이 선고되어 확정되었다면, 특별한 사정이 없는 한 그 가처분에 반하는 권리를 취득한 제3자는 가처분채권자에게 대항할 수 없다(대판 2015. 7. 23. 2014다205768 참조).

반면, 당초 유효한 피보전권리를 근거로 하여 처분금지가처분등기가 마쳐졌다고 하여도 나중에 그 가처분신청이 취하 또는 처분금지가처분결정이 취소되는 등으로 그 가처분등기가 적법하게 말소되거나 가처분채권자가 본안소송에서 패소 확정되어 그 가처분이 취소당할 운명에 있게 되면 위 가처분등기 이후에 마친 소유권이전 또는 저당권설정등기는 완전

히 유효하게 된다(대판 1976. 4. 27. 74다2151, 대판 2000. 10. 6. 2000다32147 등).

(나) 부동산 순차 매도의 경우 처분금지가처분의 효력

가처분등기 후에 그 피보전권리를 실현하는 내용의 등기가 마쳐진 경우, 그 등기는 완전히 유효하다는 것이 판례의 계속된 태도이다(대판 1991. 4. 12. 90다9407 등 다수).

부동산의 전득자(채권자)가 양수인 겸 전매인(채무자)을 대위하여 양도인(제3채무자)을 상대로 처분금지가처분결정을 받아 그 등기를 마친 경우 그 가처분 이후에 양수인이 양도인으로부터 소유권이전등기를 넘겨받았고 이에 더 잡아 다른 등기가 마쳐졌다고 하여도 그 각 등기는 위 가처분의 효력에 위배되는 것이 아니다(대판 1989. 4. 11. 87다카3155, 대판 1994. 3. 8. 93다42665). 그 가처분은 전득자가 자신의 양수인에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 양도인이 양수인 이외의 자에게 그 소유권의 이전 등 처분 행위를 못하게 하는 데에 그 목적이 있는 것으로서 그 피보전권리는 양수인의 양도인에 대한 소유권이전등기청구권이고, 전득자의 양수인에 대한 소유권이전등기청구권까지 포함되는 것은 아닐 뿐만 아니라 그 가처분결정에서 제3자에 대한 처분을 금지하였다고 하여도 그 제3자 중에는 양수인은 포함되지 않기 때문이다.

또한 채권자가 사해행위의 수익자를 상대로 사해행위취소에 따른 소유권이전등기 말소등기청구권을 피보전권리로 하여 부동산처분금지가처분결정을 받고, 수익자로부터 채무자에게 소유권이전등기가 이루어진 경우에는, 채무자로부터 다시 새로운 제3자에게 소유권이전등기가 이루어졌다고 하더라도 제3자로의 처분행위가 새로운 사해행위가 됨은 별론으로 하고, 채무자 명의로의 소유권이전등기, 제3자 명의로의 소유권이전등기는 위 가처분의 효력에 위배되는 것이 아니어서 유효하다.

반면에, 부동산이 甲→乙→丙→丁 순으로 순차 매도된 경우에 丁이 丙, 乙을 순차 대위하여 甲을 상대로 처분금지가처분을 하였는데 甲으로부터 丙 앞으로 중간생략의 소유권이전등기가 마쳐진 경우 이 등기는 처분금지가처분에 위배되어 丁에게 대항할 수 없다(대판 1998. 2. 13. 97다47897).

바. 다른 절차와의 경합

(1) 다른 가처분과의 경합

가처분은 그 내용이 다양하므로 상호 모순·저촉되지 않는 범위 내에서만 경합이 허용된다. 수 개의 가처분이 서로 모순·저촉되는지의 여부는 당사자, 피보전권리, 보전의 필요성, 주문 또는 신청취지 등을 비교하여 판단한다.

(2) 가압류와의 경합

부동산 소유권에 대한 가압류 부분 참조.

(3) 강제집행과의 경합

358

처분금지가처분이 되어 있는 부동산에 대하여도 본안에 관한 승소판결 확정 시까지는 다른 채권자가 강제집행을 할 수 있다. 이처럼 강제집행이 허용되는 경우 가처분과의 우열은 어떻게 되는가. 이에 관하여 판례는 처분금지가처분이 되어 있는 부동산에 대한 강제집행은 적법 유효하고, 강제집행의 진행 중에 가처분의 존재만으로는 제3자이익의 소를 제기할 권한이 없으며(대판 1992. 2. 14. 91다12349 참조), 가처분채권자가 후에 본안소송에서 승소확정판결을 얻는 때에 비로소 그 강제집행의 결과를 부인할 수 있음에 불과하다고 한다(대판 1998. 10. 27. 97다26104). 실무상으로는 최선순위의 처분금지가처분이 있는 부동산에 관하여는 경매개시결정을 하고 이를 등기한 다음 경매절차를 사실상 정지하여 가처분 본안소송의 결과를 기다리는 것이 일반적이다.

강제집행으로 이미 압류된 부동산에 대하여도 처분금지가처분을 할 수는 있으나, 가처분채권자는 매수인에게 대항할 수 없다(대판 1964. 12. 15. 63다1071).

(4) 체납처분과의 경합

선행하는 가처분과 체납처분과의 관계에 관하여는 체납처분우위설과 가처분우위설이 대립하고 있는데, 후자가 통설·판례이다. 판례는 부동산에 관하여 처분금지가처분의 등기가 된 후에 그 가처분채권자가 본안소송에서 승소판결을 받아 확정되면 그 피보전권리의 범위 내에서 가처분 위반행위의 효력을 부정할 수 있고 이와 같은 가처분의 우선적 효력은 그 위반행위가 체납처분을 근거로 한 것이라 하여 달리 볼 수 없고, 국세징수법 35조에서 “재판상의 가압류 또는 가처분 재산이 체납처분 대상인 경우에도 이 법에 따른 체납처분을 한다.”고 규정하고 있으나 이는 선행의 가압류 또는 가처분이 있다고 하더라도 체납처분의 진행에는 영향을 받지 않는다는 취지의 절차 진행에 관한 규정일 뿐이고 체납처분의 효력이 가압류, 가처분의 효력에 우선한다는 취지의 규정은 아니라고 한다(대결(전) 1993. 2. 19. 92마903]. 이와 같은 법리는 지방세징수법 45조에도 그대로 적용된다.

359

사. 가처분채권자의 본안승소와 피보전권리의 등기절차

부동산처분금지가처분 채권자가 본안사건의 승소확정판결(또는 이와 동일시할 청구인

낙이나 조정, 화해조서 등)을 받으면, 그 확정판결 정본 등을 첨부하여 가처분채무자를 등기의무자로 한 피보전권리의 등기를 신청할 수 있다.

또한 가처분의 등기가 마쳐진 후에 가처분채권자가 가처분채무자와 공동으로 가처분의 근거가 되는 실체적 법률관계에 기하여 소유권이전등기 또는 소유권이전등기말소등기를 마친 경우에는 가처분채권자는 피보전권리의 한도에서 가처분 위반의 처분행위의 효력을 부정할 수 있는바(대판 2012. 5. 10. 2010다2558), 이 경우 가처분채권자는 등기신청이 가처분에 기한 것이라는 소명자료를 첨부하여야 한다(등기예규 1412호). ‘가처분에 기한 것이라는 소명자료’란 그 소유권이전등기가 당해 가처분의 피보전권리를 실현하는 내용임을 소명하는 자료로서 가처분등기 이후에 작성된 원인증서는 이에 해당되지 않는 것이 원칙이나, 그 원인증서가 당해 가처분에 의하여 보전하려는 청구권의 실현을 위하여 작성되었고 그 피보전권리와 동일성이 인정되는 경우에는 이에 해당한다(대결 2014. 3. 28. 2012마103).

위와 같이 가처분채권자가 피보전권리의 등기를 신청하는 경우에는 가처분등기 이후에 된 등기로서 가처분채권자의 권리를 침해하는 등기의 말소를 신청할 수 있다(부등 94조 1항). 그 구체적 절차는 아래와 같다.

(1) 피보전권리가 소유권이전등기청구권인 경우

(가) 당해 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의 소유권이전등기의 말소

가처분채권자의 소유권이전등기를 마치기 위해서는 이에 저촉되는 제3자 명의의 소유권이전등기를 말소해야 한다. 이 경우 등기관이 직권으로 말소할 수 없고 가처분채권자가 소유권이전등기신청과 함께 그 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의 소유권이전등기의 말소신청도 동시에 하면 그 가처분등기 이후의 소유권이전등기를 말소하고 가처분채권자의 소유권이전등기를 하게 된다.

가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 소유권이전등기가 가처분등기에 우선하는 저당권 또는 압류를 근거로 한 경매절차에 따른 매각을 원인으로 하여 이루어진 것인 때에는 가처분채권자의 말소신청이 있다 하더라도 이를 말소할 수 없다(등기예규 1412호).

(나) 당해 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 소유권이전등기 이외 등기의 말소

가처분등기 이후에 제3자 명의의 가등기, 소유권 이외의 권리에 관한 등기, 가압류등기, 국세체납에 의한 압류등기, 경매개시결정등기 및 처분금지가처분등기 등이 마쳐져 있을 때에는 가처분채권자가 소유권이전등기신청과 함께 제3자 명의의 등기말소신청도 동시에 하여 이를 말소하고 가처분채권자의 소유권이전등기를 하거나, 제3자 명의 등기의 말소를

동시에 신청하지 아니하였다면 채권자 명의의 소유권이전등기가 된 이후라도 그 이전등기가 가처분을 근거로 한 등기였다는 소명자료를 첨부하여 말소를 신청할 수 있다.

다만 가처분등기 전에 마친 가압류에 의한 강제경매개시결정등기와 가처분등기 전에 마친 담보가등기, 전세권 및 저당권에 의한 임의경매개시결정등기 및 가처분채권자에 대항할 수 있는 임차인 명의의 주택임차권등기, 주택임차권설정등기, 상가건물임차권등기 및 상가건물임차권설정등기 등은 가처분채권자의 소유권이전등기와 양립할 수 있으므로 말소할 수 없다(등기예규 1412호).

(2) 피보전권리가 소유권이전등기(소유권보존등기 포함. 이하 같음) 말소등기청구권인 경우

(가) 당해 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의 소유권이전등기의 말소

가처분채권자가 소유권이전등기의 말소등기신청과 동시에 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 소유권이전등기의 말소도 신청하여 가처분등기 이후의 이전등기를 말소하고 가처분을 근거로 한 소유권이전등기의 말소등기를 한다(등기예규 1412호).

(나) 당해 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 소유권이전등기 이외 등기의 말소 361

가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 소유권이전등기를 제외한 가등기, 소유권 이외의 권리에 관한 등기, 가압류등기, 국세채납에 의한 압류등기, 경매개시결정등기와 처분금지처분등기 등이 마쳐져 있을 때에는 가처분채권자가 소유권이전등기의 말소등기신청과 함께 그 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 등기말소신청도 동시에 하여 그 가처분등기 이후의 등기를 말소하고 가처분채무자 명의의 소유권이전등기를 말소하여야 한다.

다만 가처분등기 전에 마친 가압류에 의한 강제경매개시결정등기와 가처분등기 전에 마친 담보가등기, 전세권 및 저당권에 의한 임의경매개시결정등기 및 가처분채권자에 대항할 수 있는 임차인 명의의 주택임차권등기, 주택임차권설정등기, 상가건물임차권등기 및 상가건물임차권설정등기 등이 가처분등기 이후에 마쳐진 때에는 그러하지 아니하다. 이 경우 가처분채권자가 가처분채무자의 소유권이전등기의 말소등기를 신청하기 위해서는 위 권리자의 승낙이나 이에 대항할 수 있는 재판이 있음을 증명하는 정보를 제공하여야 한다(등기예규 1412호).

(3) 피보전권리가 소유권 이외의 제한물권인 경우

(가) 가처분등기 이후에 마쳐진 등기가 소유권이전등기인 경우

가처분 후의 제3취득자의 소유권 취득은 그 피보전권리를 실현하는 한도 내에서만 제한

을 받는 것이므로 제3취득자의 권리는 전부 부정되는 것이 아니고, 다만 가처분채권자의 제한물권을 승인하면 충분할 것이므로 그 등기를 말소하지 않아도 된다. 이 경우 가처분채권자는 본안승소 확정판결 등을 근거로 하여 곧바로 가처분채무자를 등기의무자로 하여 단독으로 그 피보전권리인 저당권설정등기 등을 신청할 수 있고, 제3취득자는 가처분의 효력으로서 가처분채무자가 등기의무자로서 피보전권리인 저당권설정등기 등을 하는 것을 감수하지 않으면 안 된다(등기예규 1413호 참조).

362 (나) 소유권이전등기 이외의 등기인 경우

1) 원칙

가처분채권자의 권리와 양립할 수 있는지에 의하여 말소 여부를 결정한다. 즉 가처분등기 이후에 제3자가 취득한 소유권 이외의 권리가 가처분채권자의 피보전권리와 양립할 수 있다면, 그 피보전권리를 선순위의 권리로서 승인하는 것으로 족하고 위 제3자 명의 등기를 말소할 필요는 없다.

2) 피보전권리가 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 권리(지상권, 전세권, 임차권, 주택임차권, 상가건물임차권, 다만 지역권은 제외)인 경우

가처분등기 이후에 가처분채권자의 사용·수익권과 양립할 수 없는 제3자 명의의 용익물권설정등기, 임차권·주택임차권·상가건물임차권의 설정등기 또는 주택임차권등기나 상가건물임차권등기가 마쳐져 있는 때에는, 가처분채권자가 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의 등기의 말소신청도 동시에 하여 이를 말소하고 가처분채권자의 등기를 하여야 한다. 다만 가처분채권자에게 대항할 수 있는 임차인 명의의 주택임차권등기, 주택임차권설정등기, 상가건물임차권등기, 상가건물임차권설정등기가 가처분등기 이후에 마쳐져 있는 경우에는 가처분채권자의 권리가 우선하지 못하므로 가처분을 근거로 한 설정등기신청을 하려면 먼저 소송 등 별도의 방법으로 대항력 있는 주택임차권등기 또는 주택임차권설정등기의 말소등기 절차를 선행하여야 한다.

반면, 가처분채권자의 사용·수익권과 양립할 수 있는 제3자 명의의 등기, 예를 들면 가등기, 가압류, 국세채납에 의한 압류등기, 처분금지가처분등기, 저당권 등은 가처분등기 이후에 마쳐진 것이라도 이를 말소하지 않는다(등기예규 1413호).

3) 피보전권리가 저당권, 지역권인 경우

피보전권리가 저당권인 경우 가처분 이후에 제3자가 어떠한 권리를 취득하여도 저당권과 양립할 수 있으므로, 그 저당권의 존재를 인정하는 것 이외에는 권리취득에 아무런 장애가 없다. 또한 지역권자는 승역지(承役地)를 독점적으로 이용할 수 없고 승역지 소유자

는 지역권의 부담을 수인한 채 자신의 토지를 계속 사용·수익할 수 있으므로, 지역권의 경우도 저당권의 경우와 마찬가지로의 결과가 된다. 따라서 처분금지가처분에 기하여 저당권설정등기 또는 지역권설정등기를 하는 경우에는, 그 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 등기는 이를 말소하지 않는다(등기예규 1413호). 363

(다) 소유권 외의 피보전권리 실현을 위한 등기 방법

저당권 등 소유권 외의 권리의 설정등기청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분의 등기 후 그 피보전권리 실현을 위한 저당권 등의 설정등기를 하는 때에는 가처분등기 후에 등기된 권리의 취득이나 처분의 제한으로 가처분채권자의 저당권 등의 취득에 대항할 수 없다는 점을 표시하기 위하여 그 등기의 목적 아래에 “○○년 ○월 ○일 접수 제○○○호 가처분에 기함”과 같은 방식으로 그 설정등기가 가처분에 기초한 것이라는 뜻도 함께 등기하게 되어 있고(부등 95조, 등기예규 1413호), 이와 같이 가처분의 피보전권리 실현을 위한 등기가 되면 그 후 가처분등기가 말소되더라도 여전히 가처분등기 후에 등기된 권리의 취득이나 처분의 제한으로 가처분채권자의 저당권 취득에 대항할 수 없다(대판 2015. 7. 9. 2015다202360 참조).

(4) 당해 가처분등기의 말소

가처분채권자의 신청에 따라 등기관이 가처분등기 이후의 등기를 말소하였을 때에는 등기관은 직권으로 그 가처분등기도 말소하여야 한다(부등 94조 2항 전단, 등기예규 1412, 1413호).

가처분등기 이후의 등기가 없는 경우로서 가처분채무자를 등기의무자로 하는 권리의 이전, 말소 또는 설정의 등기만을 할 때에도 또한 같다(부등 94조 2항 후단).

2. 점유이전금지가처분

가. 피보전권리

부동산에 대한 인도청구권을 보전하기 위한 다툼의 대상에 관한 가처분의 일종으로서, 목적물의 주관적(인적), 객관적(물적) 현상변경을 금지하고자 함을 목적으로 한다. 364

민사소송법은 당사자 승계주의를 취하고 있어 변론종결 전의 승계인에게는 판결의 효력이 미치지 아니하므로 인도청구의 본안소송 중 목적물의 점유가 이전되면 그대로 본안소송에서 패소할 수밖에 없고, 따라서 새로이 그 제3자를 상대로 하여 소를 제기하든가 아니면

1) 주관적

민사소송법 82조 등에 의하여 위 제3자에게 소송을 인수시켜 소송을 유지할 수밖에 없다. 그러나 점유이전금지가처분을 받아 두면 그 이후에 점유를 이전받은 사람은 가처분채권자에게 대항할 수 없고, 당사자가 항정되므로 위와 같은 불측의 손해를 예방할 수 있다.

또한 이 가처분은 가처분집행 당시 목적물의 현상을 본집행 시까지 그대로 유지함을 목적으로 한다. 즉 목적물에 관하여 객관적 현상변경(물리적 변경)이 이루어지면 채권자가 승소의 확정판결을 얻어도 변경 후의 목적물의 현상이 판결에서 표시된 물건과 동일성을 잃을 정도의 것이면 그 판결에 기초한 강제집행은 불능이 되고, 동일성을 잃을 정도까지는 되지 않는다 하더라도 집행에 더 큰 비용이 필요하게 되는 등 강제집행이 곤란하여질 염려가 있으며, 채무자가 본안소송에서 토지, 건물 등의 목적물에 변경을 가하고는 이를 이유로 비용상환청구권(민 203조) 등의 행사에 의한 유치권항변을 할 가능성도 있으므로, 이를 방지하기 위해서도 점유이전금지가처분이 필요하다.

피보전권리가 되는 인도청구권은 채무자에게 대항할 수 있는 한 물건에 근거한 것이든 채권(임차권 등)에 근거한 것이든 관계없다.

토지 소유자는 그 지상에 무단으로 건축된 건물 소유자에 대하여 건물의 철거와 그 대지 부분의 인도를 청구할 수 있을 뿐, 자기 소유의 건물을 점유하고 있는 자에게 그 건물에서 퇴거할 것을 청구할 수는 없으므로(대판 1999. 7. 9. 98다57457, 57464), 건물 소유자를 상대로 한 건물에 대한 점유이전금지가처분은 허용되지 않는다. 따라서 이때에는 대지에 대한 점유이전금지가처분과 함께 건물에 대한 처분금지가처분을 신청하여야 한다(대판 1987. 11. 24. 87다카257, 258 참조). 다만 토지 소유자는 위와 같이 무단으로 건축된
365 건물의 임차인 등 소유자 아닌 점유자에 대하여는 퇴거청구권을 가지므로 건물에 대한 점유이전금지가처분이 허용된다.

차임 연체를 이유로 한 임대차계약의 해지를 원인으로 점유이전금지가처분을 구할 경우, 차임 연체를 증명할 소명자료(예컨대 채권자가 채무자로부터 차임을 지급받기로 한 계좌의 통장 사본 등)가 제출되었는지 살펴볼 필요가 있다. 또한 상가건물 임대차보호법 10조의8이 적용되는 상가에 관한 임대차계약의 경우 3기 이상의 차임을 연체하여야 해지할 수 있음을 주의하여야 한다. 임대차기간이 기간 만료로 종료되었음을 이유로 하는 경우, 상가건물 임대차보호법상 갱신요구권을 행사할 수 있는 기간이 아닌지 살펴보아야 한다.

저당부동산의 사용수익권은 저당권설정자에게 있으므로 저당권은 원칙적으로 점유이전금지가처분의 피보전권리가 될 수 없다. 그러나 저당부동산의 점유자가 저당부동산을 물리적으로 멸실·훼손하거나 저당부동산에 대한 점유가 저당부동산의 본래의 용법에 따른 사용·

수익의 범위를 초과하여 그 교환가치를 감소시키는 경우, 점유자에게 저당권의 실현을 방해하기 위하여 점유를 개시하였다는 점이 인정되는 경우 등, 그 점유로 인하여 정상적인 점유가 있는 경우의 매수가격과 비교하여 그 가격이 하락하거나 경매절차가 진행되지 않는 등 저당권의 실현이 곤란하게 될 사정이 있다면, 저당권자는 저당권에 기한 방해배제청구권에 기하여 또는 소유자의 방해배제청구권을 대위하여 점유자를 상대로 저당부동산에 대한 인도청구를 할 수 있고, 이러한 인도청구권을 피보전권리로 하여 점유이전금지가처분을 신청할 수도 있다(대판 2005. 4. 29. 2005다3243, 대판 2006. 1. 27. 2003다58454 등 참조).

나. 보전의 필요성

점유이전금지가처분에서의 보전의 필요성이란 채무자가 목적물에 대한 물적 현상을 변경하거나 점유를 이전할 우려가 있어 미리 가처분을 해두지 않으면 현상변경으로 채권자가 인도청구권을 실행하지 못하거나 이를 실행하는 것이 매우 곤란할 염려가 있는 것을 말한다.

앞서 본 바와 같이 이 가처분은 당사자 항정을 통해 민사소송법이 취하고 있는 당사자 승계주의의 단점을 보완할 수 있어, 실무상 처분금지가처분과 함께 가장 많이 이용되고 있고, 통상 집행관에게 보관을 명할 뿐 채무자의 사용을 금지하지 않으므로 그 집행 때문에 채무자가 받는 불이익이 적다. 따라서 다른 가처분에 비하여 보전의 필요성을 상당히 완화하여 해석하고 있는 경향이다. 366

다만 실무상 영업용 건물에 관하여, 임차인이 제3자에게 점유를 이전할 태세를 취하지 아니함에도 임대차계약 직후에 임대인이 임차인을 상대로 점유이전금지가처분을 구하는 경우가 있는데, 임차인이 점유를 이전하면 임대인은 소유자로서 제3자를 상대로 언제든지 인도청구를 할 수 있는 점, 가처분집행에 의하여 집행관이 건물에 공시서를 부착하기 때문에 임차인의 정상적인 영업에 지장을 줄 수도 있는 점 등을 고려하여 보전의 필요성 인정에 신중을 기하여야 한다. 이와 달리, 임대차계약 기간 종료가 임박한 경우, 임대인과 임차인 사이에 계약기간, 계약갱신 여부, 비용상환청구권의 존부 등에 관하여 다툼이 있는 경우, 임대인이 소유자가 아니라서 임차인이 점유를 이전하면 새로운 점유자에게 인도를 구할 수 없게 되는 경우 등에는 보전의 필요성이 좀 더 쉽게 인정될 것이다.

임대차종료 시의 인도를 위한 제소전화해가 있는 경우에는 실무상 제소전화해의 인도권원을 소유권으로 명시한 경우는 물론, 인도권원을 소유권으로 명시하지 않은 경우에도 제소전화해의 신청원인에 임대인이 소유자라는 사실을 명시한 경우에는 제소전화해 이후에

점유를 승계한 자에 대하여 승계집행문을 부여하고 있는 것이 다수의 실무이므로 제소전 화해와 별도로 점유이전금지가처분을 인정할 보전의 필요성이 없다.

한편 경매절차에서 부동산인도명령이 발령된 경우에도 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성이 인정되지 않는다. 따라서 경매를 통해 부동산을 취득하였음을 이유로 점유이전금지가처분을 신청하는 경우 인도명령의 신청 여부, 인도명령에 의한 집행의 불능 여부 등에 대하여 소명하여야 한다. 부동산인도명령 발령 전이라면 보전의 필요성이 인정될 수 있을 것이다.

승계집행 가능
하므로

367 다. 신청

가처분신청을 할 때에는 목적부동산을 명백히 특정하여야 한다. 가처분집행에 등기가 필요하지 않으므로 미등기 부동산도 목적물이 될 수 있다.

부동산 일부를 목적물로 삼을 때에는 도면, 사진 등으로 그 대상을 특정하여야 한다. 특정의 정도는 가처분의 범위를 정할 수 있는 정도면 충분하므로 정확한 측량도면을 첨부할 필요는 없다. 간혹 채무자가 점유하는 부분을 정확히 알 수 없다고 주장하면서 건물 전체에 관한 점유이전금지가처분을 구하는 경우가 있으나 공동점유에 있어서 점유 부분을 구체적으로 구분하기 어려운 경우와 같이 예외적인 경우가 아닌 한 허용하지 않는 것이 실무이다.

채무자가 부동산을 계속 사용하도록 하는 형태의 점유이전금지가처분의 담보공탁금은 통상 목적물 가액의 1/20로 정하는 것이 실무이므로 채권자는 신청 시 목적물 가액을 계산할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다(한편 임대차와 관련된 부동산점유이전금지가처분의 경우 '임대차보증금+월차임×100'의 방법으로 계산한 금액을 목적물의 가액으로 하는 것이 실무이다).

라. 주문례

(1) 기본형

1. 채무자는 별지 목록 기재 부동산에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
2. 집행관은 현상을 변경하지 아니할 것을 조건으로 하여 채무자에게 이를 사용하게 하여야 한다.
3. 채무자는 그 점유를 타인에게 이전하거나 또는 점유명의를 변경하여서는 아니 된다.
4. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

위 주문례 중 일부를 빠뜨리거나 제2문을 “집행관은 … 채무자에게 이를 사용하게 할 수 있다.”와 같이 집행관에게 사용허락 여부에 관한 재량을 주는 식으로 기재한 신청취지의 경우, 보정명령 등을 통하여 정정하도록 하여야 한다.

제2문을 생략하게 되면 점유이전금지가처분이 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 일 368
종인 채무자의 점유사용을 배제하는 사용금지가처분 또는 인도단행가처분과 같은 것이 되는데, 양자는 심리방식, 소명의 정도, 담보액의 정도 등을 달리하므로 주의하여야 한다.

(2) 응용형

(가) 점유이전금지가처분은 단순한 점유이전·현상변경의 금지 외에 부수적인 다른 목적을 첨가해 신청되기도 하며, 이때에는 점유이전금지가처분의 기본적 주문례에 부가되는 각 목적에 따른 주문이 덧붙여진다. 즉 채무자에게 사용을 허용하여야 한다는 문구 다음에 “채무자는 이 사건 토지 위에 건물이나 그 밖에 공작물을 건축하여서는 아니 된다.” 또는 “채무자는 이 사건 토지 위에 건축 중인 건물에 관하여 건축공사를 중지하고 이를 계속하여서는 아니 된다.” 또는 “집행관은 채무자에게 건축공사 중인 건물의 완성을 허용한 다음 채무자에게 이를 사용하게 하여야 한다.”고 기재하기도 한다. 다만 건축공사금지와 같은 주문이 부가되는 경우, 이는 원칙적으로 심문이 필요한 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 성격을 가진다고 할 것이다.

그리고 이 가처분에 있어서 “이 가처분명령 위반의 행위가 있는 때에는 집행관은 이의 제거를 위하여 적당한 처분을 할 수 있다.”든가 “채무자가 현상을 변경하면 집행관은 채무자의 사용을 금지하고 목적물을 직접 보관하여야 한다.”는 등의 조항을 부가하여 객관적 현상변경이 있는 경우 집행관이 이 가처분명령으로 위반 물건의 제거 또는 채무자의 퇴거 강제를 할 수 있는가의 문제가 있으나, 이러한 위반의 제거는 민사집행법 260조, 262조에 따라 채무자를 심문한 다음에 하여야 하므로 가처분법원이 처음부터 가처분명령에 이러한 처분을 명하는 것은 타당하지 않다.

(나) 때에 따라서는 채무자의 사용을 허용하지 않고 집행관 보관만을 명하거나 더 나아가 채권자의 사용을 허용하는 수도 있다. 그러나 이와 같은 주문은 실질적으로 인도의 단행을 명하는 단행가처분과 같은 것이므로 신중히 하여야 하며, 집행관 보관·채권자 사용 369
의 가처분을 할 때에는 원칙적으로 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 한다(민집 304조).

마. 집행과 그 효력

채권자가 가처분결정 정본을 가지고 집행관에게 집행을 위임함으로써 집행한다. 집행관은 채권자, 채무자 또는 그 대리인이 참여한 상태에서 목적물이 집행관의 보관 하에 있음을 밝히는 공시를 목적물의 적당한 곳에 붙이고 채무자에게 가처분의 취지를 알림으로써 집행을 한다.

이 공시는 집행관 보관의 효력발생· 존속요건이 아니고 또한 대항요건도 아니다. 단지 제3자의 개입으로 인한 집행상태의 침해나 효과의 감소를 방지하고, 나아가 본안판결의 집행으로 불이익을 입을 수 있다는 사실을 제3자에 알리는 데 그 목적이 있다. 다만 이 공시를 손괴하면 형법 140조 등이 적용된다.

집행관이 집행을 하면 집행조서를 작성한다. 집행조서와 공시의 양식은 집행관사무소에 비치할 각종 문서의 양식에 관한 예규(행정예규 1200호) 참조.

통상의 점유이전금지가처분은, 가처분집행 당시 목적물의 현상을 본집행 시까지 그대로 유지함을 목적으로 하여 그 목적물의 점유이전과 현상의 변경을 금지하는 것에 불과하므로, 이러한 가처분결정이 있었음에도 점유가 이전되었을 때에는 가처분채무자는 가처분채권자에 대한 관계에서 여전히 그 점유자의 지위에 있는 것으로 취급되는 것일 뿐 가처분집행만으로 소유자에 의한 목적물의 처분을 금지 또는 제한하는 것은 아니다. 따라서 점유이전금지가처분의 대상이 된 목적물의 소유자가 그 의사를 근거로 하여 가처분채무자에게 직접점유를 하게 한 경우에는 그 점유에 관한 현상을 고정하는 것만으로 소유권이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 할 수 없고, 소유자의 간접점유권이 침해되는 것도 아니므로 간접점유자에 불과한 소유자는 직접점유자를 가처분채무자로 하는 점유이전금지가처분의 집행에 대하여 제3자이의의 소를 제기할 수 없다(대판 2002. 3. 29. 2000다33010).

370 바. 가처분의 경합

(1) 가처분은 그 내용이 다양하므로 상호 모순·저촉되지 않는 범위 내에서만 경합이 허용된다. 수 개의 가처분이 서로 모순·저촉되는지는 당사자, 피보전권리, 보전의 필요성, 주문 또는 신청취지 등을 비교하여 판단한다. 예를 들면 甲의 乙에 대한 건물의 집행관 보관, 채무자 甲의 점유이전금지가처분과 丙의 甲에 대한 건물철거 및 乙에 대한 건물퇴거의 가처분은 경합될 수 있다.

(2) 동일 건물에 대하여 甲의 채무자 乙을 상대로 한 집행관 보관, 채무자 乙 사용의 점유

이전금지가처분(제1차 가처분)이 집행된 후에, 丙의 채무자 丁을 상대로 한 집행관 보관, 채무자 丁 사용의 점유이전금지가처분(제2차 가처분)이 다시 발령되어 집행되었을 경우는 어떠한가. 판례에 의하면, 제2차 가처분의 집행은 불허되어야 하고 만일 집행되었다면 제1차 가처분채권자는 실체법상의 권리를 근거로 하여 제3자의의 소를 제기하거나 집행에 관한 이의로써 제2차 가처분의 집행 배제를 구할 수 있다(대결 1981. 8. 29. 81마86).

(3) 甲의 채무자 乙을 상대로 한 점유이전금지가처분(제1차 가처분)이 집행된 후에, 丙이 다시 乙을 상대로 같은 건물에 대한 점유이전금지가처분(제2차 가처분)을 구하는 경우에 관하여, ① 제2차 가처분집행은 불가능하다는 견해, ② 가처분의 경합은 인정하나 먼저 가처분집행을 한 채권자의 권리가 우선한다는 견해, ③ 제1차 가처분이 집행관 보관, 채무자 사용형이고 제2차 가처분이 집행관 보관만을 구하는 경우 경합을 인정하고 그 반대의 경우에는 인정할 수 없다는 견해, ④ 경합을 인정하지 아니할 경우 인도의무를 부담하는 채무자가 제3자를 내세워 허위의 점유이전금지가처분을 집행하여 두기만 하면, 진정한 채권자는 점유이전금지가처분을 받을 길이 없어져 버린다는 점에서 부당하므로, 가처분의 선후를 불문하고 먼저 본안소송에서 집행권원을 얻은 채권자가 우선한다는 견해 등으로 나누어지고 있으나, ④의 견해가 타당하다.

(4) 채권자가 점유이전금지가처분결정(제1차 가처분)을 받아 그 집행을 마쳤으나, 제1차 가처분에서 점유자를 잘못 지정하였다며 다른 채무자를 상대로 같은 목적물에 대한 제2차 가처분을 구하는 경우에는, 채권자가 먼저 제1차 가처분의 집행취소신청을 하는 등의 절차를 밟지 않는 이상 이를 허용하여서는 안 된다는 견해가 있다. 다만 제1차 가처분이 실제 점유자를 상대로 한 것이 아니라서 집행불능된 경우에는 별도의 조치 없이 실제 점유자를 상대로 한 제2차 가처분을 발령하여도 무방할 것이다.

(5) 채권자가 목적물의 점유자를 확정할 수 없어, 처음부터 여러 명의 채무자를 공동채무자로 하여 점유이전금지가처분을 신청하는 경우가 있다. 이 경우 점유의 사실이 소명되지 않는 채무자에 대한 신청은 기각하여야 할 것이므로 채권자에게 점유자를 특정하여 나머지 채무자에 대한 신청은 취하하도록 보정을 명하기는 하나, 실제 점유자가 아닌 자를 상대로 점유이전금지가처분이 발령된다고 하더라도 이로 인하여 점유하지 않고 있는 채무자가 특별한 불이익을 볼 염려는 없으므로, 현재 점유자를 확정지을 수 없는 불가피한 사정이 소명되고 채무자들 사이에 공동점유 내지는 간접점유관계의 가능성이 소명되는 경우에는, 지나치게 많은 잠정적인 채무자를 상대로 신청을 하는 것이 아닌 이상 이러한 채권자의 신청을 받아주는 것이 실무이다.

사. 현상변경 시의 조치

(1) 객관적 현상변경의 경우

(가) 의의

기본형의 점유이전금지가처분이 있으면 채무자는 목적물의 객관적 현상변경을 할 수 없다. 어느 정도까지의 현상변경이 객관적 현상변경으로 허용되지 않는 것인가는 가처분의 목적과 관련하여 구체적으로 결정할 수밖에 없는데, 목적물인 건물을 증·개축하여 동일성을 상실하게 하는 것, 동일성은 상실하지 않더라도 과도한 유익비의 상환의무를 부담시키는 것, 본래의 용도에 맞지 않게 고치는 것 등과 나대지 상에 건물을 축조하는 것, 임야를 개간하여 대지로 조성하는 것 등은 현상변경에 해당하나, 단순히 목적물의 현상을 보존하기 위하여 수선한다거나 점포 등의 내부 장식을 바꾸는 정도 등은 현상변경에 해당하지 않는다.

(나) 원상회복의 가부와 방법

채무자가 가처분에 위반하여 목적물의 현상을 객관적으로 변경한 경우 집행관이 채무자에 대하여 원상회복을 경고하는 것은 가능하다.

문제는 채무자가 이러한 집행관의 경고에 따르지 아니할 경우 집행관이 그 변경을 제거하여 원상회복할 수 있느냐 하는 것이다. 이에 관하여는 ① 언제든지 자력으로 할 수 있다는 견해(집행관 제거설), ② 이 가처분의 취지를 채무자에 대하여 현상변경의 부작용의무를 과한 것으로 보고 부작용의무에 관한 강제집행 방법(민집 260조)을 준용하여 민법 389조 3항을 근거로 한 수권결정을 얻어 원상회복의 강제집행을 할 수 있다는 견해(집행명령설), ③ 새로운 가처분에 의하여야 한다는 견해(신가처분명령설), ④ 현상이 변경 중이거나 변경 직후인 때에는 자력구제가 가능하나 이미 기정사실로 되었을 때에는 위 집행명령이 필요하다는 견해(절충설) 등으로 나누어지고 있으나, ②의 견해가 타당하다. 보전처분 신청사건의 사무처리요령(재민 2003-4) 11조도 채무자의 현상변경을 이유로 채무자의 사용을 중지하게 하기 위해서는 가처분 발령법원이나 그 상소심법원의 집행명령이 있어야 한다고 규정하고 있다. 다만 수권결정을 받는 데 너무 시간이 걸려 보전의 필요성이 있는 경우에는 제2차 가처분의 신청도 허용된다.

(다) 채무자 퇴거의 가부와 방법

채무자가 목적물의 객관적 현상을 변경한 경우(주관적 현상을 변경한 경우, 특히 그 점유의 일부를 제3자에게 이전한 경우에도 같은 문제이다) 이를 사용허가조건 위반이라고

하여 채무자의 사용을 금하고 집행관이 직접 보관할 수 있는가.

이에 관하여는 적극설과 소극설이 있고, 소극설에는 ① 민사집행법 260조, 민법 389조 3항의 집행명령을 얻어야 한다는 집행명령설과 ② 집행관 보관의 새로운 가처분이 있어야 한다는 신가처분명령설이 있다.

점유이전금지가처분은 목적물에 대한 현상유지를 목적으로 하는 것으로서 현상변경의 결과를 제거하는 것만으로 충분하다. 또한 위 가처분명령에는 채무자를 퇴거시키는 주관적 변경까지 할 수 있다는 취지는 포함되어 있지 아니하고, 이러한 채무자 퇴거 등의 조치 373
가 민법 389조 3항의 '장래에 대한 적당한 처분'에 해당된다고 보기도 어렵다. 따라서 소극설 중에서도 신가처분명령설이 타당하다.

(라) 본안소송에 미치는 효과

목적물의 객관적 현상변경을 금지하고자 하는 목적을 가진 점유이전금지가처분의 효력은 채무자의 위반행위를 채권자와의 관계에서 무효로 하고, 또한 금지하는 것이므로 이는 본안소송에서도 당연히 고려되어야 한다. 예를 들어, 피고(채무자)가 가처분명령을 위반하여 목적물에 관하여 객관적 현상을 변경하여 필요비, 유익비 등의 상환청구권을 근거로 한 유치권 항변을 하거나 매수청구권 행사에 의한 인도거절의 항변을 하는 경우, 피고는 가처분집행 후의 현상변경을 원고에게 유효하게 주장할 수 없으므로 현상변경에 해당하는 한도에서 이러한 항변을 주장할 수 없게 된다. 항변으로서 주장할 수 없다는 의미는 민법 규정의 취지 등에 비추어 유익비상환청구권 등의 성립 자체는 인정하되 위 청구권을 근거로 한 유치권은 이를 주장할 수 없다고 해석하여야 한다.

현상변경의 결과 목적물의 동일성이 상실된 경우 본안소송에서 청구의 취지 등을 변경할 필요가 있는가. 가처분 후의 현상변경은 채권자에게 대항할 수 없기는 하나 집행법상 구(舊) 목적물을 표시한 본안판결을 집행권원으로 하여 신(新) 목적물에 대하여 집행할 수 없고, 또한 본안판결이나 가처분명령에 관하여 주관적 변경에 있어서의 승계집행문과 같은 방법도 취할 수 없으며, 일단 발령된 가처분명령을 변경하는 방법도 마땅치 않으므로 결국 본안소송에서 청구취지를 신 목적물로 변경할 수밖에 없고 이를 게을리하면 본집행은 불능으로 된다.

(2) 주관적 현상변경의 경우

(가) 의의

집행관 보관, 채무자 사용형의 가처분이 집행된 뒤에 채무자가 임대·전대·임차권양도·

사용대차·매도·증여 등으로 제3자에게 목적물의 전부 또는 일부의 점유를 이전하거나 제3자가 채무자의 의사와는 상관없이 점유하게 된 것을 말한다.

374 (나) 제3자에 대한 퇴거의 강제 가부

점유이전금지가처분은 그 목적물의 점유이전을 금지하는 것으로서 그럼에도 점유가 이전되었을 때에는 가처분채무자는 가처분채권자에 대한 관계에 있어서 여전히 그 점유자의 지위에 있다는 의미로서의 당사자항정의 효력이 인정될 뿐, 가처분 이후에 매매나 임대차 등을 근거로 하여 가처분채무자로부터 점유를 이전받은 제3자에 대하여 가처분채권자가 가처분 자체의 효력으로 직접 퇴거를 강제할 수는 없다(대판 1999. 3. 23. 98다59118).

(다) 본안소송에 미치는 효과

점유이전금지가처분이 있었음에도 점유가 이전되었을 때에는 가처분채무자는 가처분채권자에 대한 관계에서 여전히 점유자의 지위에 있고, 따라서 가처분채권자는 가처분채무자의 점유상실을 고려하지 아니하고 가처분채무자를 피고로 한 채로 본안소송을 계속할 수 있다(대판 1966. 7. 26. 66다1060, 대판 1987. 11. 24. 87다카257, 258). 그러나 가처분채무자가 가처분채권자가 아닌 제3자에 대한 관계에서도 점유자의 지위에 있다고 볼 수는 없다(대결 1996. 6. 7. 96마27).

당사자항정효에 의하여 강제집행을 수인(受忍)하여야 할 자의 범위에 선의의 제3자도 포함되는가에 관하여는, ① 선의·악의를 불문하고 목적물의 점유를 승계한 모든 제3자에게 당사자항정효가 미친다는 견해(승계자 전원 확장설), ② 선의·무과실로 목적물을 점유하게 된 제3자는 이러한 제3자를 보호하는 명문의 실체법규가 없어도 보호되어야 하고 당사자항정효가 미치지 않는다는 견해(선의자 제외설), ③ 당사자항정효로부터의 선의자 보호는 실체법규의 적용(민 249조의 선의취득 등)이나 유추적용이 가능한 한도에서 긍정하는 견해(보호규정 예외설) 등이 있으나, ③설이 타당하다.

동산의 경우, 판례는 동산의 소유자가 동산을 이증으로 양도하고 각 점유개정의 방법으로 동산의 점유를 계속하는 경우 양수인들 사이에 있어서는 먼저 현실의 인도를 받아 점유를 해온 자가 소유권을 취득한다고 볼 것이나, 양수인 중 한 사람이 처분금지가처분집행을 하고 그 동산의 인도를 명하는 판결을 받은 경우에는 다른 양수인이 위 가처분집행 후에 양도인으로부터 그 동산을 현실로 인도받아 점유를 승계하였더라도 그 동산을 선의취득한 것이 아닌 한 이와 같은 양수인은 가처분채권자가 본안소송에서의 승소판결에 따른 집행권원에 터 잡아 강제집행을 하는 경우 이를 수인하여야 하는 지위에 있으므로 가처분채권자와의 사이에서는 그 동산의 소유권을 취득하였다고 주장할 수 없다고 한다(대판 1989.

10. 24. 88다카26802).

한편 부동산의 경우, 판례는 어떤 부동산에 대하여 점유이전금지가처분이 집행된 이후에 제3자가 가처분채무자의 점유를 침탈하는 등의 방법으로 가처분채무자를 통하지 아니하고 부동산에 대한 점유를 취득한 것이라면, 설령 점유를 취득할 당시에 점유이전금지가처분이 집행된 사실을 알고 있었다고 하더라도, 실제로는 가처분채무자로부터 점유를 승계받고도 점유이전금지가처분의 효력이 미치는 것을 회피하기 위하여 채무자와 통모하여 점유를 침탈한 것처럼 가장하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 제3자를 민사집행법 31조 1항에서 정한 '채무자의 승계인'이라고 할 수는 없다고 한다(대판 2015. 1. 29. 2012다111630, 대판 2015. 6. 11. 2014다88116). 따라서 이러한 경우 제3자를 상대로 별소를 제기하여야 한다.

제3자에게 본집행을 할 때에는 승계집행문이 필요하다(대판 1999. 3. 23. 98다59118).

제3편
제9장
제1절

3. 공사금지가처분 등

가. 개요

토지 소유자가 방해배제청구권에 기하여 자신 소유 토지 위의 건축공사를 금지(또는 중지)해달라고 가처분을 신청하거나, 건축공사로 인한 지반침하, 주택 붕괴의 위험 또는 일조나 조망, 경관 기타 생활이익의 침해를 이유로 인접 토지 소유자가 건물의 공사금지를 구하는 경우가 있다. 반대로 적법하게 진행되고 있는 공사를 방해하는 행위를 금지해달라는 공사방해금지가처분도 많이 제기된다. 이러한 가처분은 채무자가 일정한 적극적 행위를 하는 것을 금지하는 부작위를 명하는 가처분으로서 성질상 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에 속한다. 이하에서는 부작위를 명하는 가처분의 대표적인 유형인 공사금지가처분을 중심으로 논한다. 376

나. 가처분의 유형에 따른 피보전권리와 보전의 필요성

(1) 공사금지가처분

(가) 토지의 이용권, 담보권에 기초한 것

다른 사람이 권원 없이 건물을 건축하는 경우에 부지의 소유자나 점유자는 방해배제

또는 방해예방청구권에 기하여 건축공사의 금지(또는 중지)를 구할 수 있다. 유치권을 근거로 건축주 또는 새로운 시공자를 상대로 공사중지를 구하는 경우, 공사대금채권의 존재 및 적법한 점유의 계속 여부에 관하여 소명이 있는지 살펴보아야 한다.

건축공사는 저당권설정자의 토지 이용권 범위 내의 정당한 권리행사에 속한다고 볼 수 있어 이러한 공사의 금지를 구하는 저당권자의 가처분신청은 허용될 수 없음이 원칙이다. 그러나 나대지 상태에서 저당권을 설정한 다음 대지상에 건물을 신축하기 시작한 저당권 설정자가, 피담보채무를 변제하지 못함으로써 저당권이 실행에 이르렀거나 실행이 예상되는 상황인데도 직접 또는 제3자를 통해 신축공사를 계속한다면, 경매절차에서 매수희망자를 감소시키거나 매각가격을 저감시켜 저당권자가 지배하는 교환가치의 실현을 방해할 수 있으므로, 이러한 경우 저당권자는 방해배제청구권에 기하여 저당목적물인 토지상의 공사 금지를 구할 수 있다(대판 2006. 1. 27. 2003다58454 등 참조).

한편 토지에 관하여 저당권을 취득함과 아울러 그 저당권의 담보가치를 확보하기 위하여 지상권을 취득하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 당해 지상권은 저당권이 실행될 때까지 제3자가 용익권을 취득하거나 목적 토지의 담보가치를 하락시키는 침해행위를 하는 것을 배제함으로써 저당 부동산의 담보가치를 확보하는 데에 그 목적이 있다고 할 것이므로, 그와 같은 경우 제3자가 비록 토지소유자로부터 신축 중인 지상 건물에 관한 건축주 명의를 변경받았다 하더라도, 그 지상권자에게 대항할 수 있는 권원이 없는 한 지상권자로서는 제3자에 대하여 목적 토지 위에 건물을 축조하는 것을 중지하도록 요구할 수 있다(대결 2004. 3. 29. 2003마1753).

(나) 인접 토지·건물 소유자의 물권적 청구권에 기초한 것

건물을 건축하기 위하여 지하굴착공사를 시행함으로써 인접지의 지반이 붕괴·침하하거나 인접 건물에 균열이 발생한 경우, 또는 그러한 염려가 있는 경우에 그 인접 토지나 건물의 소유자는 건축주나 시공자를 상대로 하여 공사금지가처분을 구할 수 있다.

지하굴착공사가 종료된 시점에서 잔여공사의 금지를 구하는 가처분이 가능한가. 판례는 토지의 소유자가 예방공사를 하지 아니한 채 굴착공사를 함으로써 인접대지의 일부 침하와 건물균열 등의 위험이 발생하였다 하더라도 나머지 공사의 대부분이 지상건물의 축조이어서 더 이상의 굴착공사의 필요성이 없다고 보이고, 침하와 균열이 더 이상 확대된다고 볼 사정이 없다면 공사중지가처분을 허용하여서는 안 된다고 한다(대판 1981. 3. 10. 80다2832).

(다) 상린관계에 기초한 것

특별한 사정이 없으면 토지의 경계로부터 건물의 가장 돌출된 부분까지 0.5m 이상의

거리를 두고 건축하여야 하므로 인접지 소유자는 이에 위반한 자에 대하여 건물의 변경이나 철거를 청구할 수 있다(민 242조 1항, 2항 본문, 대판 2011. 7. 28. 2010다108883). 다만 건축에 착수한 후 1년이 경과하거나 건물이 완성된 후에는 손해배상청구만 가능하므로(민 242조 2항 단서), 이때에는 상린관계 규정의 위반을 이유로 건축금지가처분을 구할 수 없다. 한편 건축법 59조 1항 1호, 건축법시행령 81조 1항 1호에 비추어 볼 때 상업지역에서는 민법 242조가 적용되지 않는다고 해석함이 상당하다(대판 2001. 10. 23. 2001다45195). 또한 어느 토지 소유자가 새로이 지하수 개발공사를 시행하여 설치한 취수공 등을 통하여 지하수를 취수함으로써 말미암아 그 이전부터 인근 토지 내의 원천에서 나오는 지하수를 이용하고 있는 인근 토지 소유자의 음료수 기타 생활상 필요한 용수에 장애가 생기거나 그 장애의 염려가 있는 때에는, 생활용수 방해를 정당화하는 사유가 없는 한 인근 토지 소유자는 그 생활용수 방해의 제거나 예방을 청구할 수 있다(대판 1998. 4. 28. 97다48913).

378

제3편
제9장
제1절

(라) 생활이익침해에 따른 방해배제청구권에 기한 것

① 생활이익침해에 따른 방해배제청구권 인정 여부

일조이익·조망이익 등의 침해를 이유로 하는 공사금지가처분의 피보전권리에 관하여는 물권적 청구권설, 인격권설, 불법행위설, 환경권설, 상린관계설 등의 견해가 대립하고 있으나, 환경권은 명문의 법률규정이나 관계 법령의 규정 취지 및 조리에 비추어 권리의 주체, 대상, 내용, 행사 방법 등이 구체적으로 정립될 수 있어야만 인정되는 것이므로, 사법상의 권리로서의 환경권을 인정하는 명문의 규정이 없는 이상 원칙적으로 환경권에 기하여 직접 방해배제청구권을 인정할 수 없다는 것이 확립된 판례이다(대판 1997. 7. 22. 96다56153, 대결 2006. 6. 2. 2004마1148, 1149 등).

다만 판례는 어느 토지나 건물의 소유자 또는 점유자가 종전부터 향유하고 있던 경관이나 조망, 조용하고 쾌적한 종교적 환경 등이 그에게 하나의 생활이익으로서의 가치를 가지고 있다고 객관적으로 인정된다면 법적인 보호의 대상이 될 수 있으므로, 인접 대지에 건물을 신축함으로써 그와 같은 생활이익이 침해되고 그 침해가 사회통념상 일반적으로 참아내야 할 정도(‘참을 한도’)를 넘어선다고 인정되는 경우에는 토지 등의 소유자 또는 점유자는 소유권 또는 점유권에 기하여 방해의 제거나 예방을 위하여 필요한 청구를 할 수 있다고 하여(대판 1999. 7. 27. 98다47528, 대판 2007. 6. 15. 2004다37904, 37911 등), 소유권 또는 점유권에 기한 방해배제·예방청구권을 피보전권리로 보고 있다.

인접 대지에 건물이 건축됨으로 인하여 입는 환경 등 생활이익의 침해를 이유로 건축공

사의 금지를 청구하는 경우, 그 침해가 참을 한도를 넘어서는지 여부는 피해의 성질 및 정도, 피해이익의 공공성, 가해행위의 태양, 가해행위의 공공성, 가해자의 방지조치 또는
 379 손해회피의 가능성, 인·허가관계 등 공법상 기준에의 적합 여부, 지역성, 토지이용의 선후관계 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다는 것이 판례이다(대판 1999. 7. 27. 98다47528 등).

다만 임차권자 등이 점유권에 기하여 공사금지를 청구하는 경우 보전의 필요성을 좀 더 엄격한 기준으로 심리할 필요가 있을 것이다.

② 일조권 침해

건물의 신축으로 인하여 그 이웃 토지상의 거주자가 직사광선이 차단되는 불이익을 받는 경우에 그 신축행위가 정당한 권리행사로서의 범위를 벗어나 사법상 위법한 가해행위로 평가되기 위해서는 그 일조방해의 정도가 참을 한도를 넘어야 한다.

건축법 등 관계 법령에 일조방해에 관한 직접적인 단속법규가 있다면 그 법규에 적합한지 여부가 사법상 위법성을 판단함에 있어 중요한 판단자료가 되지만, 이러한 공법적 규제는 최소한도의 기준이므로 건물이 건축 당시의 공법적 규제에 형식적으로 적합하다고 하더라도 현실적인 일조방해의 정도가 현저하게 커 참을 한도를 넘은 경우에는 위법행위로 평가될 수 있으며, 일조방해 행위가 참을 한도를 넘었는지 여부는 피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해 건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대판(전) 2008. 4. 17. 2006다35865, 대판 2011. 4. 28. 2009다98652 등).

참을 한도의 고려요소 중 가장 중요한 것은 일조방해의 정도인데, 일조방해로 인한 손해배상청구에 관하여, 고층 아파트의 건축으로 인접 주택에 동지를 기준으로 진태양시(眞太陽時) 08:00~16:00 사이의 일조시간이 2분~150분에 불과하게 되는 일조 침해가 있는 경우 참을 한도를 넘었다고 한 판례가 있다(대판 2000. 5. 16. 98다56997). 현재 일조 침해를 이유로 하는 손해배상청구사건에서 다수의 실무는 '동지일을 기준으로 09:00부터 15:00까지 6시간 중 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되지 않고 동시에 08:00부터 16:00까지 8시간 중 총일조시간이 4시간 이상 확보되지 않는 경우'에 일조방해의 정도가
 380 참을 한도를 초과한 것으로 판단하고 있다.

그러나 일조방해행위가 앞서 본 기준에 따라 참을 한도를 넘어 사법상 위법한 가해행위로 평가된다고 하여 곧바로 공사금지를 구할 수 있는 것은 아니고, 일조침해의 정도가 현

저하여 사후의 금전 배상만으로는 일조권 침해로 인한 손해의 전보가 어렵다는 등 일조 방해행위의 위법성이 중대하다고 인정될 수 있는 경우에 한하여 공사금지가처분이 발령될 수 있다고 보는 것이 실무이다. 판례 중에는 신축 건물로 인하여 기존 건물이 동지일 기준 08:00에서 16:00까지 8시간 중 총일조시간이 1시간에 이르지 못하게 되고 동시에 09:00부터 15:00까지 6시간 중 연속일조시간이 30분에 이르지 못하게 되는 경우에 공사금지가처분을 구할 수 있을 정도로 참을 한도를 넘었다고 판단한 원심의 결론을 정당하다고 한 것이 있다(대결 2007. 10. 24. 2007마742, 743).

일조시간만을 기준으로 확립적으로 판단하는 것은 지양하여야 한다. 예를 들면 가해건물의 신축 이전에는 일조방해가 전혀 없었던 경우와 가해토지상의 종전 건물로 인하여 이미 어느 정도의 일조방해가 있었거나 피해건물이 서향 또는 동향 건물인 경우와 같이 피해건물 자체가 제한된 일조만을 확보하고 있었던 경우를 동일하게 취급하는 것은 타당하지 않다(대판 2007. 6. 28. 2004다54282, 대판 2010. 6. 24. 2008다23729 등).

일조방해의 정도와 아울러 토지의 용도와 지형, 주변건물의 상황 등 지역성도 중요한 고려요소가 된다. 지역성은 그 지역의 토지이용 현황과 실태를 바탕으로 지역의 변화 가능성과 변화의 속도 그리고 지역주민들의 의식 등을 감안하여 결정하여야 하고, 바람직한 지역 정비로 토지의 경제적·효율적 이용과 공공의 복리증진을 도모하기 위한 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 공법에 의한 지역의 지정은 그 변화 가능성 등을 예측하는 지역성 판단의 요소가 된다(대판 2004. 10. 28. 2002다63565, 대판 2007. 6. 14. 2005다72058 등). 피해건물과 가해건물이 위치한 곳이 주거지역인지 아니면 상업지역인지에 따라 참을 한도가 달라져야 할 것이므로 가해건물이 위치한 곳이 상업지역인 경우나 양자가 모두 상업지역에 있는 경우에는 위 기준에 따른 일조시간이 확보되지 않더라도 참을 한도를 넘지 않은 것으로 보아야 할 경우가 있다(대판 2002. 12. 10. 2000다72213 등). 또한 일조피해를 받는 건물이 이미 다른 기존의 건물에 의하여 일조방해를 받고 있는 경우에는 그 일조방해의 정도와 신축 건물에 의한 일조방해와의 관련성 등도 고려하여 일조방해가 참을 한도를 넘었는지 여부를 판단하여야 한다. 피해건물의 남쪽이 고지인 경우 가해건물을 종전 건물보다 조금만 높게 건축하여도 위 기준에 따른 일조방해가 있을 수 있으므로 그 경우에도 위 기준이 절대적인 기준이 된다고 보기는 어려울 것이다.

③ 조망권 침해

어느 토지나 건물의 소유자가 종전부터 향유하고 있던 경관이나 조망이 그에게 하나의 생활이익으로서의 가치를 가지고 있다고 객관적으로 인정된다면 법적인 보호의 대상이 될

수 있다(대판 1997. 7. 22. 96다56153 등). 이와 같은 조망이익은 원칙적으로 특정의 장소가 그 장소로부터 외부를 조망함에 있어 특별한 가치를 가지고 있고, 그와 같은 조망이익의 향유를 하나의 중요한 목적으로 하여 그 장소에 건물이 건축된 경우와 같이 당해 건물의 소유자나 점유자가 그 건물로부터 향유하는 조망이익이 사회통념상 독자의 이익으로 승인되어야 할 정도로 중요성을 갖는다고 인정되는 경우에 비로소 법적인 보호의 대상이 되고, 그와 같은 정도에 이르지 못하는 조망이익의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 법적인 보호의 대상이 될 수 없다(대판 2004. 9. 13. 2003다64602, 대판 2007. 9. 7. 2005다72485 등). 판례는 피고가 신축하는 아파트 부지에 있던 종전 5층 아파트의 뒤에 그보다 높은 원고들 거주 10층 건물이 세워져 한강 조망을 확보한 경우와 같이 보통의 지역에 인공적으로 특별한 시설을 갖추으로써 누릴 수 있게 된 조망의 이익은 법적으로 보호받을 수 없다고 한다(대판 2007. 6. 28. 2004다54282).

조망이익이 법적인 보호의 대상이 되는 경우에 이를 침해하는 행위가 사법상 위법한 가해행위로 평가되기 위해서는 조망이익의 침해 정도가 사회통념상 일반적으로 참아내야 할 정도를 넘어야 하고, 그 참을 한도를 넘었는지 여부는 조망의 대상이 되는 경관의 내용과 피해건물이 입지하고 있는 지역에서 건조물의 전체적 상황 등의 사정을 포함한 넓은 의미에서의 지역성, 피해건물의 위치 및 구조와 조망상황, 특히 조망과의 관계에서의 건물의 건축·사용목적 등 피해건물의 상황, 주관적 성격이 강한 것인지 여부와 여관·식당 등의 영업과 같이 경제적 이익과 밀접하게 결부되어 있는지 여부 등 당해 조망이익의 내용, 가해건물의 위치 및 구조와 조망방해의 상황 및 건축·사용목적 등 가해건물의 상황, 가해건물 건축의 경위, 조망방해를 회피할 가능성의 유무, 조망방해에 관하여 가해자 측이 해의를 가졌는지의 유무, 조망이익이 피해이익으로서 보호가 필요한 정도 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(위 2004다54282 판결 등).

④ 소음·진동 등을 원인으로 하는 경우

인접 지역의 공사로 인하여 소음 및 진동 등이 발생하고, 그 정도가 사회통념상 일반적으로 참아내야 할 정도를 넘어서는 경우 공사중지가처분을 발령할 수 있다. 소음이나 진동의 발생 자체가 매우 중대하고, 채무자의 태도 등에 비추어 공사 자체의 전면 금지를 명하여야 신청의 목적이 달성될 것으로 판단되는 경우에는 공사 자체의 전면 금지를 명하고, 참을 한도를 넘는 소음 내지 진동의 범위를 설정하여 이를 초과하지 말 것을 명함으로써 신청의 목적이 달성될 수 있는 것으로 판단되면 이를 초과하는 공사의 중지를 명한다. 그 기준은 소음·진동 등으로 인하여 채권자가 입는 피해의 내용, 소음, 진동 등

의 발생 정도 및 시간대, 발생 기간, 소음·진동관리법 등 공법상 규제의 위반 여부, 장소적 특성, 공사 이전 피해지로 유입되었던 소음 등의 정도 등을 종합적으로 고려하여 정하여야 할 것이다.

한편 도로에서 발생하는 소음에 관한 사건에서, 판례는 “공동주택에 거주하는 사람들이 참을 한도를 넘는 생활방해를 받고 있는지는 특별한 사정이 없는 한 일상생활이 실제 주로 이루어지는 장소인 거실에서 도로 등 소음원에 면한 방향의 모든 창호를 개방한 상태로 측정한 소음도가 환경정책기본법상 소음환경기준 등을 초과하는지에 따라 판단하는 것이 타당하다.”고 하였고, 또한 “생활방해를 원인으로 소음의 예방 또는 배제를 구하는 방지청구는 금전배상을 구하는 손해배상청구와는 내용과 요건을 서로 달리하는 것이어서 같은 사정이라도 청구의 내용에 따라 고려요소의 중요도에 차이가 생길 수 있고, 방지청구는 그것이 허용될 경우 소송당사자뿐 아니라 제3자의 이해관계에도 중대한 영향을 미칠 수 있어, 방지청구의 당부를 판단하는 법원으로서 청구가 허용될 경우에 방지청구를 구하는 당사자가 받게 될 이익과 상대방 및 제3자가 받게 될 불이익 등을 비교·교량하여야 한다.”고 하였다(대판 2015. 9. 24. 2011다91784).

(마) 사생활 침해

건물의 건축으로 인하여 사생활의 비밀이 침해될 경우에도 참을 한도를 벗어난다면 공사금지가처분을 신청할 수 있다(대판 1979. 11. 13. 79다484, 대판 1999. 1. 26. 98다23850 등).

(바) 도급계약과 관련된 공사금지가처분

도급인은 수급인이 일을 완성하기 전에는 손해를 배상하고 도급계약을 해제할 수 있고(민 673조) 여기서 손해의 배상은 계약해제의 요건이 아니므로, 도급인은 수급인이 계약을 위반하였는지 여부에 관계없이 도급계약을 해제하고 그 공사의 금지를 구할 수 있다. 이러한 경우 수급인이 공사대금채권에 기한 유치권을 주장하는 예가 있으나 수급인이 유치권에 기하여 공사현장을 점유하는 것은 별론으로 하고 공사를 계속할 권원은 없다고 봄이 상당하므로, 설령 유치권이 인정되더라도 도급인의 공사금지가처분 자체가 인용되는 데에는 문제가 없을 것이다. 한편 수급인이 도급계약 해제의 부적법을 주장하며 공사대금채권 또는 시공권을 피보전권리로 삼아 공사를 진행하고 있는 새로운 수급인을 상대로 공사금지를 구하는 경우가 있으나, 공사도급계약자는 채권적 권리만을 가지고 있는 경우가 대부분이어서 공사현장을 점유하며 공사를 진행하고 있는 자를 상대로 공사금지를 구할 피보전권리와 보전의 필요성이 소명되기 어려울 것이다.

(사) 공법상 규정의 위반

참을 한도를 넘는 침해가 있었는지를 판단함에 있어 공법상의 규정을 참작할 수 있음은 물론이나, 건축허가처분 등이 위법하다는 이유만으로 바로 그 건축의 금지를 구할 사법상의 권리가 생긴다고 할 수는 없다. 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률상 근린공원은 누구나 자유로이 이용할 수 있지만, 그러한 사정만으로 그 인근 주민들이 공원이용권이라는 배타적인 권리를 취득하였다고 할 수 없으므로 공원 내 개인 소유 토지상의 시설물 건축금지를 구할 수 없고, 구 학교보건법상 학교환경위생 정화구역 내 건축행위에 대하여 학습환경권을 피보전권리로 하여 공사중지를 명하는 가처분을 신청할 수도 없다(대결 1995. 5. 23. 94마2218, 대결 2004. 6. 11. 2002마532).

(2) 공사방해금지가처분

실무상 토지의 이용권을 둘러싼 분쟁과 관련하여 청구하는 경우가 대부분으로서 공사금지가처분의 반대당사자로부터 선행적으로 또는 공사금지가처분신청에 대한 대항수단으로 행해지고 있다. 공사방해의 행위태양은 사람 또는 물건 등을 통하여 공사현장을 점거하거나, 공사현장에 진입하려는 장비나 인부의 출입을 저지하거나, 단전, 단수 등을 하는 것이다. 공사방해는, 공사금지가처분을 제기할 입장에 있는 자들에 의하여 자력구제의 방법으로 이루어지는 경우가 대부분이므로, 그 주요 쟁점은 공사금지가처분과 같다.

공사 자체가 가처분으로 금지를 명할 정도로 위법한 경우에 그에 대한 방해행위가 위법하다고 하여 공사방해금지가처분을 인용하게 되면 그 공사가 적법한 것으로 인식될 여지가 있으므로, 그 공사의 속행이 정당한지에 대하여도 심리를 하여 이를 보전의 필요성의 판단요소로 고려할 필요가 있다. 따라서 공사금지가처분과 공사방해금지가처분이 동시에 제기된다면 그중 하나만을 인용하는 것이 바람직하다(두 가처분의 경합이 허용된다는 반대 견해 있음).

한편 채무자가 방해행위를 일시적으로 중단하고 있다고 하더라도, 향후 그러한 행위를 다시 할 개연성이 높은지 여부를 심리하여 보전의 필요성을 판단하여야 한다.

다. 당사자

가해건물의 건축주 또는 사업시행자와 시공자가 공사금지가처분의 채무자로 되며 실무상 건축주와 시공자를 공동채무자로 삼는 경우가 많다. 상린관계에 기한 경우에는 토지의 소유자에 한하지 않고 임차권자 등도 가처분채권자에 포함될 수 있다.

일조권, 조망권 등을 이유로 한 공사금지가처분의 피보전권리를 소유권 또는 점유권에 기한 방해배제·예방청구권으로 보는 경우 토지 또는 건물의 소유자 또는 점유자가 채권자가 되며, 심리 도중에 소유권 또는 점유권을 상실하면 더 이상 피보전권리를 인정할 수 없다. 판례는 일조권 침해에 있어 객관적인 생활이익으로서 일조이익을 향유하는 ‘토지의 소유자 등’은 토지소유자, 건물소유자, 지상권자, 전세권자 또는 임차인 등의 거주자를 말하는 것으로서, 당해 토지·건물을 일시적으로 이용하는 것에 불과한 사람은 이러한 일조이익을 향유하는 주체가 될 수 없다고 한다(대판 2008. 12. 24. 2008다41499). 신소유자 또는 신점유자는 승계참가가 가능하다. 나대지의 소유자는 그 상태에서의 일조나 조망 등의 생활이익이 특별히 보호되어야 할 사정이 없는 한 피보전권리를 인정받기 어려울 것이다.

라. 심리와 재판

(1) 원칙적 심문

공사금지가처분은 가처분결정이 잘못되었을 경우에 채무자가 입는 손해는 다른 가처분의 경우보다 상당히 커서 보증에 의한 손해의 전보로도 충분하지 않은 경우가 많은 반면, 이러한 가처분이 신청되었음을 채무자가 알더라도 채권자의 권리가 침해될 우려가 매우 적다고 할 수 있다. 따라서 기일을 열어 심리하면 가처분의 목적을 달성할 수 없는 사정이 있는 때를 제외하고는 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 한다(민집 304조). 실무상으로는 심문기일로 진행하는 것이 일반적이다.

(2) 소명방법

건축공사에 관한 가처분은 그로 인하여 건축공사의 지연이 초래되어 건축주 측에 큰 경제적인 부담을 주게 되는 반면에, 건축주가 건물을 건축하여 버리면 인근 주민들은 반영구적으로 피해를 받게 되어 그 회복이 쉽지 않게 되는 등 분쟁 당사자 쌍방에게 미치는 영향이 대단히 크므로 분쟁 당사자 쌍방의 감정적인 대립이 상당히 격화되기 쉬운 특성이 있다. 따라서 신속한 재판이 요구되는 반면, 피보전권리의 존재 및 보전의 필요성에 대하여 일반의 가처분보다 고도의 소명이 요구된다.

공사금지가처분의 경우에도 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거방법에 의하여야 하므로 원칙적으로 검증·감정은 허용되지 않는다. 실무상 당사자로 하여금 검증의 대응으로서 현장사진이나 도면, 측량도, 모형 등을, 감정의 대응으로서 관계 전문가의 의견서나 컴퓨터 시뮬레이션 출력물 등을 제출하도록 권고함이 상당하고, 경우에 따라서는 현장상황 등을

촬영한 자료를 제출하게 하기도 한다.

다만 일조 등의 침해를 이유로 한 공사금지가처분의 경우에는 실무상 예외적으로 현장 검증신청이나 감정신청을 채택하기도 한다. 채권자가 소명자료로 사적인 의뢰에 의하여 작성된 감정보고서를 제출하는 경우가 있다. 그러한 경우에는 채무자도 사적으로 감정을 의뢰하여 감정보고서를 제출하는 경우가 있는데 이때에는 법원이 별도로 감정을 명하지 않는 경우가 많다. 법원이 감정을 명할 경우에는 통상 피해건물의 주요 채광창을 기준으로 일조확보시간을 산정하도록 하는데 그와 관련하여 일조방해 또는 일조확보시간을 산정한 기준을 감정서에 명시하도록 하며, 종전 건물로 인한 일조방해의 정도도 반드시 감정내용에 포함하도록 한다. 가해건물이 예정대로 완공될 경우의 일조방해의 정도와 함께 가해건물 완공 시 참을 한도를 초과하는 일조방해가 발생할 경우에는 참을 한도 내의 일조가 확보되는 가해건물의 층수, 구조 등도 밝히도록 한다.

(3) 담보

공사금지를 명하는 경우에는 대상이 되는 건물의 가치가 하나의 기준이 되므로 그 규모에 의하여 담보금액도 커지게 된다.

공사방해금지를 명하는 경우에는, 실력에 의한 방해가 허용될 수는 없어 이를 당연히 금지할 수밖에 없기 때문에 담보금액이 보다 적은 경우가 보통일 것이나, 채무자에게 특별히 큰 손해를 주게 되는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 그것을 담보하기에 족한 보증금이 요구된다.

(4) 조정·화해 시도

통상 건축공사를 둘러싼 가처분사건에서는, 공사가 중지되면 건축자금의 조달계획에 차질이 생기고 건축비용이 증가하여 큰 손해를 입을 우려가 있기 때문에 신속한 심리를 구하는 건축주의 입장과, 가처분 발령 요건의 존부 해명이 기술적으로 곤란한 관계로 정확하고 신중한 심리를 요청하는 채권자의 입장이 대립되고, 결과에 따라서 어느 한 편은 치명적인 손해를 입게 되므로 분쟁의 신속하고도 종국적인 해결 및 손해의 확대방지를 위하여 보전소송의 소송물뿐만 아니라 본안청구에 대하여도 조정이나 화해를 하는 경우가 있다.

(5) 재판

피보전권리와 보전의 필요성이 인정되어 가처분명령을 발령하는 경우에 그 인정 범위는 채권자의 권익보호에 필요한 최소한에 그치도록 노력하여야 한다.

공사금지가처분에서는 통상 단순히 채무자의 공사를 금지시키거나 중지시키는 결정 외

에도 “채무자는 별지 목록 기재 토지에 관하여 별지 도면 표시 ……부분 위에 높이 0m, 길이 0m 이상의 철근콘크리트조 옹벽을 설치하지 않고서는 지표면으로부터 0m 이상 굴착하는 공사를 하여서는 아니 된다.”와 같이 피해예방공사를 공사속행의 조건으로 하여 가처분결정을 하는 경우도 있고, “채무자는 채권자 소유의 건물에 발생한 피해의 보수공사를 시행하라. 채무자는 위 보수공사를 마칠 때까지 채무자 소유의 별지 목록 기재 토지에 건축 중인 공사를 속행하여서는 아니 된다.”와 같이 피해보수공사를 공사속행의 조건으로 하여 가처분결정을 하는 경우도 있다.

일조 등의 침해가 참을 한도를 넘는 것으로 판단되는 경우에도 원칙적으로 공사 전체의 금지를 명하지 않고 참을 한도를 넘는 일조 등의 침해가 발생하는 층수 이상의 공사를 금지한다. 건물의 일부분을 축조하지 않거나 구조를 변경함으로써 일조 등의 침해가 참을 한도를 넘지 않는다는 점이 감정 등에 의하여 명확히 밝혀진 경우에는 가해건물의 층수를 제한하는 대신 특정부분에 대한 공사금지를 명하는 것도 가능하다.

388

제3편
제9장
제1절

공사금지가처분의 발령사실 및 부작위의무의 범위 등을 공시함으로써 재건축조합원이나 시공자를 상대로 한 가처분에서의 건축주 등과 같이 당해 공사에 관한 다수 이해관계인에 대하여 권리관계를 명확히 하고, 또한 추가적인 분쟁발생의 소지를 없앨 수도 있으므로 공시명령을 붙이는 것이 다수의 실무이다.

마. 주문례

(1) 토지소유권에 기한 건축금지가처분

채무자는 별지 목록 기재 토지 위에 건물의 축조공사를 하여서는 아니 된다.
집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

채무자는 별지 목록 기재 토지에 관하여 별지 도면 표시 ①, ②, ③, ④, ①의 각 점을 순차로 연결한 선내 ㉔부분 위에 높이 0m, 길이 0m 이상의 철근콘크리트조 옹벽을 설치하지 않고서는 지표면으로부터 0m 이상 굴착하는 공사를 하여서는 아니 된다.

채무자는 별지 목록 기재 토지 위에 건물을 축조하거나 그 밖에 유수를 방해하는 일체의 공사를 하여서는 아니 된다.

경우에 따라서는 반입된 공사자재의 수거를 명하는 단행가처분이 포함되는 수가 있는데, 이때에는 집행단계가 필요하게 된다. 주문례는 다음과 같다.

1. 채무자는 별지 제1 목록 기재 토지 위에 건축 중인 건물의 축조 공사를 중지하여야 하고, 이를 속행하여서는 아니 된다.
2. 채무자는 위 건축공사를 위하여 설치된 별지 제2목록 기재 물건들을 이 명령 송달일부터 ○일 내에 수거하라.
3. 채무자가 위 기일 내에 이를 수거하지 아니하면 집행관은 채권자의 신청에 의하여 채무자의 비용으로 이를 제거할 수 있다.
4. 집행관은 위 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

389 (2) 건물소유권에 기한 공사금지가처분

채무자는 별지 목록 기재 건물에 관하여 개축·증축·그 밖의 공사를 하여서는 아니 된다.

채무자는 별지 목록 기재 건물에 관하여 그 내부의 구조를 변경하는 공사를 하여서는 아니 된다.

(3) 일조권 등의 침해를 이유로 한 공사금지가처분

채무자는 별지 목록 기재 토지 위에 건축 중인 건물에 관하여 지표면으로부터 0m 이상으로 축조하는 공사를 하여서는 아니 된다.

(4) 소음 및 진동 발생 제한을 명하는 가처분

채무자는 OO도로 건설공사를 하면서 별지 목록 기재 채권자의 건물로 60dB(A) 이상의 소음 및 57dB(V) (≒0.02kine) 이상의 진동이 유입되도록 하여서는 아니 된다.

(5) 철거금지가처분

채무자는 별지 목록 기재 건물을 철거하여서는 아니 된다.

(6) 진입금지가처분

채무자는 별지 목록 기재 부동산에 진입하여서는 아니 된다.

채무자 또는 그 사용인은 별지 목록 기재 부동산에 진입하여 경작행위를 하여서는 아니 된다.

바. 집행과 그 효력

(1) 이러한 가처분은 단순히 부작위의무만을 명할 뿐이므로 채무자에게 가처분의 내용을 고지함으로써 족하고 원칙적으로 집행이라는 관념이 존재하지 않는다. 다만 반복적 계속적 부작위를 명하는 가처분에서 채무자가 의무위반을 할 때에는 대체집행(민집 260조) 또는 간접강제(민집 261조)의 방법에 의하여 그 의무의 이행을 강제할 수 있다. 390

채무자의 의무 위반 시 강제하는 위 두 가지 방법 가운데 일반적으로 채무자의 위반행위가 물적 상태를 남기는 경우에는 대체집행의 방법에 의하고, 그 위반행위가 물적 상태를 남기지 않는 경우에는 간접강제의 방법에 의한다. 대체집행이나 간접강제를 위해서는 채무자의 심문이 필요함은 물론이다(민집 262조).

가처분은 소급효가 없으므로 채권자가 이러한 종류의 가처분명령을 얻을 때까지 사이에 채무자가 가처분에 의하여 금지시키려는 행위를 하여 이미 발생한 물적 상태(건축공사금지가처분 전에 이미 완료된 공사부분)를 제거할 수는 없고, 그 제거를 위해서는 새로운 집행권원을 얻어야 한다.

(2) 집행을 따로 요하지 아니하는 단순히 부작위를 명하는 가처분의 경우에는 원칙적으로 집행기간의 문제가 생기지 않으나 채무자가 명령위반행위를 하면 채권자는 그 제거 또는 방지를 구할 수 있는바(민집 260조, 민 389조 3항), 그 명령위반 행위 시로부터 그 제거나 방지를 위한 신청의 집행기간이 개시된다. 채무자에 대하여 단순히 부작위를 명하는 가처분은 그 가처분재판이 채무자에게 고지됨으로써 효력이 발생하는 것이지만, 채무자가 그 명령 위반의 행위를 한 때에 비로소 간접강제의 방법에 의하여 부작위 상태를 실현시킬 필요가 생기는 것이므로 그때부터 2주 이내에 간접강제를 신청하여야 함이 원칙이다. 다만 채무자가 가처분 재판이 고지되기 전부터 가처분재판에서 명한 부작위에 위반되는 행위를 계속하고 있는 경우라면, 그 가처분결정이 채권자에게 고지된 날부터 2주 이내에 간접강제를 신청하여야 하고, 그 집행기간이 지난 후의 간접강제 신청은 부적법하다(대결 2010. 12. 30. 2010마985).

한편 부작위를 명하는 가처분에 공시명령이나 집행관 보관명령이 부가되어 있는 경우, 그 부분의 집행에 관하여는 집행기간에 관한 규정이 준용된다(대결 1982. 7. 16. 82마카50).

4. 채권자의 행위에 대한 방해금지를 명하는 가처분

391

가. 개요

(1) 채권자가 권원에 기하여 어떤 행위(권리행사)를 하고 있는 것을 채무자가 방해하고

있거나 방해할 우려가 있을 때 그 방해배제청구권 또는 방해예방청구권의 보전을 위하여 행하는 가처분이다. 이러한 가처분 역시 채무자에게 부작위의무를 과할 뿐이므로 채무자에게 가처분을 고지함으로써 족하고 별도의 집행행위는 필요 없다. 이 가처분은 현재의 상황을 깨뜨리지 않고 채권자의 권리를 적법하게 행사할 수 있음을 전제로 하여 발령하는 것이며, 채권자의 행위가 현재의 질서를 깨뜨리는 것이 되면(예를 들면 채무자가 점유 중인 건물에 채권자가 입주하려는 경우), 단행가처분과 같은 효과가 있게 되므로 신중하여야 한다.

(2) 이 가처분도 부작위를 명하는 가처분의 일종이라 할 수 있지만 단순히 채무자에게 일정한 행위의 금지만을 명하는 것이 아니라 채권자에 대하여 일정한 적극적인 행위를 하는 것을 인정한다는 점에서 단순히 부작위의무를 명하는 가처분과 다르다. 따라서 이 가처분이 발령된 후에 채무자가 채권자에 대하여 채권자에게 인정된 일정한 행위를 금지해 달라는 가처분을 신청하는 것, 예를 들면 공사방해금지가처분이 내려진 후에 채무자가 신청한 공사금지가처분은 받아들여질 수 없을 것이다.

(3) 채무자가 스스로 또는 제3자를 이용하여 실력으로 이 가처분을 위반하는 방해행위를 하였을 때 채권자는 어떠한 집행방법을 취할 수 있는가. 그 방해행위의 결과 유형물이 남아 있는 경우, 예를 들어 통행방해금지가처분의 채무자가 통행로에 철책 등을 설치하여 통행을 방해한 경우에는 민법 389조 3항에 따라 수권결정을 얻어 대체집행의 방법으로 해당 유형물을 제거하면 된다. 그 외의 경우에는 간접강제결정을 얻는 방법으로 채무자의 방해행위를 막을 수 있을 것이다.

392 나. 통행방해금지가처분

채권자의 행위에 대한 방해금지를 명하는 가처분 중 대표적인 것은 공사방해금지가처분, 통행방해금지가처분이다. 공사방해금지가처분은 위 3.항에서 살펴보았으므로 여기에서는 통행방해금지가처분에 대하여 살펴본다.

통행방해금지가처분은 민법 219조의 주위토지통행권, 배타적 사용수익권 포기, 민법 291조의 통행지역권, 계약에 의한 통행권 등을 피보전권리로 하는 가처분이다. 통행방해행위의 금지와 아울러 통행을 방해하는 공작물의 철거를 구할 수도 있다(대판 2006. 10. 26. 2005다30993).

어느 사유지가 사실상 일반 공중의 교통에 공용되는 도로로 사용되고 있는 경우, 그 토지의 소유자가 그 토지에 대한 독점적이고 배타적인 사용수익권을 포기한 것으로 의사해석을 함에 있어서는, 그가 당해 토지를 소유하게 된 경위나 보유기간, 나머지 토지들을

분할하여 매도한 경위와 그 규모, 도로로 사용되는 당해 토지의 위치나 성상, 인근의 다른 토지들과의 관계, 주위 환경 등 여러 가지 사정과 아울러 분할·매도된 나머지 토지들의 효과적인 사용·수익을 위하여 당해 토지가 기여하고 있는 정도 등을 종합적으로 고찰하여 판단하여야 한다(대판 2006. 5. 12. 2005다31736 등 참조).

어떠한 토지가 일반 공중의 통행에 제공되는 상태에 있다는 사유만으로 이를 통행하고자 하는 사람이 그 통행을 방해하는 사람에 대하여 당연히 지장물의 제거 등을 포함하여 방해의 배제를 구할 수 있는 사법상 권리를 갖게 되는 것은 아니다. 다만 통행의 방해가 특정인에 대하여만 이루어지고 그로 인하여 일상생활에 지장을 초래하는 때와 같이 통행 방해 행위가 특정인의 통행의 자유에 대한 위법한 침해로서 민법상 불법행위를 구성한다고 평가될 정도에 이른 경우에는 그 금지를 구하는 것이 허용될 수도 있다(대판 2011. 10. 13. 2010다63720, 대결 2013. 2. 14. 2012마1417 등 참조).

한편 토지 소유자가 자신 소유의 토지 위에 공작물을 설치한 행위가 인근건물의 소유자에 대한 관계에서 권리남용에 해당하고, 그로 인하여 인근건물 소유자의 건물 사용수익이 실질적으로 침해되는 결과를 초래하였다면, 인근건물 소유자는 소유권에 기한 방해제거청구권을 행사하여 토지 소유자를 상대로 통행방해금지 및 그 공작물의 철거를 구할 수 있다. 393

채권자가 채무자의 토지를 통행하는 데 방해를 받고 있기는 하나 이로 인하여 채권자의 토지 이용에 현저히 장애가 발생하였다고 보기 어려운 경우, 채권자가 통행을 위하여 다른 토지를 이용할 수 있는 여지가 있는 경우, 채권자가 이미 다른 토지를 사용하고 있는 경우에는 보전의 필요성이 인정되기 어렵다.

주위토지통행권에 기한 통행방해금지가처분신청사건에서는 반드시 필요한 경우에는 현장검증이나 감정을 실시하기도 한다. 주위토지통행권은 공로와의 사이에 그 용도에 필요한 통로가 없는 토지의 이용이라는 공익목적을 위하여 피통행지 소유자의 손해를 무릅쓰고 특별히 인정되는 것이므로, 그 통행로의 폭이나 위치 등을 정함에 있어서는 피통행지의 소유자에게 가장 손해가 적게 되는 방법이 고려되어야 한다(대판 2009. 6. 11. 2008다75300).

다. 주문례

(1) 점유방해금지가처분

채무자는 채권자의 별지 목록 기재 물건에 대한 점유사용을 방해하여서는 아니 된다.

채무자는 별지 목록 기재 건물에 들어가거나 그 밖에 채권자의 위 건물에 대한 점유사용을 방해하여서는 아니 된다.

(2) 통행방해금지가처분

채무자는 채권자가 별지 목록 기재 토지 중 별지 도면 표시 ①, ②, ③, ④, ①의 각 점을 순차로 연결한 선내 ㉞ 부분을 통로로 사용함을 방해하여서는 아니 된다.

채무자는 별지 목록 기재 토지 중 별지 도면 표시 ①, ②, ③, ④, ①의 각 점을 순차로 연결한 선내 ㉞부분의 통로에 철책이나 그 밖의 공작물을 설치하여 채권자의 통행을 방해하여서는 아니 된다.

394 (3) 공사방해금지가처분(점유의 해제 포함)

1. 채무자는 별지 목록 기재 건물에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
2. 채무자는 채권자가 위 건물 중 별지 도면 표시 ①, ②, ③, ④, ①의 각 점을 순차로 연결한 선내 ㉞ 층계 부분을 수리하는 것을 방해하여서는 아니 된다.
3. 집행관은 채권자가 위 수리공사를 함을 허용하고 채무자에 대하여 위 공사를 방해하지 않는 범위 내에서 위 건물의 사용을 허용하여야 한다.
4. 집행관은 위 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

5. 방해물배제의 가처분

가. 개요

이 가처분은 소유권이나 그 밖의 사용·수익권에 기하여 방해배제를 구하는 권리를 보전하기 위한 가처분으로서 작위를 명하는 가처분의 일종이다.

이 가처분은 이미 기정사실로 되어 있는 방해상태의 제거를 목적으로 하므로 일종의 단행가처분이며 원칙적으로 변론기일이나 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 한다(민집 304조). 실무의 관행상 담보금을 비교적 높게 정한다. 단순히 방해상태의 제거만을 명하는 경우도 있고(이때에 채무자가 그 의무를 이행하지 않으면 대체집행의 신청을 하여야 한다), 가처분 자체에 채권자의 대체집행을 허용하는 문구를 넣는 경우도 있다. 후자의 경우에는 대체집행의 신청이 있어야 하고, 결정을 하기 전에 채무자를 심문하여야 한다(민집 262조).

나. 주문례

(1) 기본형

채무자는 이 명령 송달일부터 ○일 내에 별지 목록 기재 토지 위에 있는 ○○를 수거하라.

채무자는 이 명령 송달일부터 ○일 내에 별지 목록 기재 토지 위에 있는 ○○를 철거하고 채권자가 그 지상을 통행하는 것을 방해하여서는 아니 된다.

※ 이 문례는 방해물배제의 가처분과 전술 4. 가처분의 복합형임.

(2) 대체집행을 허용하는 문구가 있는 경우

1. 채무자는 이 명령 송달일부터 ○일 내에 별지 목록 기재 토지 위에 있는 ○○을 수거하라.
2. 채무자가 위 명령을 실행하지 아니하면 채권자는 집행관으로 하여금 채무자의 비용으로 위 물건을 수거하게 할 수 있다.

395

제3편
제9장
제1절

6. 인도·철거·수거 등 단행가처분

가. 개요

(1) 인도단행가처분은 부동산의 인도, 즉 현상 그대로의 점유이전청구권을 보전하기 위하여 그 점유를 채무자로부터 채권자에게로 이전할 것을 명하는 만족적 가처분이다. 판례는 건물인도청구권의 보전을 위하여 집행관 보관·채권자 사용형의 가처분을 하는 것이 권리보전의 범위를 일탈하는 것으로 볼 수 없다고 하였다[대판(전) 1964. 7. 16. 64다69].

현상의 변경을 수반하는 점유이전인 철거, 수거, 굴이(掘移)단행가처분은 건물, 임목, 수목 등 토지의 정착물에 대한 철거 등 청구권을 보전하기 위하여 채무자에게 그 철거 등을 명하는 만족적 가처분이다.

(2) 실무상 본안의 소 제기 없이 인도단행가처분만을 신청하기도 하나 본안 제기와 동시에 가처분을 신청하는 경우도 상당수에 이른다. 인도단행가처분이 집행되면 가처분채권자는 사실상 본안소송에 의하여 실현하려는 목적을 달성하는 반면, 가처분채무자는 본안소송에서 다투어 볼 기회조차 없이 부동산에 대한 현재의 이용상태를 박탈당하여 생활이나 영업에 막대한 지장을 받을 우려가 있다. 따라서 가처분으로서 신속하게 인도를 명할 특별한 사정이 있는지를 심리하여 신중하게 가처분을 발령하여야 한다.

396

한편 철거, 수거 등 단행가처분의 경우, 가처분이 집행되면 원상회복이 불가능하거나 현저히 곤란하므로 실무상 이를 인용하는 예가 많지 않다.

나. 심리

(1) 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심사

이 유형의 가처분은 만족적 가처분이므로 이러한 종류의 가처분을 인용하기 위해서는 피보전권리는 물론 보전의 필요성에 관하여 고도의 소명이 있어야 한다. 즉 채무자의 항변이 인정되지 않는 무조건적인 인도 등 청구권의 존재가 명백하여 단행가처분의 집행으로 인하여 채무자의 정당한 권리가 침해될 가능성이 없고, 본안판결을 기다려 그에 기하여 강제집행을 하도록 할 경우 채권자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 위험이 있거나 채권자에게 가혹한 부담을 지우는 결과에 이르게 된다는 사정이 존재하여야 한다.

피보전권리나 보전의 필요성의 쌍방 또는 일방의 존재가 인정되지 않거나 채무자가 주장하는 반대사실이 적극적으로 소명되는 때에는 담보제공을 조건으로 신청을 인용할 것이 아니라 신청을 기각하여야 한다.

인도단행가처분의 보전의 필요성이 인정되는 예로는 이미 인도 강제집행이 마쳐진 건물에 채무자가 침입하여 다시 점유를 개시하거나 불법적인 점유침탈이 이루어진 직후인 경우, 또는 한두 세대의 인도 거부로 재건축사업이 지연되는 경우, 인도를 둘러싼 분쟁 중에 합의가 이루어져 합의금이 지급되었음에도 인도를 거부하는 경우, 채권자가 장래의 건물 이용계획을 세워두고 채무자에게 한시적으로 건물의 사용을 허락하였는데 채무자가 당초의 건물 이용계획에 따른 인도요구에 불응하는 경우, 임대차보증금이 미지급 차임으로 모두 공제되고 임차인의 비용상환청구권 등 항변사유가 존재하지 않음이 명백한 경우 등을 들 수 있으나, 동시이행항변 또는 유치권항변의 존부가 다투어지는 등 무조건적인 인도의
397 무의 존부에 의심이 있는 경우에는 단행가처분을 발령하는 데 신중하여야 한다.

토지소유권이나 주위토지통행권에 대한 방해금지가처분에서 이미 설치된 담장의 철거나 시설물의 수거를 통하여 신청의 목적을 종국적으로 달성할 수 있음에도 단순히 방해금지라는 부작위위무의 이행을 명하는 가처분을 구하는 경우가 있으나, 이러한 가처분이 발령되더라도 철거 등을 위한 대체집행은 허용되지 않으므로 주의하여야 한다.

(2) 심리방법

기일을 열어 심리하면 가처분의 목적을 달성할 수 없는 사정이 있는 때를 제외하고는

원칙적으로 변론기일이나 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 한다(민집 304조).

철거, 수거 등 단행가처분을 명할 경우에는 대체집행을 위한 수권결정까지 같이 하는 경우도 많은데, 수권결정을 함에 있어서는 결정 전에 채무자를 심문하도록 되어 있으나(민집 262조), 철거 등 단행가처분의 심리과정에서 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열고 있으므로 그러한 경우에는 문제될 것이 없다.

인도단행가처분 등의 심리가 장기화되면 단행가처분을 인정하는 취지에 부합하지 아니하므로 신속히 심리하는 것이 바람직하다.

(3) 담보

담보금액을 정할 경우에도 이 가처분에 의하여 채무자에게 주는 손해가 많다는 점을 감안하여야 한다. 건물인도(또는 퇴거) 단행가처분의 경우에는 채무자의 생활이나 영업을 위협하는 바가 크므로 채무자가 건물로부터 퇴거당함으로 인하여 입는 손해(예를 들면 다른 건물에 거주하기 위하여 필요한 비용, 상인의 경우는 그 건물에서 퇴거당함으로 인하여 입는 영업상의 손해 등)를 표준으로 담보금액을 정하여야 하고, 방해물의 철거단행가처분에서는 채무자가 방해물을 철거당함으로 인하여 입는 손해(예를 들면 방해물의 가액)를 표준으로 하여 담보금액을 정하여야 한다.

다. 주문례

건물의 철거 또는 물건의 수거 등을 명할 경우에는 대체집행을 위하여 가처분명령 중에 미리 건물의 철거, 물건의 수거 등을 위한 수권결정을 하는 경우가 많다.

(1) 기본형

채무자는 채권자에게 별지 목록 기재 부동산을 인도하라.

채무자는 채권자에게 20 . . . 까지 별지 목록 기재 부동산을 인도하라.

(2) 건물철거와 토지인도의 결합형

1. 채무자는 채권자에게 별지 목록 기재 토지 상의 같은 목록 기재 건물을 철거하고 위 토지를 인도하라.
2. 채무자가 이 명령 송달일부터 ○일 내에 위 건물을 철거하지 않을 때에는 채권자는 그가 위임하는 집행관으로 하여금 채무자의 비용으로 이를 철거하게 할 수 있다.

라. 집행

(1) 개요

인도를 명하는 가처분은 부동산 인도청구권의 강제집행방법에 의한다. 철거를 명하는 가처분은 그에 대한 대체집행의 수권이 가처분명령에 포함되어 있으면 따로 수권을 받을 필요가 없으나 대체집행의 수권이 없으면 대체집행의 신청을 하여 집행하여야 한다.

집행관 보관·채권자 사용형도 채무자의 점유를 현실로 해제하고 인도받아야 하므로 인도청구권의 강제집행방법과 같이 집행한다.

399 (2) 가처분의 집행과 본안소송의 관계

단행가처분의 집행에 의하여 피보전권리가 실현된 것과 마찬가지로의 상태가 사실상 달성되었다 하더라도 그것은 어디까지나 임시적인 것에 지나지 않고, 가처분이 집행됨으로써 그 목적물이 채권자에게 인도되었다 하더라도 본안소송에서는 그와 같은 잠정적인 상태를 고려함이 없이 그 목적물의 점유는 채무자에게 있는 것으로 보고 재판하여야 한다(대판 1996. 12. 23. 95다25770, 대판 2007. 10. 25. 2007다29515).

(3) 가처분의 집행정지 등

부동산인도나 건물철거 등 이행소송을 본안으로 하는 단행가처분에 대하여 이의신청이 있는 경우에, 이의신청으로 주장한 사유가 법률상 정당한 이유가 있다고 인정되고 주장사실에 대한 소명이 있으며 그 집행에 의하여 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이 있다는 사정에 대한 소명이 있는 때에는, 법원은 당사자의 신청에 따라 담보를 제공하게 하거나 담보를 제공하게 하지 아니하고 가처분의 집행을 정지하도록 명할 수 있고, 담보를 제공하게 하고 집행을 정지하도록 명할 수 있다(민집 309조). 민사집행법 288조 1항 또는 307조에 따른 가처분취소신청이 있는 경우에도 마찬가지로이다(민집 310조).

(4) 가처분의 취소와 원상회복

단행가처분의 집행이 완료된 뒤라고 하더라도 가처분집행에 의하여 인도된 물건의 반환이 가능한 경우가 있고 위법한 가처분결정에 기한 부당한 결과는 간단하고도 신속하게 원상으로 복귀시킬 필요가 있기 때문에 이 가처분에 있어서도 가처분취소재판을 할 수 있음은 물론, 가처분을 취소하는 재판에서 채무자의 신청에 따라 채권자에 대하여 가처분에 기초하여 인도받은 물건의 반환을 명하는 원상회복재판을 할 수 있다(민집 308조).

7. 가등기와 관련한 가처분

가. 가등기상의 권리행사금지가처분의 가부

가등기가 당초부터 무효이거나 매매예약의 해제 등의 사유가 있는 경우에도 가등기의 말소청구소송 중에 또는 그 승소판결 후 집행 전에 본등기가 이루어지면 가등기말소의 주문만으로는 실효가 없기 때문에 그 본등기를 막아 두고자 하는 뜻에서 그 가등기에 대한 말소등기청구권을 피보전권리로 하고, “채무자는 별지 목록 기재 부동산에 관하여 별지 목록 기재 가등기에 대한 가등기상의 권리를 행사하여서는 아니 된다.” 또는 “채무자는 별지 목록 기재 부동산에 관하여 별지 목록 기재 가등기에 관한 매매예약에 기한 소유권이 전등기청구권을 행사하여서는 아니 된다.”는 것을 신청취지로 하여 가등기상의 권리행사를 금하는 가처분을 신청하는 경우가 있다.

판례는 가등기에 터 잡아 본등기를 하는 것은 그 가등기에 기하여 순위보전된 권리의 취득(권리의 증대 내지 부가)이지 가등기상의 권리 자체의 처분(권리의 감소 내지 소멸)이라고는 볼 수 없으므로 가등기에 기한 본등기절차의 이행을 금지하는 취지의 가처분은 등기사항이 아니어서 허용되지 아니하고, 그러한 가처분이 잘못 기입등기되었다 하더라도 그 기재사항은 아무런 효력을 발생할 수 없으므로, 가처분채권자는 이러한 무효인 가처분 결정의 기입등기으로써 부동산의 적법한 전득자에게 대항할 수 없다고 한다(대판 1992. 9. 25. 92다21258, 대판 2007. 2. 22. 2004다59546).

나. 가등기상의 권리처분금지가처분

가등기상의 권리(대물변제예약 또는 매매예약상의 권리)를 타인에게 이전(양도)하는 것을 금지하는 가처분은 허용되고 등기할 수 있다(다만 소유권에 대한 가처분과 달리 가등기상의 권리에 대한 가처분은 부기등기로 기입한다). 이 가처분의 피보전권리는 ‘사해행위취소를 원인으로 한 가등기의 말소등기청구권’ 또는 ‘양도약정을 원인으로 한 가등기의 이전 등기청구권’ 등이 되고, 주문은 “채무자는 별지 목록 기재 부동산에 관하여 별지 목록 기재 가등기에 대한 가등기상의 권리를 다른 사람에게 양도, 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.” 또는 “채무자는 별지 목록 기재 부동산에 관하여 별지 목록 기재 가등기에 관한 매매예약에 기한 소유권이전등기청구권을 타인에게 양도, 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.”로 함이 일반적이다.

가등기상의 권리처분금지가처분의 기입등기가 마쳐진 후 채무자가 가등기상의 권리를

제3자에게 양도함으로써 마쳐진 가등기이전의 부기등기가 위 가처분의 효력에 저촉됨은 당연하다.

그렇다면 가등기이전의 부기등기에 기하여 본등기가 마쳐진 경우에도 가처분채권자가 본안승소 확정판결을 받아 본등기를 말소할 수 있을 것인가. 甲이 가등기권자 乙을 상대로 가등기상의 권리처분금지가처분결정을 받아 그 가처분기입등기가 마쳐진 이후에 乙의 가등기상 권리가 가등기이전의 부기등기의 방법에 의하여 丙에게 이전되고, 丙 명의로 가등기에 기한 본등기까지 마쳐진 경우에 가처분채권자 甲이 가처분의 피보전권리인 乙에 대한 가등기말소청구권에 기한 본안소송에서 승소하고 그 판결이 확정되었다면, 丙의 본등기는 가처분채권자 甲에게 대항할 수 없는 것으로서 甲이 그 확정판결의 정보를 첨부하여 乙 명의의 가등기와 丙 명의의 본등기의 말소신청을 하면 위 각 등기는 모두 말소될 운명이라 하여 이를 긍정함이 판례의 입장이다(대판 1992. 8. 14. 91다45806).

가등기상의 권리처분금지가처분의 기입등기가 마쳐진 후 채무자가 자신의 명의로 가등기에 기한 본등기를 마치고 즉시 제3자에게 소유권이전등기를 마쳐준 경우에 선행한 가처분의 처분금지 효력은 그 본등기상의 권리에도 미친다고 보는 견해가 다수설이다. 이 점에 관한 판례는 아직 없으나, 가등기상의 권리에 대한 ‘가압류’의 효력에 관하여는 가압류의 기입등기가 마쳐진 후 가등기에 기한 본등기가 마쳐지고 그에 터 잡아 제3자 명의의 소유권이전등기가 마쳐졌다면 제3자 명의의 소유권이전등기는 등기된 가압류채권자에 대한 관계에서 무효라는 것이 판례의 입장이다(대판 1998. 8. 21. 96다29564).

402 다. 가등기를 명하는 가처분명령

가등기의 신청에 관하여 가등기의무자의 협력을 얻을 수 없는 경우, 가등기권리자는 부동산소재지를 관할하는 지방법원에 가처분신청을 하여 가등기원인을 소명하여 가처분명령을 얻은 후에 그 명령의 정보를 첨부하여 단독으로 그 가등기를 신청할 수 있는데(부등 89조, 90조), 이를 가등기를 명하는 가처분명령이라고 한다(사건부호 : 비단, 비합).

이 가처분은 민사집행법상의 가처분과 같은 기능을 가지는 점도 있으나 그와는 다른 비송사건적인 성질을 가지고 있다. 즉 부동산등기법상의 가등기를 명하는 가처분명령은 당사자의 이해관계의 대립이 있음을 요건으로 하지 아니하는 보전처분으로 본등기의 순위보전의 효력밖에 없는 것이어서 민사집행법상의 가처분과는 성질이 달라 같은 법상의 가처분에 관한 규정을 준용할 여지가 없다(대결 1973. 8. 29. 73마657). 이 가처분명령은 가등기의무자의 승낙서(부등 89조)와 같은 등기신청에 있어서의 첨부서류에 지나지 않으

므로 가등기를 명하는 가처분명령이 있어도 법원이 직권으로 가등기를 촉탁하는 것이 아니라 가등기권리자가 그 가처분명령의 정본을 가등기신청서에 첨부하여 가등기를 신청하여야 비로소 가등기가 기입되며, 또한 이 가처분을 명하는 결정에 대하여는 불복이 허용되지 아니하고 민사집행법상의 가처분에 대하여 인정되는 이의, 취소의 절차도 인정되지 않으며, 다만 가등기 그 자체의 효력을 다투어 그 말소를 구할 수 있을 뿐이다. 가등기를 명하는 가처분명령 신청을 각하한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있고 즉시항고절차에는 비송사건절차법을 준용한다(부등 90조 2, 3항).

미등기 부동산이나 1필지의 토지 또는 1동의 건물의 일부에 관하여도 가등기를 명하는 가처분명령이 가능하다. 다만 부동산등기법 88조의 규정상 같은 법 3조에 규정된 물권 또는 부동산임차권의 변동을 목적으로 하는 청구권이 아닌 물권적 청구권을 보전하기 위한 가등기는 허용되지 아니하므로(대판 1982. 11. 23. 81다카11110) 결국 말소등기 및 회복등기의 가등기나 이에 관한 가등기가처분명령은 허용되지 않는다.

위 부동산등기법상의 가처분명령에 의한 가등기 이외에 민사집행법상의 가처분절차에 의하여 가등기를 명할 수는 없다.

한편 가등록(假登錄)을 명하는 가처분명령의 경우, 법원이 직권으로 등록관청(국토교통부, 광업등록사무소장, 환경부 등)에 가등록을 촉탁하여야 한다는 규정이 있다(공항시설관리권등록령 22조, 광업등록령 84조 1항 단서, 수도시설관리권 및 하수종말처리시설관리권 등록령 24조 1항, 어업등록령 113조 1항, 유료도로관리권등록령 24조 1항, 철도시설관리권등록령 22조 참조).

제2절 선박·항공기·자동차·건설기계에 대한 가처분

1. 개요

가. 선박·항공기·자동차·건설기계의 개념에 대하여는 그에 대한 강제집행 부분 참조.

나. 이들 물건은 등기·등록에 의하여 권리가 이전되는 면에서 부동산에 준하면서 실제로는 이동하므로 동산의 성질을 가진다. 따라서 가처분에 있어서도 이러한 성질이 참작되어야 한다. 이들에 대한 가처분으로는 소유권 등 권리이전을 금하는 처분금지가처분과 점유의 이전을 금하는 점유이전금지가처분이 있는바, 위와 같은 속성 때문에 두 가지를 겸한

가처분도 많이 쓰인다.

다. 선박에 있어서 항해의 준비를 완료한 선박과 속구의 압류·가압류금지규정(상 744조)이 가처분에도 적용되는가에 관하여는 논의가 있으나 소극적으로 해석할 것이다.

404 2. 처분금지가처분

가. 신청과 심리

선박·항공기·자동차·건설기계의 처분금지가처분신청에는 그 등기사항증명서·등록원부 등본을 첨부하여야 하며 그 외에는 가압류에 준하여 생각하면 된다.

주문례는 다음과 같다.

채무자는 별지 목록 기재 자동차에 대하여 매매, 양도, 저당권설정 그 밖에 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.

등록의 대상이 되는 자동차, 건설기계, 항공기, 소형선박은 자동차 등 특정동산 저당법 9조에 의해, 선박(등기선박)은 상법 789조에 의해 질권 설정이 금지되어 있으므로 질권 설정을 금지하는 문구를 삽입할 필요가 없다.

나. 집행

단순한 처분금지가처분은 소관관청에 가처분의 기입등기(등록)를 촉탁함으로써 한다. 그 촉탁방법은 부동산처분금지가처분 촉탁등기에 준한다.

과세표준은 1건(자동차 등이 여러 대일 때에는 1대당 1건)이며, 등록면허세액은 선박, 자동차가 건당 15,000원(지방세 28조 1항 2호 다목, 3호 라목), 건설기계는 건당 10,000원(지방세 28조 1항 4호 라목), 항공기는 건당 12,000원(지방세 28조 1항 14호)이며, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20이다(지방세 151조 1항 2호). 다만, 자동차, 건설기계 중 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭은 비과세이다(지방세 150조 2호, 124조, 지방세령 120조)

405 3. 점유이전금지가처분

가. 총설

자동차 등의 인도청구권을 보전하기 위해서는 점유이전금지가처분을 신청하여야 한다. 그런데 자동차 등은 이동성을 속성으로 하고 있어 채무자에게 사용을 허가하면 가치가

떨어지거나 그 소재를 파악하기 어렵게 되는 경우가 있다. 따라서 자동차·건설기계에 있어서는 채무자에게 사용을 허가하지 아니한 채 집행관 보관을 명하고, 항공기·선박에 대하여는 일정장소에 정류, 정박할 것을 명하는 것이 보통이다. 다만 이는 채무자의 자동차 등에 대한 경제적 이용을 박탈하게 되므로 신중을 기하여야 한다.

나. 자동차·건설기계·소형선박의 점유이전금지가처분

(1) 주문례

1. 채무자는 별지 목록 기재 자동차에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

가처분 시의 집행관 보관방법에 관하여는 명문의 규정이 없으므로 가압류집행의 경우에 준하여 집행관은 상당하다고 인정할 때에는 채권자, 채무자, 그 밖의 적당한 사람에게 보관시킬 수 있다. 이처럼 제3자에게 보관하게 한 경우에는 공시서를 붙여두거나 그 밖의 방법으로 자동차 등을 집행관이 점유하고 있음을 분명하게 표시하고, 운행하지 못하도록 적당한 조치를 하여야 한다(민집규 115조, 210조 3항, 211조, 215조). 집행관은 그의 재량으로 보관장소, 보관방법을 변경할 수 있다(민집규 114조 2항, 210조 3항, 211조, 215조).

실무상 채무자에게 자동차·건설기계를 보관시키는 경우는 거의 없고, 비용이 많이 드는 등의 이유로 채권자나 그가 지정하는 차고 등에 보관시키는 경우가 많다. 채권자에게 보관시키는 것을 허용하는 경우에는 1, 2항 사이에 “집행관은 채권자의 신청이 있으면 사용하지 아니할 것을 조건으로 채권자에게 보관을 명할 수 있다”고 기재한다.

(2) 집행

집행은 결정 정본을 채권자가 집행관에게 제출하여 위임한다. 이때에는 수수료 외에 보관료 등의 비용까지 예납하여야 한다.

다. 선박·항공기의 점유이전금지가처분

(1) 주문례

(가) 항공기의 경우

자동차·건설기계와 같게 하거나 아래와 같이 기재한다.

1. 채무자는 별지 목록 기재 항공기에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
2. 집행관은 채무자로 하여금 위 항공기를 ○○공항에 정류하게 하고 현상을 변경하지 아니할 것을 조건으로 채무자에게 그 보관을 명할 수 있다.
3. 채무자는 별지 목록 기재 항공기에 대한 점유를 타인에게 이전하거나 점유명의를 변경하거나 이를 운행하여서는 아니 된다.
4. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

(나) 선박의 경우

항공기에 대한 위 주문례 중 “○○공항에 정류하게 하고”를 “○○항의 집행관이 명하는 장소에 정박시키고”로 바꾸는 외에는 같다(채무자에게 보관을 명하는 부분을 “사용하게 할 수 있다”로 바꾸기도 한다).

(2) 집행

채권자가 가처분명령 정본을 그 항공기·선박이 정류·정박 중인 곳의 관할지방법원 소속
407 집행관에게 제출하고 그 집행을 위임한다. 실무상으로는 집행관으로 하여금 그 채무자에게 송달할 결정 정본을 집행할 때 송달하게 한다. 다만, 2016. 3. 23. 제정된 항공안전법은 ‘정류’ 대신에 ‘주기(駐機)’라는 용어를 사용하고 있다(54조, 91조 1항 15호 참조).

제3절 유체동산에 대한 가처분

1. 점유이전금지가처분

가. 개요

동산에 대한 가처분은 점유이전금지가처분이 거의 전부라고 해도 과언이 아니다. 동산의 경우에는 점유이전금지 없이 처분만을 금지하는 가처분을 하더라도 양수인이 선의취득의 규정에 따라 유효하게 소유권을 취득하는 경우가 많아 실효가 없어서 부동산의 처분금지가처분과 같은 목적을 달성하기 위해서도 동산의 경우에는 점유이전금지가처분과 함께 또는 점유이전금지가처분만을 구하게 된다.

동산은 부동산과 달리 그 점유사용을 누가 하느냐에 따라 물건의 가치보존이 많이 달라진다. 동산의 경우에는 채무자의 점유를 풀고 집행관으로 하여금 직접 이를 보관하게 함이

원칙이고 그 외 채무자에게 사용을 허가하거나 채권자로 하여금 보관하게 하는 유형의 가처분도 많이 사용된다. 채무자의 사용을 허락하지 않는 경우에 목적 동산의 보관장소, 비용 등의 관계로 실무에서는 사실상 채무자에게 보관케 하는 예가 많으나 그러한 경우에는 집행관은 언제든지 보관방법을 변경할 수 있다. 그리고 일단 채무자에게 보관하게 한 후에 채무자가 보관물을 처분할 염려가 있는 등 사정변경이 있는 경우에는 집행관이 이를 회수할 필요가 있으나 그러한 사정이 없는데도 집행관이 스스로 보관하고자 하는 경우에는 채무자는 집행에 관한 이의를 할 수 있다.

유체동산에 대한 처분금지는 통상 “양도, 질권 설정 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.”고 하는 문례가 많으나 유체동산에 관하여는 공시방법이 없으므로 그와 같은 처분금지가처분만으로는 실효성이 없어 처분금지만을 신청하는 경우는 적으며, 오히려 동산의 점유를 집행관보관으로 하고 채무자에게 사용케 하는 점유이전금지가처분을 하면서 채무자의 처분을 금지하는 주문을 함께 적는 경우가 많다. 408

집행관이 동산을 점유하는 경우에도 채무자는 이를 제3자에게 점유개정(민 189조) 또는 목적물 반환청구권 양도(민 190조)의 방법으로 인도하는 것이 가능하며, 다만 가처분채권자에게 그 인도로서 대항할 수 없을 뿐이다.

기계·기구류와 같이 채무자가 이를 사용하지 못하게 되면 큰 손실을 받을 수 있는 물건은 채무자의 점유사용을 금지하는 가처분을 함에 있어 신중한 심리가 요구되고, 이 경우 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에 준하여 심문기일을 여는 것이 다수의 실무례이다.

동산점유이전금지가처분의 집행은, 부동산과 마찬가지로 채권자가 집행관에게 집행을 위임하면 집행관이 자신의 보관 하에 있음을 밝히는 공시를 목적물에 붙이고 채무자에게 그 취지를 알리는 방법으로 한다. 구체적인 집행방법 및 그 효력에 관하여는 부동산점유이전금지가처분에 관한 제1절 2. 마. 집행과 그 효력 부분 참조.

나. 신청과 주문례

(1) 신청

동산점유이전금지가처분을 신청할 때에는 그 대상이 되는 동산을 명칭, 종류, 수량 등으로 반드시 특정하여야 하고 현재 그 물건의 소재지를 명시하여야 한다. 또 담보공탁금의 산정 편의를 위하여 그 가액의 산출자료를 첨부하여야 한다.

409 (2) 주문례

(가) 집행관 보관만을 명하는 경우

1. 채무자는 별지 목록 기재 물건의 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

(나) 채무자에게 사용을 허가하는 경우

1. 채무자는 별지 목록 기재 물건에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
2. 집행관은 현상을 변경하지 않을 것을 조건으로 하여 채무자에게 사용을 허가하여야 한다(또는허가하여야 하며, 채무자가 그 현상을 변경하였을 때에는 채무자에 대하여 그 사용을 금지할 수 있다).
3. 채무자는 (위 물건에 관하여 양도, 질권 설정, 그 밖의 처분을 하거나) 그 점유를 타인에게 이전하거나 또는 점유명의를 변경하여서는 아니 된다.
4. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

(다) 채권자에게 보관시키는 경우

1. 채무자는 별지 목록 기재 물건에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
2. 집행관은 위 물건을 사용하지 않을 것을 조건으로 하여 채권자에게 이를 보관하게 할 수 있다.
3. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

2. 동산인도단행가처분

가. 개요

동산의 경우에도 채권자의 인도청구권 보전을 위해서 또는 채권자에게 임시의 지위를 부여하기 위하여 인도단행가처분을 할 수 있다. 채권자가 일단 점유이전금지가처분을 한 후에 동일 목적물에 대하여 다시 인도단행가처분을 하더라도 1차 점유이전금지가처분을 폐지·변경하는 것이 아니므로 1차 가처분 후에 생긴 사정의 변경으로 단행가처분의 필요가 새로 생겼다면, 점유이전금지가처분이 된 목적물에 대하여 재차 인도단행가처분을 발령할 수 있다.

나. 주문례

(1) 기본형

채무자는 채권자에게 별지 목록 기재 물건을 (임시로) 인도하라.

(2) 점유이전금지가처분에 따른 집행관 보관물에 대하여 재차 인도단행을 명하는 경우

위 당사자 간의 이 법원 20 카합 가처분사건에 관한 20 . . . 가처분결정에 의하여 집행관이 보관 중인 별지 목록 기재 물건에 관하여 집행관은 그 점유를 풀고 채무자는 채권자에게 이를 임시로 인도하라.

3. 사용금지가처분

가. 개요

소유권 등에 기한 유체동산 인도청구권의 집행보전을 위하여 점유이전금지가처분을 구하면서 채무자의 사용을 불허하는 가처분을 구하거나, 인도청구권을 피보전권리로 하여 임시의 지위를 정하기 위한 가처분으로서 곧바로 채무자에 대하여 유체동산의 사용금지가처분을 구하는 경우가 있다.

자재공급업체가 소유권유보부매매계약에 기하여 자재를 공급하였는데 시공사가 부도처리되었다거나 리스회사가 리스물품에 대한 리스계약이 해지되었음을 이유로 신청하는 경우가 많은데, 대부분은 소유권에 기한 인도청구권을 보전하기 위한 것이라기보다는 물품대금이나 리스료 지급을 압박하려는 데 목적이 있다.

동산인도청구권의 집행보전은 점유이전금지가처분에 의하는 것이 원칙이고, 점유이전금지가처분에서는 현상을 변경하지 않을 것을 조건으로 채무자에게 사용을 허가하는 주문을 발령하는 것이 일반적이므로, 유체동산의 사용금지를 명하는 가처분은 목적물의 사용으로 인하여 현상이 변경 훼손되거나 그 가치가 현저히 하락된다는 등의 특별한 사정에 대한 소명이 있는 경우에 한하여 예외적으로 허용한다. 411

나. 주문례

채무자는 별지 목록 기재 물건을 사용하여서는 아니 된다.

제4절 채권과 허가권 등에 대한 가처분

1. 채권의 추심 및 처분금지가처분

가. 개요

(1) 채권의 존부에 관한 다툼이 있는 경우

채권의 존부에 대한 다툼이 있을 때 채무자는 채권자로부터 그 이행의 청구를 받아도 이를 거절할 수 있기 때문에 채무자가 채권자를 상대로 자기에 대한 채권의 추심을 금지하는 가처분을 할 필요는 없다. 그러나 그 채권이 허위표시로 성립되었다고 할 때에는 그 채권이 선의의 제3자에게 양도되면 대항할 수 없는 경우가 생길 뿐 아니라, 선의의 제3자에게 대항할 수 있다고 하더라도 당사자의 항정이 필요할 수도 있으므로, 채권자로 하여금 제3자에게 이를 처분할 수 없도록 금지할 필요가 있다.

(2) 채권의 귀속에 관한 다툼이 있는 경우

412 한편 채권의 양도에 다툼이 있는 경우 채권을 양수한 권리를 보전하기 위해서는 원래의 채권자를 채무자로 하여 채권의 추심을 금함과 동시에 그 채권이 다시 제3자에게 처분되는 것을 금지하는 가처분을 받을 필요가 있다. 그 외에도 채권이 이중으로 양도되어 두 사람의 양수인 사이에서 채권의 귀속에 대한 분쟁이 생긴 경우에 어느 한쪽이 다른 쪽에 대하여 채권의 추심을 금지하거나, 부동산 소유권에 관하여 분쟁이 있는 경우 분쟁의 상대방에게 임차인으로부터의 임대료의 추심을 금지할 필요도 있다. 채권양도가 사해행위임을 주장하며 수익자인 양수인을 상대로 그 채권에 대한 가처분을 구하거나, 근저당권 설정이 사해행위임을 주장하며 수익자인 근저당권자에게 배당된 배당금채권에 대한 가처분을 구하는 경우도 많다.

어느 경우이거나 당해 채권은 양도 가능한 것이어야 한다.

나. 주문례

(1) 채권의 존부 등에 관하여 다툼이 있어 그 다툼의 대상인 채권의 채무자가 채권자만을 상대로 하는 경우

채무자는 별지 목록 기재 채권을 타인에게 양도하거나 질권 설정, 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.

채권의 표시방법은 채권가압류 부분 참조.

(2) 채권의 귀속 등에 관하여 다툼이 있어 제3채무자에 대한 채권의 추심 및 처분금지가처분을 구하는 경우

1. 채무자는 제3채무자로부터 별지 목록 기재의 채권을 추심하거나 타인에게 양도, 질권 설정, 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권을 지급하여서는 아니 된다.

채권의 표시방법은 채권가압류 부분 참조.

(3) 임차권 관련 추심 및 처분금지가처분

413

1. 채무자는 제3채무자로부터 별지 목록 기재의 임차권에 기한 임대차보증금을 추심하거나, 임차권을 타인에게 양도, 질권 설정, 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.
2. 제3채무자는 채무자에게 임대차보증금을 반환하거나 채무자의 청구에 의하여 임차인의 명의변경을 하여서는 아니 된다.

다. 집행과 그 효력

채권가압류와 마찬가지로 발령법원이 집행법원이 되며(민집 296조 2항, 301조) 따로 집행신청이 필요 없다.

위 (1)의 채권의 처분금지가처분은 가처분채무자에게 통지함으로써 집행을 완료하게 된다. 그러나 이 가처분은 공시방법도 없고 제3자의 양수를 금하는 효력도 없어 실효성이 적다.

위 (2)의 채권의 추심 및 처분금지가처분은 제3채무자에게 가처분명령 정본을 송달하여야 하며 가처분의 효력으로 가처분채무자의 추심, 양도 등의 처분행위와 제3채무자의 변경이 금지되고 이에 위반되는 행위는 가처분채권자에게 대항할 수 없다. 집행채권자의 채권자가 집행권원에 표시된 집행채권에 대하여 처분금지가처분을 한 경우에는 집행기관은 가처분이 해제되지 않는 한 집행할 수 없어 이는 집행장애사유에 해당한다(대결 2000. 10. 2. 2000마5221).

다만 부동산의 전득자가 양수인 겸 전매인을 채무자, 양도인을 제3채무자로 하여 “채무자는 제3채무자에 대한 소유권이전등기청구권 그 밖에 분양계약상의 권리를 양도하는 등 일체의 처분행위와 권리의 행사를 하여서는 아니 된다. 제3채무자는 채무자에게 소유권이전등기를 하여서는 안 된다”는 부작위를 명하는 가처분을 하였더라도 그와 같은 내용의

가처분은 등기될 수 없어서 부동산 자체의 처분행위를 금하는 효력은 없으므로, 가처분 후 부동산을 취득한 제3자 명의의 등기는 유효하다(대판 1989. 5. 9. 88다카6488).

- 414 그런데 채권의 추심 및 처분금지가처분이 있는 경우에도 채권가압류와 마찬가지로 가처분채권자는 그 채권에 관하여 일체의 보관처분 권능을 박탈당하는 것이 아니고 가처분채권자의 권리를 해하지 아니하는 범위 내에서 유효하게 권리행사를 할 수 있다. 즉 채권의 보전행위 등을 위하여 채권의 확인을 구하거나 그 이행의 소를 제기할 수 있다. 따라서 이러한 보전행위를 게을리하여 소멸시효가 완성되었다 하더라도 그 가처분이 존속 중임을 이유로 하여 가처분채권자에게 손해배상을 구할 수 없다. 또한 부동산소유권이전등기청구권의 처분금지가처분이 있더라도 채무자는 제3채무자를 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기할 수 있으나, 이 경우 법원은 가처분의 해제를 조건으로 하여서만 청구를 인용할 수 있다(대판 1998. 2. 27. 97다45532, 대판 1999. 2. 9. 98다42615).

2. 허가권 양도금지가처분

가. 개요

식품위생법, 자동차관리법, 여객자동차 운수사업법, 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 등 개별법에서 영업양도에 수반하여 영업허가명의를 변경을 허용하고 있는 경우에, 그 영업을 양수한 자가 양도인을 상대로 허가명의변경절차이행청구권을 피보전권리로 하여 허가권의 처분금지를 구하는 가처분을 신청할 수 있는가. 과거에는 이에 관한 공시방법이 없다는 이유로 이를 허락하지 않았으나, 양수인이 가처분명령을 행정청에 제출하면 행정청이 양도인에 의한 명의변경을 거절하고 있어 실질적으로 가처분의 효력을 이룰 수 있다는 점을 고려하여 이제는 폭넓게 허용하고 있는 것이 실무례이다.

이 경우 당해 허가를 한 행정청이나 허가를 관장하는 국가 또는 지방자치단체를 제3채무자로 하여 허가명의를 변경하여 주지 말 것을 함께 명할 수 있는지가 문제되는데, 이러한 가처분이 가능하다는 반대 견해도 있으나, 대법원판례는 민사집행법상의 가처분으로 행정청의 행정행위 금지를 구하는 것은 허용될 수 없다고 판시하였고(대결 2011. 4. 18. 2010마1576), 이에 따라 위와 같은 가처분신청을 각하하는 것이 다수의 실무이다.

- 415 또한 소관 행정청에 대하여 위와 같은 가처분결정이 있음을 고지할 사실상의 필요가 있다는 이유로 결정문의 당사자표시란에 소관청을 표시하고 결정문을 소관청에도 송달해야 한다는 견해도 있으나, 소관청에 대하여 아무런 의무 부과가 없는 결정문을 송달할 근

거가 없고 그러한 송달 때문에 소관청에 혼란을 줄 수 있기 때문에 결정문에 소관청을 표시하지 않고 송달도 하지 않는 것이 다수의 실무이다.

나. 주문례

채무자는 별지 목록 기재 자동차운송사업면허권에 대하여 매매, 증여, 질권 설정, 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.

3. 건축허가명의 처분금지가처분

가. 개요

건축허가명의의 양도 계약이 있는 경우에는 위에서 본 허가권 처분금지가처분과 마찬가지로 처리하면 될 것이다.

건축 중 미등기 건물을 매수한 매수인(수분양자)이 건축주인 매도인의 처분을 금지하고 권리를 확보하기 위한 수단의 하나로써 건축허가명의의 처분금지를 구하는 경우가 상당수 있다. 채무자가 채권자에게 신축 중인 건물(대부분 단독주택 등의 소규모 건물임)의 소유권이전등기를 마쳐주기로 하였음에도 완공되지 않은 상태에서 이를 타인에게 처분하려고 하는 경우, 신축건물 소유권과 더불어 그 건축주명의로 이전하기로 하는 약정이 있는 것으로 보고 건축주명의로 대한 처분금지가처분을 허용해주기도 한다.

이와 같이 건축허가상의 권리의무를 포괄적으로 양수한 것이 아니라 장차 완공될 특정 부동산을 매수한 사람에게 건축허가명의의 처분금지를 구할 권리가 있는가.

종래에는 미등기 건물에 대한 처분금지가처분이 허용되지 않는 점을 고려하여 건물이 사실상 완공되어 민법상 독립된 건물로서의 요건을 갖춘 경우에는 건축허가명의의 처분금지가처분을 허용하고 그렇지 아니한 경우에는 허락하지 않는 것이 실무였으나, 이제는 건축법에 따른 건축허가 또는 건축신고를 적법하게 마쳤으나 사용승인을 얻지 않아 보존등기를 마치지 못한 건물에 대하여는 부동산집행의 방법으로 집행할 수 있게 되었으므로 이에 의하는 것이 타당할 것이다.

나. 효력

가처분결정을 송달하는 외에 현행법상 등기부에 공시할 방법이 없는 건축허가명의 처분

금지가처분 등은 대물적 효력이 인정되지 아니하므로, 제3자가 채무자로부터 실제로 권리를 양수하여 소유권보존등기를 하였다면 가처분을 내세워 그 권리취득의 효력을 부인할 수 없다(대판 1997. 5. 7. 97다1907 참조).

다. 주문례

채무자는 별지 목록 기재 건축허가에 관하여 건축주명의를 변경하여서는 아니 된다.

4. 미등기 건물 수분양자의 권리 관련 처분금지가처분

미등기 건물을 분양받은 자가 이를 매도(담보 설정한 경우도 같다)한 경우에 그 양수인이 자신의 권리를 보호받기 위하여 가처분을 신청한 때에는 수분양자가 그의 분양계약상의 지위 내지는 분양계약으로 말미암은 소유권이전등기청구권을 양도한 것인가 아니면 미등기 건물을 전매한 것인가에 따라 가처분을 달리하여야 할 것이다.

가. 수분양자 명의변경금지가처분

수분양자의 분양계약상의 지위 내지는 분양계약으로 말미암은 소유권이전등기청구권을 양도한 경우에는 미등기 전매라는 문제는 있으나 사법상 효력은 유효라고 보아야 할 것이다. 수분양자가 양도사실을 분양자에게 통지하면 채권양도의 효력이 생긴다. 법령 417 이나 분양계약의 약관이 분양권의 양도를 허용하는 경우가 아니라면 분양자의 동의나 승낙을 받아야 효력이 생긴다고 보아야 한다(대판 2001. 10. 9. 2000다51216 참조).

양수인이 분양자에 대하여 수분양자의 권리를 주장할 수 있는 경우, 수분양자와 양수인 사이에 양도의 효력에 대한 다툼이 없더라도 분양대장이 작성되어 그 명의에 터 잡아 분양계약상의 지위가 인정되는 때에는 수분양자를 채무자, 분양자를 제3채무자로 한 수분양자 명의변경금지가처분을 허용할 수 있을 것이다. 만약 양수인과 수분양자 사이에 양도의 효력에 대한 다툼이 있는 경우에는 수분양자를 채무자로 하여 통상의 채권처분 및 추심금지가처분이 가능할 것이고, 필요에 따라서는 분양자를 제3채무자로 하여 수분양자대장상의 수분양자 명의변경금지를 구할 수도 있을 것이다.

분양자가 수분양자에 대한 분양계약의 효력을 다투면서 분양계약상의 지위 양도를 인정하지 아니하는 경우에 양수인이 분양자를 상대로 직접 분양권의 처분금지가처분을 구

할 수 있는가. 소유자인 분양자가 가지는 분양권이란 소유물 처분권한을 말하는 것으로서 독립된 채권이라고 할 수 없으므로 분양권의 처분금지는 허용되지 않는다.

한편 수분양자 등이 분양자를 상대로 분양행위 자체의 금지를 구하는 분양금지가처분을 신청할 수 있는가. 이는 부작위의무를 명하는 임시의 지위를 정하기 위한 가처분으로 볼 것인데, 제3자에 대한 공시방법이 없어 실효성이 없다고 보아 인정하지 않는 견해가 있으나, 법률적 분쟁에 관한 법원의 공권적 판단으로 채무자에 대하여 특정한 금지의무를 명하는 이상 전혀 실효성이 없다고 보기 어렵고 그러한 금지의무의 이행을 담보하기 위하여 간접강제를 명할 수도 있음을 이유로 분양금지가처분을 허용하는 것이 다수의 실무이다.

나. 소유권이전등기청구권 처분금지 및 소유권이전등기절차 이행금지가처분

분양계약 상의 권리를 양도하는 것이 아니라, 미등기 건물 자체를 전매한 경우에(甲→ 418
乙→丙) 최종매수인(丙)이 매수인(乙)을 채무자, 매도인(甲)을 제3채무자로 하여 乙에 대하여는 제3자에게 소유권이전등기청구권을 처분하지 말 것을 구하고, 甲에 대하여는 乙에게 소유권이전등기절차를 이행하지 말 것을 구하는 가처분을 신청하는 예가 있는데, 그 허용 여부에 관하여는 견해 대립이 있다.

乙을 상대로 제3자에 대한 소유권이전등기청구권의 처분금지를 구하는 부분에 관하여 보면, ① 丙이 乙로부터 양수한 것은 소유권이전등기청구권이 아니라 부동산 자체라는 점에서 이러한 가처분은 피보전권리가 인정될 수 없다는 견해와, ② 다툼의 대상에 관한 가처분은 '현상이 바뀌면 당사자가 권리를 실행하지 못하거나 이를 실행하는 것이 매우 곤란할 염려가 있을 경우'에 하는 것인데, 乙이 제3자에게 甲에 대한 소유권이전등기청구권을 양도함으로써 현상이 변경되면, 丙의 乙에 대한 소유권이전등기청구권을 행사하는 것이 불가능해지거나 곤란해지므로, 그러한 현상의 변경을 금지하는 내용의 가처분을 받고자 하는 것을 막을 이유는 없다는 견해로 나누어진다.

甲을 상대로 乙에 대한 소유권이전등기절차의 이행금지를 구하는 부분에 관하여 보면, ① 가처분의 피보전권리가 丙의 乙에 대한 소유권이전등기청구권임에도 그 보전을 위하여 乙의 甲에 대한 소유권이전등기청구의 이행금지를 구하는 것은 민사집행법이 정한 다툼의 대상에 관한 가처분으로 볼 수 없고, 전매계약의 이행을 위해서는 甲으로부터 乙에게로 소유권 이전이 이루어져야만 하는데 丙이 그 이행금지를 구함은 자기모순이라는 이유로 이는 허용될 수 없다는 견해가 있고, ② 甲으로부터 乙에게 소유권이전등기가 이루어

어지면 그 현상변경으로 말미암아 丙의 乙에 대한 소유권이전등기청구권의 실행이 현저히 곤란해질 수 있는 점, 부동산 소유권이전등기청구권 가압류의 경우, '제3채무자에 대하여 채무자에게 소유권이전등기를 넘겨주지 못하도록 금지하는 것'이 형식적으로는 본 집행 단계에서 채무자 명의로 소유권이전등기를 마친 뒤 부동산에 대한 환가절차를 밟는 것과 배치되는 것처럼 보이지만, 그러한 금지명령은 결국 채무자의 부동산 소유권이전등기청구권이나 그 부동산 자체에 대한 처분행위를 막아 채권자의 금전채권을 만족시켜 주기 위한 것이라는 점에서 금전채권의 만족이라는 가압류의 궁극적인 목적과 모순되는 것이 아닌 것처럼, 전매형 거래에서 부동산 소유권이전등기청구권 처분금지가처분으로 제3채무자(甲)가 채무자(乙)에게 등기를 넘겨주지 못하도록 금지하는 것도 결국에는 채무자가 그 부동산을 제3자에게 처분하는 것을 막아 채권자(丙)의 채무자(乙)에 대한 소유권이전등기청구권을 실현할 수 있도록 하는 것이라는 점에서 채권자가 본안소송을 통하여 달성하려는 궁극적인 목적과 모순되는 것이라고 볼 수는 없는 점, 또 일단 처분금지가처분이 이루어지면, 적어도 채권자가 본안소송을 준비하는 동안 제3채무자는 처분금지가처분을 근거로 채무자에 대한 등기이전을 거절할 수 있어 채무자의 처분행위를 원천적으로 봉쇄할 수 있을 뿐 아니라, 가처분에 반한 제3채무자의 행위로 인하여 결국 채무자가 제3자에게 부동산을 처분함으로써 채권자가 손해를 보게 되었다면 채권자는 제3채무자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있는 점 등을 이유로 위와 같은 가처분이 허용되어야 한다는 견해가 있다.

판례는 이러한 가처분신청이 허용됨을 전제로 하여 “채무자는 소유권이전등기청구권을 양도하거나 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다. 제3채무자는 채무자에게 소유권이전등기절차를 이행하여서는 아니 된다.”라는 가처분명령이 집행된 후 채무자가 제3채무자를 상대로 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소를 제기한 경우에 법원은 가처분의 해제를 조건으로 하여서만 소유권이전등기절차의 이행을 명할 수 있다고 한다(대판 1999. 2. 9. 98다42615). 하지만 이러한 가처분명령은 채무자가 소유권이전등기청구권을 임의로 처분하는 것을 금지하는 효력만 있고 소유권이전등기청구권에 대한 후행 가압류나 후행 압류에 우선하는 효력은 없으므로, 후행 압류권자가 추심명령을 얻어 제3채무자를 피고로 하여 채무자에게 소유권이전등기절차를 이행할 것을 구하는 추심의 소를 제기한 경우에 법원은 가처분의 해제를 조건으로 하지 말고 소유권이전등기절차의 이행을 명해야 한다(대판 2001. 10. 9. 2000다51216).

다. 주문례

420

(1) 수분양자 명의변경금지가처분

1. 채무자는 별지 목록 기재 부동산에 관한 분양권을 타인에게 양도하거나 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.
2. 제3채무자는 채무자의 신청에 따라 위 분양권의 명의를 변경하여서는 아니 된다.

(2) 전매형 소유권이전등기청구권 처분금지가처분

1. 채무자는 별지 목록 기재 부동산에 관한 소유권이전등기청구권을 타인에게 양도하거나 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 부동산에 관한 소유권이전등기절차를 이행하여서는 아니 된다.
(제3채무자는 위 소유권이전등기청구권에 관한 채무자의 양도 등 처분행위에 대하여 동의나 승낙을 하여서는 아니 된다.)

5. 무허가건물관리대장의 명의변경금지가처분

가. 개요

행정절차상 무허가건물관리대장의 소유명의를 기준으로 철거에 따른 건물보상과 아파트분양권이 주어지고, 당사자 쌍방이 신청하면 대장관리청에서도 명의변경을 하여 주고 있으며, 본안소송으로도 일정한 요건하에 명의변경절차이행의 소를 인정하고 있으므로 판례가 요구하는 일정한 요건 하에 무허가건물관리대장상의 명의변경금지가처분을 인정하는 것이 실무이다(대판 1992. 4. 28. 92다3847 참조).

대장관리청을 제3채무자로 표시하거나, “제3채무자는 채무자의 신청으로 제3자에게 명의변경을 하여 주어서는 아니 된다.”라는 주문이 허용될 수 있는지와 소관청에 대한 송달이 필요한지 등에 관하여는 전술한 허가권 양도금지가처분의 경우와 같이 부정하는 것이 다수의 실무이다.

나. 주문례

421

채무자는 별지 목록 기재 건물에 관한 무허가건물관리대장상의 명의를 변경하여서는 아니 된다.

6. 금전의 지급을 구하는 가처분

가. 개요

금전지급의무의 존부 또는 금전지급의무를 수반하는 법률관계(고용, 부양 등)의 존부에 관한 다툼이 있고 소송을 통한 법률관계의 확정 전에 금전채무의 일부 또는 전부를 지급받지 못하면 채권자에게 현저한 손해가 발생할 염려가 있는 경우 임시로 금전의 지급을 명하는 가처분이다. 임시의 지위를 정하기 위한 가처분으로서 교통사고 등으로 인한 손해배상 청구권이 있을 때에 우선 치료비의 지급이 필요하다든가, 해고가 무효이고 근로자의 생계 유지에 필요한 생활비의 지급이 요구되는 경우 등에 많이 이용된다.

실무상 가장 흔히 볼 수 있는 유형은 교통사고로 인한 손해배상을 구하는 본안소송 제기와 동시에 또는 계속 중에 보험회사를 상대로 치료비 지급을 구하는 가처분과 임금 지급을 구하는 가처분이 있는데, 후자에 관하여는 노동사건에 관한 가처분에서 따로 논하기로 하고 여기에서는 치료비지급가처분을 중심으로 설명한다.

나. 신청과 심리

422 금전의 지급단행을 명하는 가처분을 신청할 때에는 그 금전채권의 존재와 함께 급박하게 지급되어야 할 필요가 있는 금액의 산출근거도 소명하여야 한다. 이 가처분은 임시의 지급을 명하는 것이기는 하지만 금전이 실제로 지급되고, 지급된 금전은 소비되어 버린다는 점에서 채무자에게 회복할 수 없는 손해를 입힐 수가 있으므로, 신중한 심리가 필요하다. 한편 이 가처분의 채권자는 대체로 경제적 약자로서 당장 금전이 지급되지 않으면 심한 곤궁에 빠지게 되므로 가능한 한 심리기간을 단축할 것이 요구된다.

치료비 지급을 구하는 가처분은 가처분채권자가 교통사고라는 예상치 못한 사태로 인한 거액의 금전적 필요에 대처할 능력이 부족하고, 치료비 부담으로 인하여 향후 치료에 어려움을 겪거나 치료를 포기해야 하는 경우가 많으므로, 다른 금전지급가처분에 비하여 비교적 보전의 필요성이 높다.

가처분을 발령할 때에는 미납 치료비, 향후 치료비에 대한 일시금의 지급을 명하는 경우가 있고, 일시금과 향후 치료비에 대한 정기금의 지급을 동시에 명하는 경우도 있다. 지급의 범위는 치료비에 한정하는 경우가 많으나, 가족의 생계를 책임지던 피해자가 치료로 인하여 수입 전부를 상실하고 있는 등의 사정이 있는 경우에는 생계비도 지급의 범위에 포함할 수 있다. 치료비 지급을 명하는 경우에도 본안소송에서 다툼의 여지가 있는 부분 등을 고려

하여 미납 치료비나 향후 치료비 예상액 중 일부의 지급을 명하는 것이 일반적이다.

치료종결 후 본안소송 계속 중에 장래의 일실수입과 위자료 중 일부의 지급을 구하는 경우도 있으나, 금전지급을 구하는 가처분으로서 적절하지 않은 것으로 보인다.

다. 주문례

(1) 정액지급형(치료비 등의 경우)

채무자는 채권자에게 ○○원을 임시로 지급하라.

(2) 정기지급형(생계비 등의 경우)

채무자는 채권자에게 20 . . .부터 20 . . .까지 매월 ○일에 ○○원씩을 임시로 지급하라.

(3) 결합형

423

채무자는 채권자에게 ○○원 및 20 . . .부터 20 . . .까지 매월 ○일에 ○○원씩을 임시로 지급하라.

정기지급형에서는 “20 . . .부터 ○○법원 20 가합○○ 사건의 본안판결 선고 시까지”라는 기간표시를 하는 경우도 있다.

라. 집행

(1) 채무자가 가처분결정 정본을 송달받고서도 기간 내에 임의지급을 하지 않으면 가처분결정을 집행권원으로 하여 집행기간(2주일) 내에 금전채권의 강제집행 방법에 의하여 집행할 수 있다. 정기지급형의 경우에 집행기간은 매 지급일부터 2주간이라고 보아야 하고, 집행기간이 경과한 부분은 집행하지 못한다.

(2) 이중집행에 대한 구제책

이 가처분이 집행되어도 본안소송에서는 이를 참작함이 없이 원고승소판결을 하여야 하나, 집행의 대상이 금전인 관계로 이중집행의 위험이 있다(예를 들면 급여 지급을 명하는 가처분의 집행 후에 본안판결의 집행을 다시 하는 경우). 이때에는 본안판결이 선고되면 단행가처분에 의한 집행의 결과를 본안청구의 만족으로 간주하게 되므로 민사집행법 49조에 의한 집행정지를 구할 수 있고, 청구이의의 소도 제기할 수 있다.

7. 보증보험금·신용장대금 지급금지가처분

가. 보증보험금 지급금지가처분

424 (1) 공사도급계약 등의 계약을 근거로 하여 이행보증보험증권이나 하자담보 보증보험증권을 발급받은 피보험자가 보험사고 발생을 원인으로 보증보험회사에 보험금지급을 구하는 경우, 보험계약자가 보험사고가 발생하지 않았다는 이유로 피보험자를 채무자로 하여 보험금의 추심금지를 구하고 보험회사를 제3채무자로 하여 보험금의 지급금지를 구하는 가처분을 신청하거나 보험회사를 채무자로 하여 보험금의 지급금지를 구하는 경우가 있다.

(2) 실무상 위와 같은 보증보험증권은 보험계약자가 피보험자에게 계약이행이나 하자보수이행을 담보하는 금원을 지급하는 것에 갈음하여 발급되는 것이므로 보험금지급이 고도로 보장되어야 하고, 피보험자는 보험금 지급관계에 있어서의 직접 당사자가 아니며, 보험회사 나름대로 스스로 책임하에 보험금을 지급하게 되고, 보험계약자로서는 보험금이 지급되더라도 장차 구상금청구를 받았을 때 대응할 기회를 가진다는 점을 고려하여 보험사고가 발생하지 않았음이 고도로 소명되었을 뿐 아니라, 보험회사가 보험금을 지급할 경우 보험계약자는 보험회사로부터 구상을 당하게 될 것이고 구상을 거절하는 경우에는 각종 금융상의 제재를 받아 막대한 손해를 입을 것임이 충분히 소명된 경우에 한하여 가처분을 인용하고 있다.

(3) 계약 조항이나 보험약관의 해석을 둘러싼 법률관계에 다툼이 있는 경우에는 보험사고발생을 둘러싼 사실관계에 다툼이 있는 것에 불과한 경우보다는 가처분 인용비율이 높은 편이다.

나. 독립적 은행보증금·신용장대금 지급금지가처분

(1) 판례는 보증의뢰인과 수익자 사이의 원인관계와는 독립되어 보증인(은행)은 그 원인관계를 근거로 한 사유로 수익자에게 대항할 수 없고 수익자의 청구가 있기만 하면 보증인(은행)의 조건 없는 지급의무가 발생하게 되는 이른바 독립적 은행보증(first demand bank guarantee)에 있어서, 수익자가 실제로 있어서는 보증의뢰인에게 아무런 권리를 가지고 있지 못함에도 불구하고 은행보증의 추상성 내지 무인성을 악용하여 보증인(은행)에게 청구를 하는 것이 객관적으로 명백할 때에는, 보증의뢰인은 보증인(은행)에 대하여 수익자의 청구가 권리남용임이 명백하다는 것을 증명하여 그 보증금의 지급거절을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 그에 기하여 직접 그 의무자인 보증인(은행)을 상대방으로 하여

425

수익자에 대한 보증금의 지급을 금지시키는 가처분을 신청할 수 있다고 판시하여 보증금의 지급금지를 구하는 가처분이 허용됨을 명백히 밝혔다(대판 1994. 12. 9. 93다43873).

신용장 개설의뢰인과 개설은행과의 관계는 독립적 은행보증의 보증의뢰인, 보증인(은행)과의 관계와 다를 바 없고, 독립·추상성을 가지는 신용장에 있어서도 매입은행과 개설은행이 선적서류의 문면 자체에 하자가 있거나 그 선적서류가 위조된 문서라는 사실을 사전에 알았거나 의심할 만한 충분한 이유가 있는 경우에는 신용장대금을 지급하여서는 아니 되므로(대판 1997. 8. 29. 96다43713 참조), 개설의뢰인은 위와 같은 신용장지급거절 사유가 있음을 증명하여 개설은행을 상대로 신용장대금지급금지가처분을 신청할 수 있다. 한편 신용장의 적법한 매입이 있는 후에 신용장 거래가 사기 거래로 밝혀지더라도, 매입은행이 신용장대금의 지급이나 매입 당시 자신이 사기행위의 당사자로서 관련되어 있거나 사기 사실을 알고 있었거나 또는 의심할 만한 충분한 이유가 있다고 인정되지 않는다면 개설은행에 신용장대금의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 은행에 의한 신용장 매입이 적법하지 않다면 대가를 지급하더라도 이는 신용장통일규칙에서 정한 ‘매입’이 될 수 없고, 이 경우 개설은행으로서는 신용장의 만기에 서류를 제시하는 위 은행에 대하여 수익자에게 대항할 수 있는 모든 사유로 대항할 수 있으며, 따라서 신용장 거래에서 수익자의 사기행위가 밝혀졌다면 이를 이유로 개설은행은 서류제시 은행에 대해 신용장대금의 지급을 거절할 수 있다(대판 2017. 11. 14. 2017다216776 등 참조).

(2) 이처럼 직접 보증은행이나 개설은행을 상대로 독립적 은행보증을 근거로 한 보증금 또는 신용장대금의 지급금지를 구하는 가처분을 신청하는 것 자체는 허용되지만, 이러한 사건은 보증은행이나 개설은행을 채무자로 하는 것이어서 형식적인 답변만이 제출되는 경우가 대부분이므로 충분한 심리가 불가능한 경우가 많고(명목상 가처분신청원인으로 서류의 일치 여부 등 보증금 청구의 권리남용 해당 사유나 신용장대금 지급거절사유를 내세우고 있으나, 사실상 개설의뢰인인 수출업자가 물품의 하자나 시세의 변동 때문에 생긴 손해를 피하기 위한 것이거나 원인관계에 대한 다툼이 있는 경우가 대부분이고, 개설의뢰인이 개설은행에 대하여 신용장대금의 지급거절을 요청하면 개설은행이 법원의 가처분결정을 받아오도록 요구하는 등 개설의뢰인과 개설은행과의 이해관계가 일치하는 경우가 적지 않다), 독립적 은행보증이나 신용장은 국제거래관계에서 독립·추상성에 의하여 그 보증금 또는 대금의 지급이 고도로 보장되어야 한다는 점을 고려하여 가처분 인용 여부를 신중히 결정할 필요가 있다. 실무상 인용되는 예가 많지 않다.

다. 주문례

(1) 보증보험금 지급금지가처분

(가) 보험회사가 채무자인 경우

채무자는 별지 목록 기재 보증보험증권에 따른 보험금을 지급하여서는 아니 된다.

(나) 보험회사가 제3채무자이고 피보험자가 채무자인 경우

1. 채무자는 별지 목록 기재 보증보험증권에 기하여 제3채무자에게 보험금 청구를 하거나 보험금을 수령하여서는 아니 된다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 보증보험증권에 기한 보험금을 지급하여서는 아니 된다.

한편 “채무자 甲은 채무자 乙에게 별지 목록 기재 보증보험증권에 기한 보험금을 지급하여서는 아니 되고, 채무자 乙은 위 보험금을 수령하여서는 아니 된다.”와 같이 보험회사와 피보험자 모두를 채무자로 하여 가처분을 발령하는 실무례도 있다.

(2) 독립적 은행보증금·신용장대금 지급금지가처분

채무자는 별지 목록 기재 지급보증서에 근거한 보증금을 지급하여서는 아니 된다.

427

채무자는 별지 목록 기재 신용장에 대하여 그 대금을 지급하여서는 아니 된다.

채무자는 ○○은행에 별지 목록 기재 각 신용장에 기한 대금을 지급하거나 그 지급채무를 승인하여서는 아니 된다.

제5절 유가증권에 대한 가처분

1. 개요

어음·수표·화물상환증·선하증권 등의 유가증권의 인도청구권을 보전하기 위해서는 그 증권에 대한 채무자의 점유를 박탈하거나 그 처분을 금지하는 가처분을 할 필요가 있다. 유가증권은 그 증권 자체의 사용은 의미 없으므로 그 증권의 점유이전을 막으려면 집행관

이 직접 그 증권을 보관하도록 하면 된다. 또 유가증권상의 권리가 행사되어 버리면 피보전권리의 보전이 불가능하게 되므로 그 권리의 행사를 금지해 둘 필요가 있다. 그러나 어음·수표 등은 일정한 권리행사기간이 있고 그 기간이 경과하면 본래의 효력을 잃게 되므로 그 권리의 보전을 위한 행위(지급거절증서의 작성을 위한 제시 등)는 할 수 있도록 배려하여야 한다.

2. 신청

유가증권에 대한 가처분을 신청함에는 그 유가증권을 특정할 수 있도록 표시하여야 하며 현재의 소재지를 밝혀야 한다.

3. 주문례

428

가. 유가증권 점유이전금지가처분

1. 채무자는 별지 목록 기재 약속어음에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
2. 집행관은 위 어음의 권리보전을 위한 행위를 할 수 있다.

나. 유가증권 처분금지가처분

1. 채무자는 별지 목록 기재 약속어음에 대하여 지급을 위한 제시를 하거나 권리를 행사하거나 또는 배서양도 그 밖에 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다. 다만 소구권의 보전을 위한 행위는 할 수 있다.
2. 제3채무자는 위 약속어음에 대한 지급을 하여서는 아니 된다.

약속어음상 지급장소로 기재되어 있는 은행을 제3채무자로 하여 은행에 대하여 채무자 아닌 어음소지인에 대한 지급금지를 명하는 가처분이 허용될 것인가의 문제가 있다. 어음의 유통증권성과 인적 항변의 단절이라는 어음법상의 원리에 비추어 제3자가 어음을 취득하여 이를 제시하는 경우까지 그 지급을 금지하는 것은 어음소지인의 권리를 부당하게 제한하는 것이므로 소극적으로 해석할 것이다. 판례도 “가처분결정에서 ‘제3채무자는 이 사건 수표에 대한 지급을 하여서는 아니된다’고 표시하여 지급금지의 상대방을 가처분채무자에 한정하지 아니하고 있다 하더라도 그 결정의 효력이 제3취득자에게 미치지 않는

하고, 또한 수표에 대한 지급금지가처분결정이 있더라도 이는 제3채무자가 가처분채무자에게 현실로 수표금을 지급하는 것만을 금지하는 것이므로 가처분채무자나 그로부터 수표를 양수한 제3취득자가 수표발행인인 제3채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있으며, 법원은 가처분이 되어 있음을 이유로 이를 배척할 수 없다.”고 하였다(대판 2008. 5. 15. 2006다8481).

429 4. 집행

유가증권 점유이전금지가처분은 집행관에게 집행을 위임하여야 하고, 유가증권 처분금지가처분은 제3채무자에게 송달하여야 한다.

집행관이 보관 중인 약속어음의 지급을 위한 제시를 하여 어음과 교환으로 지급을 받았을 때에는 그 금전이 가처분목적물을 대신하는 것으로 볼 것이다.

제6절 그 밖의 재산권에 대한 가처분

1. 지식재산권에 대한 가처분

가. 처분금지가처분

(1) 개요

이 가처분은 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권 또는 상표권) 그 밖에 이에 준하는 권리(저작권, 출판권 등)에 대한 이전등록청구권 또는 말소등록청구권을 피보전권리로 한다. 특허권·실용신안권·디자인권은 그 양도가 자유롭고 상표권도 지정상품마다 분할하여 자유롭게 양도할 수 있으며 이러한 권리들은 질권의 설정이나 각종 이용권 부여를 통한 처분이 가능하므로 이전등록청구권 또는 말소등록청구권의 보전을 위해서는 이러한 처분행위를 금지할 필요가 있다.

(2) 관할

권리이전에 등록이 필요한 지식재산권에 대한 가처분은 등록을 하는 곳을 관할하는 지방법원이나 본안의 관할법원이 관할한다(민집규 216조, 213조 1항).

등록을 하는 곳에 관하여 보면, 특허권 등 산업재산권의 등록을 하는 곳은 특허청이므로 430 (특허 85조 1항, 실용신안법 20조, 디자인보호법 88조 1항, 상표법 80조 1항) 그 관할법원은 대전지방법원이다. 저작권의 등록을 하는 곳은 문화체육관광부이므로(저작권법 55조 1항) 그 관할법원도 대전지방법원(각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 4조)이 되나, 권한의 위탁(저작권법 시행령 68조 1항)에 따라 실제 등록 업무를 처리하는 기관이 한국저작권위원회인 경우에는 한국저작권위원회의 사무소가 등록을 하는 곳이 된다.

본안의 관할법원에 관한 특칙인 민사소송법 24조는 특허권 등(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권)에 관한 소를 제기하는 경우에는 2조부터 23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할(서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원)로 하면서 서울중앙지방법원에도 그 중복관할을 인정하고, 특허권 등을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에도 2조 내지 23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있도록 규정하였다.

(3) 지식재산권의 일부에 대한 처분금지가처분

특허권 등 산업재산권의 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 자기 지분의 양도, 질권의 설정, 전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락이 금지되는 등 제약을 받게 된다(특허 99조 2항, 4항, 실용신안법 28조, 디자인보호법 96조 2항, 4항, 상표법 93조 2항, 3항). 공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 저작재산권자의 동의가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다(저작권법 48조 1항 전문). 저작권법은 상속이나 지분양도 등에 의하여 후발적으로 수인이 저작재산권을 공동으로 보유하게 되는 경우에 관하여는 명시적 규정을 두지 않고 있으나, 위 조항이 유추적용되는 것으로 해석하는 견해가 있다.

그러나 이러한 제약은 지식재산권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 지식재산권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 431 지식재산권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 지식재산권에 관한 개별법에 지식재산권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없으므로, 지식재산권의 공유에도 지식재산권에 관한 개별법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법의 공유 규정이 적용될 수 있다(대판 2004. 12. 9. 2002후567 참조).

지식재산권에 관한 공유지분의 처분에 다른 공유자의 동의를 필요로 하더라도 이는 처분의 유효요건일 뿐 처분을 공동으로 하여야 하는 것은 아니어서 공유지분의 처분에 관한

소송이 필수적 공동소송이 되어야 할 이유가 없고, 그에 관한 가처분사건도 필수적 공동소송이 아니다.

판례는 특허권의 일부 공유지분에 대한 처분금지가처분이 등록된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 경우 가처분에 위반되는 것은 특허권 전부가 아니라 처분이 금지된 일부 지분뿐이라고 하고, 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 특별한 사정이 없는 한 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분에 대한 처분금지가처분을 구할 수 없다고 한다(대판 1999. 3. 26. 97다41295). 특허권이 아닌 그 밖의 지식재산권에도 이 판례가 그대로 적용될 수 있을 것이다.

다만 특허권의 전용실시권자는 실시권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없고, 따라서 특허권의 일부 지분에 대한 처분금지가처분등록이 마쳐진 후 제3자 앞으로 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다(위 97다41295). 이 판례는 전용실시권제도가 없는 저작권을 제외한 실용신안권, 디자인권, 상표권에 대하여도 그대로 적용될 수 있을 것이다.

(4) 주문례

채무자는 별지 목록 기재 특허권에 관하여 양도, 질권 또는 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 그 밖에 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.

432 (5) 집행

부동산처분금지가처분의 경우와 같이 발령법원이 집행법원이 되어 법원사무관등의 명의로 지체 없이 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)의 경우에는 특허청장에게, 저작권 등의 경우에는 문화체육관광부 장관에게 가처분기입등록의 촉탁을 한다.

가처분의 효력이 채무자에 대한 관계에서 발생하는 시기와 제3자에 대한 관계에서 발생하는 시기를 가급적 일치시킴으로써 법률관계가 간명하게 되도록 할 필요가 있다.

각 개별법상의 등록 기한에 관계없이 채권자에게 가처분이 고지된 날로부터 2주 안에 촉탁절차를 밟아야 하고, 별다른 사정이 없는 한 가처분결정의 송달과 동시에 촉탁절차를 밟는 것이 타당하다.

다만 담보제공을 조건으로 가처분결정을 발령한 경우에는 담보제공증명서(공탁증명서)가 집행법원(즉 담보제공명령법원인 보전처분발령법원)에 제출된 후에 촉탁하여야 한다. 채권자가 가처분결정서에 담보를 제공한 증명서(공탁증명서 그 밖의 법원의 담보제공증명서, 민집 19조)를 첨부하여 법원에 제출하면 법원사무관등은 그 담보제공증명서의 등본을 채무자에게 송달하여야 한다(민집 40조 2항). 이때 가처분기입등록촉탁절차를 밟는 것이 타당하다.

등록면허세는 산업재산권의 경우는 없고(지방세 28조 1항 11, 12호), 저작권, 배타적 발행권(저작권법 88조 및 96조에 따라 준용되는 경우를 포함), 출판권, 저작인접권, 컴퓨터 프로그램 저작권 또는 데이터베이스 제작자의 권리는 건당 3,000원씩이며(지방세 28조 1항 10호 라목), 지방교육세는 그 등록면허세액의 100분의 20이다(지방세 151조 1항 2호).

집행의 효력은 부동산처분금지가처분에 준한다.

등록촉탁서의 양식은 다음과 같다.

[전산양식 A4783] 특허권가처분 등록촉탁서

433

○ ○ 법 원			
등록촉탁서			
			특허청장 귀하
사 건	20 카 .	특허권 가처분	
특허권의 표시	별지 목록 기재와 같음		
등록권리자	(채권자 이름과 주소)		
등록의무자	(채무자 이름과 주소)		
등록원인과 그 연월일	20 . . . 가처분결정		
등록목적	양도, 질권, 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락, 그 밖에 일체의 처분행위금지가처분의 기입		
과세표준	1건		
등록면허세	해당 없음		
지방교육세	원		
첨 부	결정 정본	1통	
위 등록을 촉탁합니다.			
2000. 0. 0.			
법원사무관			㉠

나. 지식재산권의 침해금지가처분

(1) 의의

지식재산권침해금지가처분은 특허권 등 지식재산권에 기한 금지청구권을 피보전권리로 하여 채무자의 침해행위의 금지를 구하는 가처분이다.

이 가처분은 특허권 등을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에게 본안판결에서 명하게 될 침해금지의 부작위의무를 미리 부과하는 점에서 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에 속하며, 가처분에서 명하는 부작위의무가 본안소송에서 명할 부작위의무와 내용상 일치하는 이른바 만족적 가처분에 속한다.

434 (2) 관할

지식재산권침해금지가처분의 본안소송인 특허권 등의 침해금지청구소송은 소송목적의 값을 산정할 수 없는 재산권상의 소에 해당하므로, 사물관할은 합의부 관할이다.

토지관할은 본안의 관할법원 또는 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원이다. 민사소송법 24조는 특허권 등(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권)에 관한 소를 제기하는 경우에는 2조부터 23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할(서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원)로 하면서(2항) 서울중앙지방법원에도 그 중복 관할을 인정하고(3항), 특허권 등을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에도 2조 내지 23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있도록 규정하였다(1항). 이는 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시키기 위한 것으로(대결 2019. 4. 10. 2017마6337), 본안의 관할이 인정되는 이상 침해금지가처분 역시 해당 법원에 제기할 수 있다. 다만 본안이 전속관할 사건에 해당하더라도 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원이 별도로 있다면 후자에도 가처분신청을 할 수 있을 것이다.

2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 28조의4 2호에 따라 특허법원이 특허권 등 침해사건의 항소사건을 심판하게 되었으나, 가처분결정에 대한 항고를 본안소송에 대한 항소와 동일하게 보기는 어려우므로 가처분사건의 항고심 관할은 일반 사건과 차이가 없다. 물론 특허법원에 본안소송이 계속 중인 상황에서 가처분신청을 하는 경우에는 특허법원에도 관할이 인정될 수 있다.

본안의 관할법원과 관련하여, 침해행위가 실제로 행하여지는 공장 등의 소재지, 침해

물건의 판매지 등에 불법행위지의 특별재판적을 인정할 수 있는지가 다투어지는데, 불법 행위지의 특별재판적 규정상 ‘불법행위에 관한 소’의 의미를 넓게 해석하여 토지관할을 인정할 수 있다는 견해도 있으나, 특허권 등 침해금지청구권은 침해자의 고의·과실을 요하지 않는 등 불법행위와 그 성질을 달리하는 점, 전국적으로 침해물품이 판매, 홍보되는 경우에는 채권자로 하여금 관할법원을 선택할 수 있게 하여 민사집행법상의 전속관할 규정을 잠탈하는 결과를 초래할 수 있는 점 등을 이유로 불법행위지의 특별재판적 규정을 적용할 수 없다는 견해가 실무상 유력하다. 또한 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구의 소는 지식재산권침해금지가처분의 본안소송에 해당하지 않는다고 보는 것이 일반적이다. 435

특허권침해금지청구권에 따른 부작위의무는 의무의 이행이 특정 장소와 결부될 성질이 아닌 일반적인 부작위의무이므로, 가령 침해품의 판매 금지를 청구하는 경우에 판매가 이루어지는 모든 장소의 법원에 의무이행지의 관할권을 인정할 수는 없고, 채무자의 주소나 거소 등 보통재판적을 의무이행지로 보아야 한다는 견해가 유력하다. 이에 대하여 일반적인 부작위의무가 아니라 특정한 장소에서의 부작위의무를 소송물로 삼는 경우라면 그 장소에 의무이행지의 특별재판적 규정이 적용될 수 있다는 견해도 있다.

다만 실무상으로는 채무자의 보통재판적이 아니더라도 침해행위가 발생하는 공장, 공사현장 등이 특정되어 있다면 이를 다툼의 대상이 있는 곳으로 보아 관할을 인정하고 있다.

(3) 당사자

지식재산권침해금지가처분사건에서는 지식재산권에 기한 금지청구권을 가진다고 주장하는 사람에게 채권자적격이 있고, 지식재산권을 침해하거나 침해할 우려가 있다고 주장되는 사람에게 채무자적격이 있다. 특허권침해금지가처분사건의 당사자적격 문제는 다른 지식재산권침해금지가처분에도 원용될 수 있으므로 이곳에서는 특허권침해금지가처분사건을 중심으로 보기로 한다.

(가) 가처분채권자

특허법 126조 1항은 특허권자 및 전용실시권자에 대하여 침해금지 및 예방청구권을 인정하고 있다.

① 특허권자

특허권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로 실질적인 특허권자

라 하더라도 등록명의인이 아닌 이상 침해금지가처분신청을 제기할 수 없다. 특허출원인은 출원공고를 하였다 하더라도 침해금지청구권을 갖지 못한다.

특허권이 공유인 경우 본안이 항상 필수적 공동소송인 것은 아닐 뿐 아니라(대판 2004. 12. 9. 2002후567), 본안이 필수적 공동소송인 경우에도 침해금지가처분은 특허권의 현상을 유지하고 그 훼손을 방지하는 보존행위에 해당하므로 공유자 중 1인이 이를 단독으로 신청할 수 있다.

특허권의 양수인, 전용실시권자, 통상실시권자 등은 침해금지가처분사건에 보조참가할 수 있다.

특허권자가 특허발명의 전부에 관한 전용실시권을 설정한 경우에도 침해금지청구권을 그대로 보유하는지 여부에 대하여는 견해가 대립하나, 특허권자가 전용실시권을 설정한 결과 현재 발명을 실시할 수 없다 하더라도 특허권에는 절대성·탄력성이 있어 일정한 기간이 경과하면 그 본연의 독점적 실시권을 회복한다는 점을 고려하여 이를 긍정하는 것이 통설이다.

② 전용실시권자

전용실시권은 특허발명을 독점적·배타적으로 실시하는 물권 유사 권리이므로 그 보유자는 침해금지청구권을 가진다(특허 126조 1항). 전용실시권은 특허등록원부상의 설정 등록에 의하여 비로소 발생하므로 등록명의인이 아닌 자는 침해금지청구권을 행사할 수 없다.

③ 통상실시권자

통상실시권자에 대하여 침해금지청구권을 인정할 수 있는지 여부가 문제된다. 특허법 126조는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자로 특허권자 또는 전용실시권자만을 규정하고 있는데, 통설은 통상실시권의 성질을 채권적인 것으로 보아 독점적 통상실시권자이든 아니든 통상실시권자는 직접 침해금지청구를 할 수 없다고 보면서 위 규정의 특허권자 또는 전용실시권자를 한정적 열거로 보고 있다.

한편 통상실시권자가 채권자대위권을 행사하여 침해금지청구를 할 수 있는가에 관하여는, 독점적 통상실시권자인 경우에도 독점의 특약이 부가되었다 하여 통상실시권 본래의 성질이 변하는 것은 아니라는 이유로 이를 부정하는 견해도 있으나, 독점적 통상실시권자는 특허권자에게 특허발명의 독점적인 실시를 보장하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리가 있는데 특허권자가 무단 실시자에 대하여 아무런 조치를 취하지 아니할 경우 특허발명의

독점적인 실시권 자체를 보호할 수단이 없고, 손해배상청구권의 행사만으로는 독점적 통상실시권자의 보호에 불충분하거나 그 집행이 용이하지 아니한 경우도 많으므로 독점적 통상실시권자의 대위권은 인정되어야 한다는 견해가 다수이다.

그런데 저작권의 경우, 판례는 저작권법은 특허법이 전용실시권제도를 둔 것과는 달리 침해정지청구권을 행사할 수 있는 이용권을 부여하는 제도를 마련하고 있지 아니하여 독점적 이용권자가 독자적으로 저작권법상의 침해정지청구권을 행사할 수는 없지만, 저작권자가 스스로 침해정지청구권을 행사하지 아니하는 때에는 자신의 권리를 보전하기 위하여 필요한 범위 내에서 권리자를 대위하여 저작권법 123조에 기한 침해정지청구권을 행사할 수 있다고 한다(대판 2007. 1. 25. 2005다11626).

한편 물건을 사용수익하는 경우와는 달리 특허발명은 수인이 각기 별개로 실시할 수 있으므로, 독점적 통상실시권자가 아닌 일반 통상실시권자의 경우에는 특정채권의 보전을 위한 채권자대위권의 요건을 충족시키지 못하여 허용되지 않는다는 것이 통설이다. 독점적 통상실시권자라면 독점권을 보장해 줄 것을 구할 수 있겠지만, 이와 달리 일반 통상실시권자는 특허권자에게 다른 사람의 사용까지 금해줄 것을 청구할 피보전권리가 없다는 점, 즉 특허권자가 다른 사람의 사용을 허락하거나 혹은 묵인한다면 어쩔 수 없다는 점에서 대위권 행사의 요건을 갖추었다고 보기 어렵다.

(나) 가처분채무자

침해금지가처분의 상대방은 특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자이다(특허 438 126조 1항). 따라서 정당한 권원 없이 업으로서 타인의 특허권에 속하는 물건 또는 방법의 발명을 실시하거나 실시할 염려가 있는 사람이 채무자로 될 것이다.

특허발명 실시제품의 생산자, 판매자 및 사용자가 서로 다른 경우에는 각기 별개의 특허권 침해를 구성한다.

침해금지의 대상에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위도 포함되나(특허 126조 2항), 채무자의 권한 범위에 속하는 행위에 해당하여야 한다. 예를 들어 소유권 없이 단순히 침해설비를 점유하고 있는 자는 처분권한이 없으므로 그를 상대로 설비의 폐기를 구하는 것은 허용되기 어렵다(대판 1996. 12. 23. 96다16605 참조). 다만 동산을 목적으로 하는 강제집행은 점유를 기초로 개시하게 되므로, 채무자가 점유하고 있고 채무자 아닌 제3자의 소유임이 소명되지 아니한 이상 가처분을 발령할 수 있으며, 다만 제3자는 경우에 따라 제3자이의의 소로 다룰 수 있을 뿐이다. 또한 현상을 변경하지 아니할 것을 조건으로 하여 채무자에게 그 사용을

허가하도록 하는 내용의 점유이전금지가처분은 그 목적물이 제3자의 소유임이 소명되더라도 발령할 수 있다(대판 2002. 3. 29. 2000다33010 참조).

(다) 소송대리인

특허권침해금지가처분에 관하여 변리사에게도 소송대리권이 인정되는지에 관하여는 논란이 있었으나, 판례는 “변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 소송대리인이 될 수 있다.”고 정하는 변리사법 8조에 의하여 변리사에게 허용되는 소송대리의 범위 역시 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송으로 한정되고, 현행법상 특허 등의 침해를 청구원인으로 하는 침해금지청구 또는 손해배상청구 등과 같은 민사사건에서 변리사의 소송대리는 허용되지 않는다고 하였으므로(대판 2012. 10. 25. 2010다108104), 특허권침해금지가처분에서도 변리사의 소송대리권은 인정될 수 없다.

국내에 주소 또는 영업소를 갖지 아니한 재외자의 특허관리인도 침해금지가처분의 소송대리인이 될 수 없다(특허 5조 1항).

439 (4) 피보전권리와 보전의 필요성

만족적 가처분의 특성과 제한적 심리로 인해 본안소송에서 충분한 증거조사를 거쳤다면 금지청구나 손해배상청구가 인용될 수 있는 사안임에도 피보전권리나 보전의 필요성에 관한 소명이 부족하다는 이유로 가처분신청이 기각되는 경우가 있다.

가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분에서 보전의 필요성을 인정하는 데에는 신중한 필요가 있고(대판 2006. 11. 23. 2006다29983 참조), 실무상 피보전권리에 관하여도 고도의 소명을 요구하고 있다. 다만 지식재산권의 침해로 인해 채권자가 입게 되는 손해에는 단순한 영업이익의 감소뿐만 아니라 시장점유율의 감소, 실시품 매출의 감소, 판매가격의 저하, 판매경비의 증가에 따른 재산적 손해와 침해행위로 인한 명예, 신용의 훼손 등 정신적 손해가 모두 포함되므로, 지식재산권의 침해로 인한 손해는 금전적인 전보가 가능하다는 단순한 전제에 서서 피보전권리와 보전의 필요성 유무를 다뤄서는 안 된다. 또한 동일한 만족적 가처분이더라도, 예를 들어 아직 시판되지 않은 제품의 생산, 판매 등의 금지를 구하는 신청보다는 이미 시장에 판매 중인 제품의 생산, 판매 등의 금지를 구하는 신청의 경우 상대적으로 인용 여부를 더욱 신중하게 결정할 필요가 있을 것이다.

특허권침해금지가처분의 피보전권리와 보전의 필요성은 다른 지식재산권침해금지가처분에도 그대로 원용될 수 있으므로 이하에서는 특허권을 중심으로 살펴본다.

(가) 피보전권리

특허권침해금지가처분의 피보전권리는 채권자의 특허권에 기한 금지청구권 및 채무자의 침해금지 부작위의무라는 권리의무 관계의 존재이고, 이와 같은 피보전권리의 존부는 결국 채무자의 행위가 특허권 침해행위를 구성하느냐에 달려 있다.

① 특허권 침해라 함은 제3자가 정당한 권원 없이 업으로서 타인의 특허권에 속하는 물건 또는 방법의 발명을 실시하는 것을 말한다.

“업으로서”란 사업으로 실시하는 것을 의미하므로 단순히 개인적·가정적 범주에서 실시하는 것은 포함되지 않는다. 사업에는 영리사업뿐만 아니라 공공사업과 같은 비영리사업도 포함된다. 440

“물건의 발명 실시”란 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 말한다(특허 2조 3호 가목). 채무자가 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 경우에는 특허권 침해로 간주한다(특허 127조 1호: 간접침해). 물건의 수출·소지 등은 발명의 실시해당되지 않는다.

“방법의 발명 실시”란 그 방법을 사용하는 행위를 의미한다(특허 2조 3호 나목). 채무자가 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 경우에는 특허권 침해로 간주한다(특허 127조 2호: 간접침해).

“물건을 생산하는 방법의 발명 실시”란 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 의미한다(특허 2조 3호 다목). 물건을 생산하는 방법의 발명에 의한 물건과 동일한 물건을 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하나(특허 129조: 생산방법의 추정), 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건이거나, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건인 경우에는 그 추정이 번복된다.

② 채무자가 실시하는 물건 또는 방법(이하 ‘채무자 물건 또는 방법’)이 특허권 침해를 구성하는지 여부는, i) 특허발명의 보호범위의 확정, ii) 채무자 물건 또는 방법의 특정, iii) 채무자 물건 또는 방법과 특허발명의 대비의 심리과정에 의하여 판단하고, 나아가 iv) 채무자에게 항변사유가 있는지 여부를 심리, 판단한다.

441 ㉔ 특허발명의 보호범위의 확정

특허발명의 보호범위라 함은 특허권자의 측면에서는 특허절차에 의하여 독점적 실시권이 부여된 기술사상의 범위를 의미하고, 제3자의 측면에서는 특허발명이 등록된 결과 제3자가 정당한 권원 없이 실시할 수 없는 기술사상의 범위를 의미한다. 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고(특허 97조), 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대판 2007. 11. 29. 2006후1902).

특허발명의 보호범위를 확정하기 위해서는 특허출원, 출원공개 및 설정등록 등의 제반 절차가 진행되는 과정에서 출원인에 의하여 공개된 기술사상의 내용 및 독점권 부여의 대상을 신중하게 검토할 필요가 있다.

㉕ 채무자 물건 또는 방법의 특정

특허권침해금지가처분신청에 있어서 금지대상은 채무자가 실제로 생산·판매하는 제품 또는 실시하는 방법이지, 채권자의 제품이나 실시 방법이 아니다. 이러한 가처분은 상대방으로 하여금 특정한 물건의 생산·판매 또는 방법의 사용 등을 금지하도록 하기 위한 것이고, 가처분결정 이후에도 위반행위가 계속되는 경우 가처분집행으로 목적을 달성할 수밖에 없으므로, 채권자는 금지청구의 대상인 채무자 물건 또는 방법을 집행이 가능할 정도로 구체적으로 특정하여야 한다.

채권자가 금지대상을 채무자의 실제 제품이나 방법 등과 다르게 특정하여 오는 경우 일단 채권자에게 금지대상을 채무자의 실제 제품이나 방법 등으로 보정하도록 해야 한다. 다만 신청취지의 특정을 지나치게 강조하면 적기에 권리구제를 받을 수 없게 되는 측면이 있고, 신청취지가 구체화될수록 채무자가 가처분결정의 취지를 용이하게 잠탈할 수 있는 부작용도 있으므로, 신청취지의 특정이 채권자에게 과도한 부담이 되지 않도록 할 필요가 있다.

물건의 발명의 경우 입체적인 물건을 문서에 표현하는 어려움을 고려할 때, 실무상 채무자가 생산, 판매하고 있는 상품명, 제품형식번호 등을 기재하고 간결한 설명을 첨가하거나 도면이나 사진을 첨부하면 특정이 되었다고 볼 수 있다. 방법의 발명의 경우에도 채무자가

당해 방법에 붙인 특정한 명칭이 있다면 이를 기재하고 간결한 설명을 첨부할 수 있겠으나, 집행의 용이성 측면에서는 사용행위 자체보다 침해행위에 제공된 설비나 침해행위로 생긴 물건을 신청대상으로 삼는 것이 적절한 경우도 있다.

반면 침해 물건의 사진만을 첨부한다거나 자신의 특허발명과 동일·유사한 실시행위의 금지를 구하는 것만으로는 채무자 물건 또는 방법이 특정되었다고 볼 수 없다. 예를 들어 주문에서 채무자의 제품이나 생산방법을 채권자의 특허발명과 대비될 수 있는 정도의 기술적 특징만을 가지고 특정한다면, 집행기관이 판결을 집행함에 있어 채무자의 구체적 제품이나 생산방법이 그러한 기술적 특징을 포함하고 있는지를 판단하여야 하는데, 당사자 사이에 그러한 기술적 특징의 포함 여부에 대하여 다툼이 있는 경우에는 결국 가처분의 집행이 곤란해지게 된다. 따라서 채권자 권리를 중심으로 채무자 실시 제품이나 방법을 포괄하여 또는 일정한 범위의 물건이나 방법으로 특정하는 주문, 예를 들어 ‘채무자는 채권자의 제00호 특허와 동일 또는 유사한 제품을 생산, 판매하여서는 아니 된다’라고 하는 것은 피해야 하고, 장래의 침해 가능성을 포괄적으로 배제하기 위하여 주문에 ‘2차적저작물’, ‘계약에 기한’, ‘권리범위에 속하는’ 등의 법률용어 또는 ‘동일’, ‘유사’, ‘기타’, ‘등’, ‘일체’ 등의 추상적 용어를 사용하는 것 역시 적절하지 않다.

㊤ 채무자 물건 또는 방법과 특허발명의 대비

채무자 물건 또는 방법의 구성요소와 특허청구범위에 기재된 구성요소를 일대일로 대비하여 본 결과 동일성이 인정되는 경우에는 특허권 침해를 구성한다. 즉 침해 여부를 판단하기 위해서는 침해 물건 또는 방법과 특허발명의 대비가 필요하므로, 채권자는 구성요소의 측면에서 금지청구의 대상인 채무자 물건 또는 방법을 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 분석하여 설명하여야 한다.

443

특허청구범위는 기술적 사상의 창작을 문자로 표현한 것이어서 현실적인 침해 물건이나 침해 방법을 그 자체로서 대비하는 것은 불가능하므로, 침해 물건이나 침해 방법에 존재하는 기술적 사상을 정확히 파악하여 이를 문장화하고 도면으로 묘사할 필요가 있다.

채무자 물건 또는 방법이 특허발명의 구성요소를 모두 그대로 포함하는 경우에는 특허권 침해를 구성한다(문언침해). 반면 채무자 물건 또는 방법이 특허발명의 구성요소 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 않은 경우에는 원칙적으로 특허침해를 구성하지 않는다(구성요건 완비의 원칙, 대판 2001. 12. 24. 99다31513 참조).

채무자 물건 또는 방법의 구성요소 중에 특허발명의 구성요소와 문언상으로는 동일하지 않은 부분이 있다 하더라도 그 부분이 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 기능 및

작용효과를 발휘하는 것으로서 실질상 동일한 가치로 평가되는 경우, 즉 $a+b+c \rightarrow y$ 인 특허발명과 $a+b+c' \rightarrow y'$ 인 채무자 물건 또는 방법을 대비하여 본 결과 c 와 c' , 그리고 y 와 y' 가 각기 실질상 동일한 가치로 평가되는 경우에는 특허권 침해를 구성한다(균등침해, 대판 2000. 7. 28. 97후2200 참조).

특허발명의 구성요건 중 출발요소와 최종요소는 동일하게 하면서도 특허에 저촉하는 것을 피하기 위하여 불필요한 공정을 부가한 형태의 실시태양, 예컨대 $a+b+c \rightarrow y$ 의 특허발명에 대하여 $a+b+c+c' \rightarrow y'$ 의 채무자 물건 또는 방법을 실시하는 이른바 우회발명도 특허권 침해가 된다는 것이 통설, 판례이다(대판 1997. 11. 14. 96후2135, 대판 2000. 7. 4. 97후2194 등).

444 기존 선행 발명의 구성요소를 모두 그대로 가지고 있으면서 새로운 기술요소를 부가하여 작용효과의 상승을 달성해 낸 후행 발명을 이용발명이라고 하는데, 선행 발명 특허권자의 동의 또는 특허청의 통상실시권 허락의 심판 없이 실시한 이용발명은 선행 발명에 대한 특허권 침해를 구성한다(특허 98조, 138조). 이용관계에 의한 침해가 성립하는 요건으로서 선행 발명을 '그대로' 이용하는 것은 문언 기재 그대로 이용하는 것뿐만 아니라 균등물을 이용하는 경우도 포함한다(대판 2001. 8. 21. 98후522).

㉔ 채무자의 항변

채무자 물건 또는 방법이 특허권에 저촉되는 경우라도 특허권의 행사를 제한하는 사유나 채무자의 실시행위를 적법하게 하는 사유가 있으면 특허권 침해가 성립하지 않는다.

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지가처분신청은 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다[권리남용 항변, 대판(전) 2012. 1. 19. 2010다95390]. 그러나 침해 여부를 심리하는 법원이 특허 무효의 명백성을 심리할 때에는 신중을 기하여야 한다.

채무자 물건 또는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 이를 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다(자유실시기술 항변, 대판 2004. 9. 23. 2002다60610).

특허발명의 전부가 출원 당시 공지되거나 공연히 실시된 기술이었던 경우(예컨대 $A+B+C$ 로 된 발명에 있어서 위와 동일한 구성 전체가 공지, 공연 실시된 것을 의미하고, A , B , C 의 개별 구성요소들이 나뉘어 각각 공지, 공연 실시된 경우를 뜻하는 것이 아니다)에는 특허 무효심결 유무와 관계없이 그 권리범위가 부정된다[공지기술 항변 내지 신규성

결여 항변, 특허 29조 1항 1, 2호, 대판(전) 1983. 7. 26. 81후56].

명문의 규정은 없으나, 특허권자로부터 일단 적법하게 당해 특허권에 관한 제품을 양도 받은 후에 이를 다시 양도하거나 사용하는 행위는 특허권 침해를 구성하지 않는다(권리소진 항변, 상표권 소진에 관하여는 대판 2003. 4. 11. 2002도3445 참조).

445

특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없고, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 살펴 판단하여야 한다(기재불비 항변, 대판 2002. 6. 14. 2000후235).

그 밖에 특허권의 효력이 제한된다거나(특허 96조, 181조), 채무자가 특허권자의 허락에 의한 전용실시권 또는 통상실시권을 가진다거나, 특허법이 정한 법정실시권(특허 103조 ~ 105조, 122조, 182조, 183조)을 가진다거나, 강제실시권 등(특허 98조, 106조, 107조, 138조)을 가진다는 항변이 가능하다.

③ 특허권 침해의 우려

채권자가 침해예방청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분을 신청한 경우 채무자에게 특허권 침해의 우려가 있다는 점이 소명되어야 한다. 즉 현재 제조 준비 중에 있거나 계절상품이기 때문에 현재는 생산하지 않지만 계절이 되면 생산을 재개할 것이 확실한 경우, 침해 물건을 판매하기 위하여 소지하고 있다가나 판매 준비를 위하여 카탈로그를 반포한 경우, 과거에 특허권 침해의 경력이 있는 자로서 현재 침해를 위한 준비행위를 하는 경우 등에 특허권 침해의 우려가 있다고 봄이 상당하다.

(나) 보전의 필요성

특허권침해금지가처분은 임시의 지위를 정하기 위한 가처분 일반과 마찬가지로 계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 허용되나(민집 300조 2항), 그중에서도 특히 만족적 가처분에 속하기 때문에 보전의 필요성에 관하여 고도의 소명이 필요하다는 것이 일반적인 견해이다.

특허권침해금지가처분사건에서의 보전의 필요성은 가처분의 인용 여부에 따른 당사자들의 이해득실관계, 본안소송에서의 승패의 예상, 공공복리에 미칠 영향 등을 고려하여 결정하라는 것이 판례(대판 1993. 2. 12. 92다40563)이다.

446

① 당사자의 이해득실관계

㉞ 채권자 측의 사정

가처분신청이 받아들여지지 않을 경우 본안판결의 확정 시까지 채권자가 입게 될 손해를 고려하여야 한다. 여기서의 손해에는 시장점유율의 감소, 실상품 매상고의 감소, 판매가격의 저하, 판매경비의 증가에 따른 재산적 손해와 침해행위로 인한 명예, 신용의 훼손 등 정신적 손해가 모두 포함된다.

채무자가 금전적인 손해배상을 할 자력이 없다는 사정은 채권자가 특허권 침해로 입게 될 현저한 손해를 인정할 주요 근거가 될 수 있으나, 장차 금전적인 손해배상이 가능하다는 이유만으로 침해금지가처분신청을 배척하는 것은 독점적 실시권을 보장하고 타인의 침해행위를 배제하고자 하는 특허권 제도의 본질에 반하여 타당하지 않다. 다만 채권자와 채무자 사이에 종전부터 거래관계가 있었고, 채권자의 주된 목적이 지식재산권의 침해금지보다는 거래대금을 받는 데 있다는 사정은 보전의 필요성 인정에 부정적 요소가 될 수 있다.

채권자가 특허발명을 위하여 투여한 연구개발비의 규모가 크고, 당해 특허분야에서 경쟁이 치열하며, 기술변화의 속도가 빠를수록 보전의 필요성이 인정될 가능성이 클 것이다. 그리고 채권자가 입게 될 손해가 시장점유율의 감소, 신용 저하 등과 같이 금전적 배상만으로는 충분하지 못하거나 단시간 내에 회복하기 어려운 손해일 경우에도 보전의 필요성이 더 커진다고 보아야 한다.

한편 채권자가 침해사실을 알고도 상당한 기간이 경과하도록 권리구제를 위한 조치를 게을리하였다는 사정은 보전의 필요성을 인정함에 있어 소극적 요소로 작용할 수 있다(대결 2005. 8. 19. 2003마482). 그리고 채권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우에는 일반적으로 보전의 필요성을 인정하기 어려우나, 미실시를 정당화할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 보전의 필요성을 인정할 수 있다(상표권 사안에서 대판 1980. 12. 9. 80다829 참조).

여기서 채권자가 특허발명을 실시하였는지 여부는 오로지 특허권자 본인이 직접 실시한 것만을 의미하는 것은 아니므로 타인에게 실시권을 설정하여 주고 그 비용을 받는 등의 경우도 실시라고 할 수 있을 것이나, 다만 타인에게 실시권을 설정해주는 하였으나 별도로 비용을 받지 않고 있고 특허권자 본인이나 실시권자 모두 특허권을 실시하지 않고 있는 경우는 실시라고 할 수 없으며, 별도로 비용을 받더라도 그것이 실질적인 특허실시의 대가라고 볼 수 없고 오로지 특허실시의 외관을 작출하기 위한 경우에도 마찬가지이다. 특허상표의 경우 오로지 손해배상금만을 목적으로 상표제도를 악용하는 사례가 많으므로 심리에 신중을 기할 필요가 있다.

단순히 특허발명의 존속기간 만료가 임박하였다는 사정만으로는 보전의 필요성을 부인하기 어려울 것이다.

㉔ 채무자 측의 사정

가처분신청이 받아들여질 경우 본안판결의 확정 시까지 채무자가 입게 될 손해를 고려하여야 한다. 채권자 측의 실시상황이 극히 미미한 반면 채무자의 영업규모가 큰 경우에는 보전의 필요성을 배척해야 할 사유가 될 수 있을 것이나, 채무자가 사업의 초기 단계에 있거나, 당해 제품의 사업상 비중이 낮은 경우에는 채무자가 입게 될 타격이 적으므로 보전의 필요성이 보다 쉽게 인정될 수 있다.

특허권 침해의 성립요건으로서 채무자의 고의·과실 등 주관적 요소는 필요하지 않으나, 보전의 필요성을 판단함에 있어서는 가처분으로 인하여 채무자가 입게 될 손해가 채무자의 고의적인 특허권 침해행위로 인하여 스스로 초래한 것인지 여부도 고려하여야 한다. 예를 들어 채무자가 스스로 특허권 침해제품을 생산한 것이 아니라 제3자로부터 이를 구입하여 사용하고 있고, 구입 과정에서 특허권 침해사실을 인지하였다고 볼 사정이 전혀 없는 경우에는 보전의 필요성 인정에 신증을 기할 필요가 있다.

채무자가 가처분신청 이전에 이미 침해행위를 중단한 경우에도 보전의 필요성이 부정될 수 있으나, 가처분결정을 피하기 위한 방법으로 임시적으로 중단한 것에 불과하여 이후 다시 침해행위를 재개할 우려는 없는지 살펴볼 필요가 있다. 한편 가처분신청을 인용하는 결정에 따라 침해행위가 중단되었다고 하더라도 채무자들이 그 가처분의 적법 여부에 대하여 다투고 있는 이상 권리 침해의 중단이라는 사정만으로 종래의 가처분이 보전의 필요성을 잃게 되는 것이라고는 할 수 없다(대판 2007. 1. 25. 2005다11626).

448

② 본안소송에서의 승패의 예상

침해금지가처분의 피보전권리가 일단 소멸된 경우라 하더라도 본안소송에서의 종국적인 승소 가능성은 상이할 수도 있으므로 본안소송에서의 승패의 예상도 보전의 필요성 유무를 판단하는 하나의 요소가 된다.

판례는 가처분신청 당시 채무자가 특허청에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있는 경우나, 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 보전의 필요성이 없는 것으로 보는 것이 합리적이라고 하였다(대판 1993. 2. 12. 92다40563, 대결 2007. 6. 4. 2006마907 등).

특허발명이 신규성은 인정되나 진보성이 없는 경우에는 보전의 필요성을 결한 것으로 볼 수 있겠지만 특허권자의 침해금지청구가 권리남용이라고 보아 피보전권리 자체를 부정하는 것도 가능할 것이다(대판(전) 2012. 1. 19. 2010다95390 참조). 다만 권리남용 항변

에 있어서는 특허무효의 명백성을 요구하는 반면에 보전의 필요성 판단에서는 특허무효의 높은 개연성을 요구한다는 점에서 그 요건이 다소 완화된다고 볼 수 있다.

③ 공공복리

일반적으로는 유효한 특허권에 대한 침해가 인정될 경우에는 그 특허권을 보호하여 주는 것이 공익에 부합한다고 할 수 있다. 그러나 침해금지가처분의 인정으로 오히려 공공복리에 심각한 위해가 발생할 우려가 있을 경우, 가령 채권자가 특허발명을 실시하지 않거나 극히 미미한 정도로 실시하고 있는 반면에 채무자는 상당한 규모로 특허발명을 실시하여 의약품이나 생활필수품으로서 달리 대체품도 없는 제품을 대량생산하는 경우 등에는 보전의 필요성이 없다고 볼 여지가 크다.

- 449 채무자가 국방상 필요한 물품을 생산하는 경우에도 보전의 필요성을 배척할 수 있을 것이다. 특허법은 정부가 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있는 등(특허 41조 등), 국방상 필요한 물품을 생산하는 경우에는 특별한 규정을 두고 있는데, 신청대상이 국방상 상시사용에 필요한 물품이고 그 생산을 금지하면 급히 대체생산을 통한 공급 곤란의 문제를 해결할 수 없는 등의 사정이 있는 경우에는 보전의 필요성을 배척할 수 있을 것이다.

(5) 심리

(가) 원칙적 심문

지식재산권의 침해금지가처분은 성질상 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에 해당하므로 기일을 열어 심리하면 가처분의 목적을 달성할 수 없는 사정이 있는 때를 제외하고는 원칙적으로 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 한다(민집 304조 본문).

신청이 받아들여지면 채무자는 본안판결을 받기도 전에 물건의 생산, 사용, 양도 등 경제활동을 전면적으로 금지당하는 결과가 되어 치명적인 손해를 입게 되는 반면, 신청이 배척되면 많은 연구개발비를 투입하여 특허발명을 한 채권자의 독점적 실시권이 특허기간 중에도 보장받지 못하여 특허보호제도를 유명무실하게 할 우려가 있는 등 특허권침해금지 가처분사건은 당사자의 이해관계에 미치는 영향이 지대하므로, 실무상으로도 통상 심문이나 변론 등 신중한 심리절차를 거쳐 결정하고 있다.

특히 심리할 때 법원은 신청목적을 이루는 데 필요한 처분을 직권으로 정할 수 있으므로(민집 305조 1항), 오로지 피보전권리와 보전의 필요성 유무만을 심리할 것이 아니라, 가처분결정을 하더라도 본안에서 채무자가 승소할 경우에 대비하여 가처분 목적도 어느 정

도 달성하면서, 한편으로는 채무자의 피해를 최소화할 수 있는 적당한 처분이 무엇인지까지 미리 염두에 두고 이 부분도 심리하면 최종 결정 시에 도움이 된다.

(나) 소명방법

450

특허권 등 등록된 지식재산권의 경우 등록원부와 등록공보가 필수적인 소명자료이므로, 가처분신청서에 첨부하여 제출하도록 할 필요가 있다.

원래 심문절차에서는 즉시 조사할 수 있는 증거를 소명방법으로 하여야 하므로 증인신문이나 검증·감정 등의 증거조사절차를 거치지 않음이 원칙이지만, 실무상으로는 기술사항이 복잡하고 쌍방이 제출한 감정서의 의견이 엇갈려 심증 형성에 어려움이 있을 때에는 심문절차에서도 위와 같은 증거조사 신청을 받아들이는 경우도 있다. 실무상 컴퓨터프로그램의 실질적 유사성 판단과 같이 고도의 전문성이 필요한 사안에서는 본안소송에서 이미 감정이 이루어지지 않은 이상 소명방법으로 감정을 필요로 하고 있다.

또한 위와 같은 정식의 증거조사절차를 거치지 않더라도 필요한 경우 증인신문에 갈음하여 참고인을 신문하거나, 검증에 갈음하여 임의제출의 형식으로 발명실시품을 제출받아 법관이 직접 살펴보기도 한다.

기술적인 사항에 관하여 전문가의 설명이 필요한 경우에는 실무상 별도의 기술설명회를 개최하기도 한다. 기술설명회란 특허발명과 채무자가 실시하는 물건 또는 방법의 기술내용을 이해하기 위하여 당사자로부터 제출받은 기술설명서 또는 프레젠테이션 등에 의하여 기술설명을 행하는 것을 말하는데, 실제로 심증 형성에 많은 도움이 되고 있다. 이러한 기술설명에 대리인 또는 본인 외에 전문심리위원에 의하여 이루어지는 경우는 물론이고, 당사자의 담당 직원 등 제3자가 설명하는 경우에도 정식의 증거조사 및 구술에 의한 변론 또는 심문절차의 일부가 되는 것이므로, 민사소송법상의 해당 요건(전문심리위원의 선정 또는 변론의 경우 증인의 선서, 심문의 경우 참고인으로 채택 등)을 갖추어야 한다. 기술설명회는 쟁점 기술이 특정되고 침해 여부에 대한 공방이 어느 정도 이루어진 후에 하는 것이 효율적이다.

법원조직법 54조의3에 따라 법원에 각종 조사관을 둘 수 있는데, 이 중 기술 분야에 관한 조사관(이하 ‘기술조사관’)이 배치된 법원에서는 통상 위와 같은 기술설명회에 기술조사관도 참석시키고 있다. 실무상 기술조사관은 기술설명회에서 당사자의 기술설명 내용을 청취하고, 필요한 경우 재판장을 통하여 특정 부분에 관한 구체적인 설명을 요청하며, 이후 당사자의 기술설명 내용에 관한 추가 자료를 수집·정리하여 재판부에 제출하는 등의 방식으로 조사 업무를 수행하고 있다.

451

실무상 특허등록무효 등 관련 사건의 결과를 기다리는 경우도 있으나, 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위한 데 의의가 있으므로, 가능하면 자체적인 소명절차를 토대로 결론을 내는 것이 바람직하다.

(다) 담보

담보하는 대상은 가처분이 발령되는 경우 본안판결의 확정 시까지 채무자가 입게 될 손해이다.

특허권침해금지가처분의 성질상 청구금액이나 목적물의 가액에 따른 담보의 기준이 있을 수 없다. 결국 가처분발령 후 본안판결 시까지 채무자가 당해 실시품의 생산 중단 등으로 인하여 입게 될 예상 손해액을 기준액으로 삼고, 여기에 채권자의 자력과 소명의 정도, 본안에서의 승소가능성 등을 종합적으로 고려하여 구체적인 사안에 따라 적절하게 증감한 금액을 정할 수밖에 없을 것이다.

실무에서는 가처분결정에 앞서 담보제공명령을 별도로 발하기보다는 담보제공을 조건으로 하여 가처분결정을 내리는 경우가 많다.

(6) 재판

(가) 대상물의 특정

채무자가 채권자의 권리를 침해하여 실제로 실시하고 있는(또는 실제로 실시할 급박한 우려가 있는) 물건 또는 방법을 명확하게 특정하여야 한다. 단순히 “특허등록번호 제○호의 어떤 권리범위에 속하는 것과 동일 또는 유사한 물건의 제조·판매”라고 하든가 “상표등록번호 ○호와 동일 또는 유사한 상표의 사용”이라고 표시하여서는 아니 된다. 가처분을 집행하는 집행관이 다시 동일·유사한가, 권리범위에 속하는가를 심리하여 판단할 수 없기 때문이다.

452 (나) 필요한 범위의 한정

특허권침해금지가처분은 상대방에게 주는 피해가 크므로 특허권을 침해하는 행위만을 국한하여 신청의 범위 내에서 신중하게 발령하여야 한다.

(다) 반제품의 표시

특허권을 침해하는 물건의 완성품 외에 그 반제품에 대하여도 집행관의 보관을 명할 필요가 있으나 단순히 ‘반제품’이라고 표시하게 되면 권리범위와는 관련 없는 부분의 부품까지를 포함하는 용어가 되므로 ‘반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건)’이라고 표시함이 타당하다.

(7) 지식재산권침해금지가처분의 주문례

(가) 특허권·실용신안권

① 물건의 발명

1. 채무자는 별지 목록 기재 및 표시 제품을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 된다.
2. 채무자는 그 본점, 지점, 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 보관 중인 위 제품과 그 반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건)에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.
3. 집행관은 채무자가 위 제품과 그 반제품을 보관하고 있던 장소에서 이를 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

채권자의 특허권을 특정하고 그 권리범위에 속하는 제품의 생산 등을 하여서는 아니 된다는 식의 주문은 집행이 가능할 만큼 특정되었다고 할 수 없다.

실무상 생산, 양도, 대여 또는 수입, 양도 또는 대여의 청약, 이를 위한 전시를 모두 금지대상에 포함하는 것이 일반적이나, 가령 채무자가 유통업체라서 직접 제품을 생산하는 업무에는 종사하지 않는 등 일부 종류의 행위 이외에는 금지명령을 할 보전의 필요성이 없다고 볼 경우도 있을 것이다.

제조설비에 대한 점유해제 부분은 특허법 127조에서 ‘그 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 특허권에 대한 침해행위로 보고, 126조 2항에서 ‘특허권자나 전용실시권자는 침해행위에 제공된 설비의 제거 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다’라고 규정하고 있는 데서 비롯하는 것이므로, 그 제조설비가 특허권·실용신안권 침해행위에만 사용되지 아니하고 다른 제품을 생산하는 데에도 사용되는 경우에는 그 점유해제를 명하지 않는다. 453

종래 실무상 신청취지에서 점유해제 대상물의 소재지를 지정하면서 ‘본점, 지점, 사무소, 공장 … 그 밖의 장소에 보관 중인’이라는 표현을 사용하는 경우가 많았는데, ‘그 밖의 장소’ 또는 ‘기타의 장소’라는 표현은 특정되지 않은 개념이므로 그러한 표현을 사용하여 점유해제 대상물의 소재지를 특정하는 것은 바람직하지 않다.

특허권·실용신안권침해금지 가처분사건에서 침해물품에 대한 점유해제 및 집행관 보관명령에 그치지 아니하고 곧바로 침해물품의 폐기를 구하는 경우가 있으나, 실무상 가처분 단계에서는 폐기를 명하는 주문을 발령하지 않는다. 제조, 판매 등을 금지하는 이상

즉시 폐기하지 않고 본안소송이 종결된 후에 폐기하더라도 가처분의 목적을 달성하는 데 별다른 지장이 없고, 채무자의 손해와 채권자가 본안에서 패소할 경우 채무자에게 배상할 손해를 고려하더라도 즉시 폐기는 적당한 처분의 내용이라고 보지 않는 것이 실무의 대세이다.

실무상 채권자가 실시금지명령과 점유해제 및 집행관 보관명령에 대하여 집행관 공시를 구하는 경우가 종종 있으나, 실시금지명령의 경우에는 집행관이 그 금지명령을 공시할 적절한 방법이 없는 경우가 대부분일 뿐 아니라 특단의 사정이 없는 한 이를 공시하는 것이 그 실효성을 확보하기 위하여 필요하지 않으므로 집행관 공시 신청을 받아들이지 않는 것이 실무의 경향이다. 점유해제 및 집행관 보관명령의 경우도 집행관이 별도의 장소에서 목적물을 직접 보관하는 때에는 그 보관의 취지를 공시하는 것이 가처분결정의 실효성을 확보하기 위하여 필요하다고 보기 어려우므로, 집행관이 보관장소, 비용 등의 관계로 목적물을 사실상 채무자에게 보관케 하는 경우를 제외하고는 선불리 집행관 공시명령을 발하지 않는 것이 바람직하다.

권리를 침해하는 부분이 전체 물건의 일부에 불과할 때에는 채무자에게 나머지 부분을 분리·수거하여 사용할 수 있도록 다음과 같은 문구를 덧붙일 수 있다.

집행관은 채무자의 신청이 있으면, 위 물건 중 별지 목록 기재 및 표시 ○○ 부분 이외의 부분품을 분리하는 것을 허용하고, 그 분리된 부분품에 대한 점유를 풀어야 한다.

② 물건을 생산하는 방법의 발명

채무자는 별지 기재 방법에 의하여 ○○을 제조하거나, 위 방법에 의하여 제조한 ○○을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 위 제품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 된다.

③ 방법의 발명

채무자는 별지 기재 방법을 사용하여서는 아니 된다.

(나) 디자인권

채무자는 별지 목록 기재 및 표시 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 위한 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 된다.

(다) 상표권침해금지·부정경쟁행위금지가처분

① 상품주체 혼동행위

1. 채무자는 별지 1 목록 표시 표장을 별지 2 목록 기재 제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물에 표시하거나, 별지 1 목록 표시 표장이 표시된 별지 2 목록 기재 제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포, 수입, 수출, 전시하여서는 아니 된다.
2. 채무자는 그 본점, 지점, 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 보관 중인 별지 1 목록 표시 표장이 표시된 별지 2 목록 기재 제품 및 그 반제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물에 대한 점유를 풀고, 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.
3. 집행관은 채무자가 위 제품과 그 반제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물을 보관하고 있던 장소에서 이를 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.
4. 집행관은 채무자의 신청이 있으면 별지 2 목록 기재 제품 및 그 반제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물로부터 별지 1 목록 표시 표장을 말소하고 위 물건을 채무자에게 반환하여야 한다.

상표·서비스표나 상품표지·영업표지와 관련된 금지신청에서는 채무자가 실제로 사용하고 있는 표장이나 표지를 구체적·개별적으로 특정하여야 한다. 이와 달리 채권자의 등록상표나 주지 표지를 특정하고 이와 동일 또는 유사한 표장이 표시된 제품의 생산 등을 하여서는 아니 된다는 식의 주문은 집행이 가능할 만큼 특정되었다고 할 수 없다. 채권자 상표와 채무자 표장의 동일·유사 여부를 판단하기 위해서는 채무자가 사용하고 있는 표장 중 채권자 상표와 유사한 일부분이 아니라 전체를 모두 특정하도록 하여야 한다. 455

실무상 채무자에 대하여 특정한 문자나 명칭의 사용금지를 구하는 신청도 있으나, 동일한 문자 또는 명칭을 사용하더라도 구체적인 사용방식에 따라서 채권자의 상표권이나 서비스표권의 권리범위에 속하지 않을 여지가 있다면, 채무자가 실제 사용 중인 특정한 외관을 가진 표장으로만 금지대상을 한정하는 것이 타당하다. 디자인권이나 상표권에서 색채가 디자인이나 상표의 구성요소가 되는 경우에는 신청취지나 주문에서 색채도 특정하여야 한다.

② 영업주체 혼동행위

채무자는 자신의 ○○ 영업과 관련하여 별지 목록 표시 표장을 그 사무소 본점 및 지점, 영업소, 매장의 외부 간판, 현수막, 포스터, 가격표, 영수증, 종업원 배지 및 유니폼, 쇼핑백, 홈페이지를 비롯한 웹사이트, 이메일, 전단지, 잡지 광고면, 포장지 및 명함에 표시하여서는 아니 된다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법') 2조 1호 나목에 규정된 이른바 영업주체 혼동행위는 주지성을 취득한 채권자의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 채권자의 영업과 채무자의营业을 혼동하게 하는 행위이므로, 비록 채무자가 채권자의 주지 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하더라도 이를 채권자

와 이종의 영업에 사용하여 혼동이 초래될 염려가 없다면 이는 영업주체 혼동행위에 해당하지 않는다. 따라서 영업주체 혼동행위를 금지하는 가처분을 발령할 때에는 표지 사용이 금지되는营业을 특정하는 것이 바람직하다.

- 456 이와 달리 채권자의 영업표지가 주지성을 넘어 저명성을 취득하였을 경우에는 채무자가 채권자와 동종 영업은 물론 이종 영업에 그와 동일 또는 유사한 표지를 사용하더라도 부정경쟁방지법 2조 1호 다목에 규정된 이른바 저명표지 희석행위에 해당하므로, 이러한 경우에는 표지 사용이 금지되는营业을 특정할 필요가 없다.

③ 도메인이름 부정사용행위

채무자는 별지 기재 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소(URL)로 사용하여서는 아니 된다.

④ 품질 등 오인 야기행위

채무자는 자신이 판매하는 ○○ 제품을 인터넷 웹사이트, 일간신문 등 간행물, 라디오 및 텔레비전 등 방송매체를 통하여 광고함에 있어 별지 목록 기재 광고문구를 사용하여서는 아니 된다.

⑤ 상품형태 모방행위

1. 채무자는 20 . . .까지 별지 표시 제품을 생산, 양도, 판매, 대여, 수입, 수출하거나 이를 위한 청약, 전시 및 광고를 하여서는 아니 된다.
2. 채무자는 그 본점, 지점, 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 보관 중인 별지 표시 제품 및 그 반제품에 대한 점유를 풀고, 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다(보관 기한은 20 . . .까지로 한다).

부정경쟁방지법 2조 1호 자목에 규정된 이른바 상품형태 모방행위는 채권자 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년간 금지되므로, 심리 결과 상품의 형태가 갖추어진 날이 특정된다면 가처분결정의 주문에 금지 기간 및 집행관 보관기간을 특정하는 것이 바람직하다. 다만 심리 결과 상품의 형태가 갖추어진 날을 파악하기 어렵다면 가처분의 특수성에 비추어 기간을 특정하지 않아도 무방하다. 이러한 경우에는 채무자 측에서 기간이 경과하였음을 사유로 가처분이의 또는 취소신청을 하게 될 것이다.

- 457 (라) 저작권침해금지가처분

특허권침해금지가처분에 준한다. 주문례는 다음과 같다.

① 서적의 경우

1. 채무자는 별지 목록 기재 서적을 인쇄, 제본, 판매, 배포하여서는 아니 된다.

2. 채무자는 위 서적과 인쇄용 컴퓨터 파일 저장매체에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.
3. 집행관은 채무자가 위 서적을 보관하고 있던 장소에서 이를 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

채무자의 서적 중 일부분의 저작권만 침해된 경우에는 “채무자는 별지 제1목록 기재 서적 중 별지 제2목록 기재 각 해당 부분을 삭제하지 아니하고는 위 서적을 인쇄, 제본, 판매, 배포하여서는 아니 된다”라고 기재하고, 점유해제 및 집행관 보관명령 부분에 “집행관은 채무자의 신청이 있으면 위 각 해당 부분을 말소하고 위 서적을 채무자에게 반환하여야 한다”라는 부분을 부가하기도 한다. 다만 이 경우 신청취지에 말소 후 반환의 취지가 기재되어 있지 않다면 나머지 신청을 기각한다는 주문도 함께 기재하여야 한다.

종래에는 “위 서적에 관한 인쇄용 지형, 사진 및 아연판에 대한 점유를 풀고”라는 표현을 사용하는 것이 일반적이었으나, 인쇄조판 방식의 변화에 따라 현재는 ‘인쇄용 컴퓨터 파일’이나 ‘인쇄용 프로그램’ 등의 표현이 사용되고 있다. 한편 서적에 대한 인쇄, 제본, 판매, 배포 금지만으로 가처분의 목적을 달성할 수 있는 경우에는 채무자 점유 금지 및 집행관 보관명령을 부가하지 않는 것이 실무의 경향이다.

② 음악의 경우

채무자는 별지 목록 기재 음악을 수록한 시디(CD), 카세트테이프, 비디오테이프, 엠프시리(MP3) 파일을, 제작, 판매, 배포하여서는 아니 된다.

③ 모바일 애플리케이션을 통한 음원 배포의 경우

채무자는 모바일 애플리케이션 '○○'의 이용자들이 위 애플리케이션을 이용하여 별지 기재 음원을 복제하거나 전송받도록 하여서는 아니 된다.

④ 시각적 캐릭터의 저작물성이 인정되는 경우

채무자는 별지 1 표시 캐릭터가 표시된 별지 2 목록 기재 제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포, 수출, 전시하여서는 아니 된다.

⑤ P2P 서비스 제공자의 저작권침해 방조책임

채무자는 자신이 운영하는 ○○ 웹사이트를 통하여 그 이용자들이 하여금 별지 목록 기재 동영상에 들어있는 파일을 채권자의 동의 없이 공중의 다운로드(또는 ‘내려받기’)가 가능한 상태로 업로드하거나(또는 ‘올리거나’), 이를 알면서 다운로드하도록(또는 ‘내려받도록’) 하여서는 아니 된다.

⑥ 스트리밍 서비스 제공자의 저작권침해 방조책임

채무자는 자신이 운영하는 ○○ 웹사이트의 이용자들로 하여금 별지 목록 기재 동영상에 들어있는 파일을 위 웹사이트의 서버에 업로드하도록(또는 ‘올리도록’) 하거나, 별지 목록 기재 동영상에 들어있는 파일을 검색하고 이를 채무자가 개발한 ○○ 프로그램을 이용하여 스트리밍 방식으로 시청하도록 하여서는 아니 된다.

(마) 영업비밀침해금지가처분

① 기본형

1. 채무자는 20 . . . 까지 별지 1 목록 기재 제조공정에 관한 별지 3 목록 기재 문서 및 컴퓨터 파일을 열람하거나 이를 채권자 이외의 자에게 공개하여서는 아니 된다.
2. 채무자는 20 . . . 까지 별지 2 목록 기재 제품을 생산, 판매, 양도, 대여, 수출하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 그 본점, 지점, 사무소, 공장에서 별지 3 목록 기재 문서 및 컴퓨터 파일을 저장한 정보저장매체에 대한 점유를 풀고, 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.

459 영업비밀의 보유자는 침해자에 대하여 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고(부정경쟁방지법 10조 1항), 이와 아울러 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다(부정경쟁방지법 10조 2항). 금지를 구하는 ‘침해행위’가 무엇인지에 따라 신청취지가 달라질 수 있다. 영업비밀이 담긴 서류나 컴퓨터 파일을 부정하게 취득하여 열람하는 것이 침해행위인 경우 그 열람의 금지 및 서류, 파일의 집행관 보관을 구하는 반면, 유출된 설계도에 기해 제품을 생산하는 것이 침해행위인 경우 그 생산의 금지 및 제품의 집행관 보관을 구하게 된다. 부정경쟁방지법 2조 3호는 영업비밀의 ‘사용’도 침해행위의 유형으로 적시하고 있으나, 이행을 명하는 주문에 기재하기에 다소 추상적인 용어로 볼 수 있어, 금지청구 대상을 더 구체화하는 것이 바람직하다.

영업비밀침해금지가처분에 있어서 기존 실무는 신청취지에 채권자의 영업비밀을 특정하는 것이 일반적이다. 다만 영업비밀의 특징을 지나치게 구체적이고 상세하게 요구할 경우 이로 인하여 채권자의 영업비밀이 비밀성을 상실할 우려가 있으므로, 집행상 의문을 남기지 않는 범위 내에서 이를 개괄적으로 특정하는 것이 불가피한 측면도 있다. 판례는 영업비밀침해행위의 금지를 구하는 경우에는 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없도록 그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한 한 영업비밀을 구체적으로 특정하여야 하고, 어느 정도로 영업비밀을 특정하여야 하는지는 영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀침해행위의 구체적 태양과 금지청구

의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다고 하였다(대결 2013. 8. 22. 2011마1624). 영업비밀은 대부분 파일이나 문서의 형태로 보관되고 있기 마련이므로, 실무상 채권자로 하여금 영업비밀로 주장하는 파일이나 문서의 명칭을 적시하고 그에 관한 간단한 설명을 덧붙이게 하고 있다.

실무상 영업비밀에 관한 증거의 경우 제출 종류와 범위를 정하기 위해 재판부가 먼저 내용을 확인한 후, 공개로 보유자가 입는 불이익과 비공개로 상대방이 입는 불이익을 비교 460
형량하여 비공개가 필요하다고 인정되는 부분을 삭제한 자료의 제출을 명하는 방식이 활용되기도 한다. 한편 부정경쟁방지법 14조의4에 따라 ‘영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송’에 적용되는 비밀유지명령(다른 당사자, 소송대리인, 그 밖에 해당 소송으로 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용하거나 제3자에게 공개하지 않도록 하는 명령)이 본안소송 이외에 가처분사건에도 활용될 수 있는지 문제되나, 보전소송도 소송의 일종에 해당하고 실무상 영업비밀침해금지 청구는 대부분 가처분절차를 통해 이루어지는 점을 고려하여 이를 긍정하는 견해가 유력하다.

한편 채권자의 영업비밀은 신청원인의 전제사실로서만 특정하고, 금지청구의 대상으로는 채권자의 영업비밀을 이용하여 채무자가 생산하는 제품이나 확보한 기술 또는 영업활동을 명시하는 방식으로 신청취지를 구성하는 경우에는 “채무자는 ○○ 제품을 제조, 판매 하여서는 아니 된다.”라고 기재하는 것으로 족하다. 채무자 제품 중 특정한 부품만이 채권자의 영업비밀을 침해하였고, 물리적으로 그 부품을 분리하는 것이 가능하다면 제품 전체가 아니라 당해 부품의 제조, 판매를 금지하는 것이 적절하다.

금지 기간을 정할 때에는 영업비밀 보유자가 아니라 영업비밀의 침해행위자가 독자적으로나 역설제에 의하여 적법하게 개발하는 데 소요되는 기간, 기술의 발전 속도 등을 고려하여야 한다.

심리 결과 영업비밀 보호기간이 남아 있으면 남은 기간 동안 침해금지청구권이 인정되고, 이미 영업비밀 보호기간이 지났다면 침해금지청구권은 소멸한다. 다만 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다. 이처럼 금지기간을 정하지 않는다고 해서 영구히 금지하는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자는 나중에 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장·증명하여 가처분이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다룰 수 있다(대결 2019. 3. 14. 2018마7100).

461 ② 근로자에 대한 영업비밀침해금지 내지 전직금지가처분

1. 채무자는 20 . . .까지 신청의 회사에서 별지 1 목록 기재 제조공정을 통한 별지 2 목록 기재 제품의 제조, 판매 및 그 보조업무에 종사하여서는 아니 된다.
2. 채무자는 별지 1 목록 기재 제조공정에 관한 별지 3 목록 기재 생산방법을 사용하거나 이를 신청의 회사 그 밖의 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.

영업비밀에 대한 침해금지 기간과 종업원의 전직금지 기간을 별개로 취급하여 서로 상이한 기간을 설정하는 것이 대체적인 실무이다. 두 금지 기간의 성격은 일단 같다고 보이지만 전직금지 기간의 성격에는 종업원의 직업선택의 자유 등의 예민한 문제도 포함되어 있어 금지 기간을 정할 때에 그러한 사정까지 참작하여 결정하기 때문인 것으로 보인다. 그리고 퇴직한 근로자에 대하여 전직금지의무를 부과하는 것은 종전에 근무하던 직장의 영업비밀을 보호하기 위한 것이므로 특별한 사정이 없는 한 영업비밀의 존속기간을 넘는 기간까지 전직을 금지할 수는 없다(대판 1996. 12. 23. 96다16605, 대판 1998. 2. 13. 97다24528 등 참조).

판례 중에는 ① 전업금지약정의 내용, 영업비밀침해금지 기간을 3년으로 인정함으로써 전업금지 기간까지 장기간으로 할 필요가 없다고 보이는 점, 채무자의 개인적 사정, 퇴직 후 3년의 전업금지 기간은 과도한 면이 있고 본안판결 확정 전에 가처분의 형식으로 그와 같이 장기간 전업금지를 명해 두어야 할 긴급한 필요성도 인정하기 어려운 점 등을 들어 영업비밀침해금지가처분 기간은 3년, 전업금지 기간은 1년으로 그 기간을 달리 인정한 사례가 있고(대판 2003. 3. 14. 2002다73869), ② 석재의 연마, 절단, 가공을 위한 다이아몬드 톱(Diamond Saw)의 팁(Tip) 제조 공정 중 분말처리공정에 있어서의 결합제(Bond)의 성분과 배합비율, 금속분말의 비중, 성형 및 소결공정에 있어서의 가열온도와 가열시간, 가하는 압력 등에 관한 다양하고 핵심적인 영업비밀에 대하여 기술정보를 사용할 수 없는 기간을 퇴직 후 3년으로 인정한 것이 형평의 원칙에 비추어 현저하게 불합리하다고는 인정되지 않는다고 한 사례가 있으며(대판 1998. 2. 13. 97다24528), ③ 전직금지 기간도 영업비밀침해금지 기간과 같이 채무자가 영업비밀 취급업무에서 실질적으로 이탈한 시점부터 1년간이라고 인정한 원심을 수긍한 사례가 있다(대결 2003. 7. 16. 2002마4380).

462

본안소송과 달리 가처분사건에서는 실무상 전직금지 기간을 특정하는 대신 본안소송의 판결 확정 또는 선고 시까지 전직을 금지하는 방식이 이용되기도 한다.

이와 같은 기간 산정의 차이는 영업비밀로서 보호될 수 있는 기간을 정함에 있어서 참작하여야 하는 여러 가지 개별적인 문제, 즉 영업비밀 기술이 동종 업계에 얼마나 널리 알려

져 있는지, 관련 분야의 기술 발전 속도, 상대방 회사의 기술수준 등을 사건마다 종합적으로 고려하여야 하기 때문으로 보인다. 근로계약에서 기간에 관한 구체적인 약정이 있다면 그 기간, 근로자의 업무내용이나 성질, 노트·컴퓨터파일 등을 가져간 사실이 있는지, 회사에 근무하면서 구체적으로 영업비밀침해행위를 하였다는 근거가 있는지 등을 두루 고려하여 금지기간을 정함이 타당하다.

(8) 집행

지식재산권침해금지가처분 중 집행관 보관형 가처분결정은 집행관에게 집행기간인 2주 내에 집행을 위임하여 행한다. 집행관은 동산의 점유이전금지가처분(집행관 보관형)의 집행방법에 준하여 집행한다.

채무자에게 부작위의무를 부과하는 가처분에서 채무자가 부작위의무를 위반하여 계속 침해행위를 하면 대체집행의 방법으로 가처분에 위반한 실시품 등을 제거할 수 있고, 간접강제의 방법을 취할 수도 있다.

위반일수 1일당 일정 금액을 지급하도록 명한 간접강제결정 이후 당해 결정 위반을 사유로 집행문부여신청이 있는 경우, 채권자가 제출한 소명자료를 토대로 위반일수를 확인하여 집행문에 집행금액을 기재하게 된다.

2. 광업권에 대한 가처분

463

가. 개요

광업권은 채굴되지 아니한 광물을 채굴하고 취득할 권리로서, 물권으로 부동산에 준한다(광업법 10조 1항). 광업권에 대한 가처분은 주로 그 처분금지가처분이 대부분이다. 광업권에 기한 방해배제가처분은 부동산소유권에 기한 방해배제가처분과 같이 생각하면 된다.

과거에는 광업권으로만 규정하고 있던 것을 2011. 1. 28.부터 시행된 광업법에서는 탐사권과 채굴권으로 구분하여 규정하고 있고(광업법 9조의2), 처분의 방법도 탐사권은 양도에 의한 처분만이 가능하며, 채굴권은 양도, 조광권·저당권의 설정에 의한 처분이 가능하므로(광업법 11조), 그 처분금지가처분은 광업 원부(광업법 38조)를 통하여 광업권의 종류를 확인하여 그 종류에 따른 처분 가능한 행위를 금하는 것으로 하면 된다. 광업 원부를 통하여 광업권의 종류를 구체적으로 특정하면 주문에는 탐사권 또는 채굴권으로 구분하지 아니하고 광업권으로 표시하더라도 무방하다.

조광권은 설정행위에 의하여 타인의 광구에서 채굴권의 목적이 되어 있는 광물을 채굴하고 취득하는 권리로서(광업법 3조 4호), 조광권 자체도 물권이지만, 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우 외에는 권리의 목적으로 하거나 타인이 행사하게 할 수 없으므로(광업법 47조 참조), 처분금지가처분을 인용하는 예가 거의 없다.

나. 주문례

채무자는 별지 목록 기재 광업권에 관하여 양도, 저당권 또는 조광권의 설정 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.

464 다. 집행

부동산처분금지가처분에 준하여 가처분기입의 등록을 광업등록사무소장에게 촉탁한다(광업등록령 1조의2, 19조 1호).

이때에 과세표준은 1건이라고 표시하고(광업권이 수 개일 때에는 그 건수), 등록면허세는 1건당 12,000원이며(지방세 28조 1항 8호 라목), 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20이다(지방세 151조 1항 2호).

제7절 단체 임원의 직무집행정지 등에 관한 가처분

1. 피보전권리와 본안소송

가. 주식회사 이사 등의 직무집행정지가처분

주식회사의 이사선임결의의 무효나 취소 또는 이사해임의 소가 제기된 경우 또는 급박한 사정이 있는 때에는 본안소송의 제기 전이라도 법원은 당사자의 신청에 의하여 가처분으로서 이사의 직무집행을 정지하거나 직무대행자를 선임할 수 있다(상 407조 1항).

주식회사의 이사직무집행정지가처분에 대한 상법 407조 1항은 주식회사의 집행임원(상 408조의9), 감사(상 415조), 감사위원회(상 415조의2 7항), 청산인(상 542조 2항), 유한회사의 이사(상 567조), 감사(상 570조), 청산인(상 613조 2항), 상호회사의 이사(보험업법 59조 2항), 감사(보험업법 59조 3항), 청산인(보험업법 73조), 선주상호보험조합의 이